

제5장 전부명령

제5장 전부명령

제1절 의의

전부명령이란 금전채권에 대한 압류 후 그 현금화의 방법으로 압류한 금전채권을 권면액으로 압류채권자에게 이전시키고 그 대신 동액 상당의 집행채권을 소멸시킴으로써 채무자의 채무변제에 갈음하게 하는 제도를 말한다.¹⁾

즉 압류된 채권이 그 명목액과 같은 가치를 가지는 것으로 보고 이를 압류채권자에게 이전시킴으로써 채권의 평가, 현금화, 추심 등의 절차를 생략하고 바로 변제의 효력을 낳게 함으로써 그 집행을 종료시키는 것이다.

전부명령은 앞의 제4장에서 본 추심명령과 달리 그것을 얻으면 위와 같이 즉시 변제의 효력이 발생하고 채권자가 제3채무자의 무자력의 위험을 부담하기 때문에 독일법에서와 같이 압류에 의하여 압류질권의 발생을 인정하는 법제에서는 물상담보권이 있는 확실한 채권이 아니면 전부명령을 채택할 실익이 없다. 그러나 채권자 평등주의를 채택하고 있는 우리 민사집행법하에서는 전부명령에 의하여 압류채권자가 다른 채권자에 우선하여 독점적으로 변제받을 수 있으므로 채권자평등주의의 예외규정이라고 볼 수 있다.

전부명령의 경우에는 다른 채권자가 배당요구를 할 수 없어 압류채권자가 독점적 만족을 받을 수 있는 이점이 있는 반면, 제3채무자가 무자력인 때에는 전혀 만족을 받을 수 없게 되는 위험을 감수해야 한다. 채무자의 제3채무자에 대한 채권이 있음이 확실하면 이 제도를 이용하는 것이 유리한 까닭에 실무상 그 이용률이 적지 않다.

위 전부명령은 지급에 갈음하여 압류채권을 압류채권자에게 이전하여 그 채권의 만족을 주는 집행행위이고, 여기서 「지급에 갈음한다」 함은 채무자가 압류채권자에 대하여 현실로 금전을 지급하는 대신 채무자의 제3채무자에 대한 채권을 압류채권자에게 이전하여 그것으로 채무자로부터 변제가 있는 것으로 본다는 의미이다.

그러므로 전부명령이 발부되고 그 명령이 적법하게 송달되었다 하더라도 전부명령의 내용이 되는 전부채권이 존재하지 아니할 때에는 전부채권 이전·청구채권 변제·청구채권소멸 등과 같은 전부명령의 효력이 발생할 여지가 없으며, 결국 그 전부명령

1) 방순원, 민사소송법(하), 보성문화사(1980), 205.

은 실체상 무효라 할 것이다.²⁾

☞ 채권자가 경합하는 경우의 처리방법으로는 우선주의와 군단우선주의 및 평등주의가 있다.

이 중 우선주의는 먼저 집행에 착수한 채권자에게 우선권을 인정하여 그가 집행 목적물의 환가대금으로부터 먼저 만족을 받고 그보다 늦게 집행에 착수한 채권자는 선순위자가 받아가고 남은 잔액만을 받을 수 있는 제도로서 독일 및 영미 등이 채택하고 있는 입법례이다.

군단우선주의는 평등주의와 우선주의의 중간적 입장으로서 최초의 압류 후 일정한 시간 내에 집행에 착수하거나 배당요구한 채권자들로 제1군을 형성하고 그 뒤의 압류와 그 후 일정한 기간 내에 집행에 착수하거나 배당요구한 채권자들로 제2군을 형성하는 식으로 순차 군을 형성한 다음, 선순위군에 속하는 채권자들은 후순위군에 속하는 채권자에 우선하여 집행목적물의 환가대금으로부터 만족을 받되 동일군에 속하는 채권자 상호간에는 평등배당을 받는 제도로서, 스위스와 독일의 1931년 민사소송법 개정초안이 이 제도를 채택하고 있다고 한다.

평등주의는 다수채권자 경합의 경우 각 채권자는 목적물의 환가액으로부터 채권액에 따라 안분비율로 배당받는 제도를 말하고 평등배당주의라고도 한다. 이에 의하면 압류의 선후에 불구하고 배당요구시기까지 배당요구하거나 강제집행을 신청한 채권자는 평등한 대우를 받게 되는데, 현재 우리와 일본의 민사집행법이 이러한 입장을 채택하고 있다.

그런데 평등주의를 채택하고 있는 우리 민사집행법에 있어서 외관상 우선주의를 취하고 있는 것처럼 보이는 것이 채권집행에 있어서의 전부명령이다. 전부명령은 위에서 보았듯이 압류명령의 뒤를 이어서 환가방법의 일종으로 집행법원이 발하는 명령으로서 압류된 채권을 그 권면액으로 집행채권의 변제에 갈음하여 집행채권자에게 이전하게 하는 내용의 재판인바, 아래에서 다시 보듯이 그에 대하여 즉시항고가 없거나 즉시항고를 하였더라도 그 이유가 없으면 확정되어 그 효력이 제3채무자에게 송달된 때로 소급하여 발생하고 그 송달시까지 다른 채권자의 압류, 가압류 또는 배당요구가 없으면 다른 채권자를 배제하고 선착순한 채권자가 실질적으로 우선변제를 받게 되는 것이다(민집 제229조 제5항, 제231조 등 참조).

2) 대법원 1967. 12. 5. 선고 67다1614 판결

그러나 이러한 효과는 우리 민사집행법이 취하고 있는 채권자평등주의에 정면으로 반하는 것이라기보다는 전부명령에 있어서는 채권의 압류와 현금화 및 만족 단계가 거의 동시에 이루어지기 때문에 다른 채권자가 개입할 여지가 적다는 것에서 기인하는 반사적 효과에 불과한 것으로 보아야 할 것이고, 만일 전부명령의 효력이 발생하기 전에 다른 채권자가 개입하면 전부채권자는 우선적 만족을 얻지 못하고 평등배당을 받을 수밖에 없다. 즉 유체동산이나 부동산강제집행의 경우에도 다른 채권자가 개입하기 전에 집행이 끝나버리면 선착수한 채권자는 사실상 우선변제를 받는 것과 같은 결과로 되는 것은 채권압류 및 전부의 경우와 다를 것이 없고, 다만 그 차이는 전부명령의 경우 일반적으로 압류명령과 동시에 신청하므로 밀행성이 있고 그 절차도 신속히 종료해버리므로 사실상 다른 채권자가 이를 알아차리고 개입하기가 곤란한 반면, 채권을 압류하여 추심명령을 받거나 유체동산 또는 부동산에 대한 강제집행을 하는 경우에는 밀행(密行)하기도 어렵고 시간도 다소 걸리기 때문에 다른 채권자가 개입할 수 있는 여지가 상대적으로 더 많다는 것에 있을 뿐이다.

제2절 신청 및 재판

I. 전부명령의 신청

1. 신청방식

가. 전부명령도 제4장에서 본 추심명령과 같이 압류채권자(압류채권자의 승계인을 포함한다)의 신청에 의하여 발령된다.

위 전부명령의 신청은 압류명령의 신청과 동시에 할 수도 있고 사후에 신청할 수도 있으나, 실무상 동시에 신청하는 예가 많다. 그러나 민사집행법 제233조의 규정에 의한 증권채권의 경우에는 집행관이 증권을 점유한 후가 아니면 신청을 할 수 없으므로 동시신청을 할 수 없다.

수개의 집행권원에 기하여 1개의 신청으로 채권압류 및 추심 또는 전부명령을 신청하는 경우에는 압류명령과 추심 또는 전부명령은 수개의 신청을 편의상 1건으로 신청한 것이므로 각 집행권원의 수에 상응하는 인지를 첨부해야 한다.³⁾

나. 신청은 서면으로 하여야 한다(민집 제4조).⁴⁾ 추심명령을 얻은 채권에 대하여 그 후에 다시 전부명령을 신청할 수도 있다. 채권가압류가 된 후에 가압류채권자가 집행권원을 취득하더라도 직접 전부명령을 신청할 수는 없고 채권압류명령신청과 함께 하여야 한다.⁵⁾ 이 압류명령신청이 있으면 가압류는 본압류로 이전한다.

다. 압류채권의 일부에 대하여 전부명령신청을 할 수 있을 것인가의 문제가 있으나, 이를 부정할 이유는 없을 것이다.

다만 민사집행법 제233조의 증권채권에 대하여는 일부의 배서가 무효인 것(어음법 제12조, 수표법 제15조)과의 관계를 고려할 때 압류채권 일부에 대한 전부명령은 허용되지 않는다고 볼 것이다.

또한 합동채무를 부담하는 여러 사람을 상대로 하는 전부명령은 그 여러 사람에

3) 대법원 재판예규 제1524호, “수개의 집행권원에 기하여 1건으로 채권압류 및 전부명령을 신청할 경우 첨부할 인지액(재민 87-9)”

4) 별지서식 [5-1] 채권압류 및 전부명령 신청서 및 [5-4] 근저당권부 채권압류 및 전부명령 신청 참조(제5장 말미 수록)

5) 조성수, “전부명령에 관한 제문제”, 사법논집 17집, 법원행정처(86.12), 269.

대하여 동시에 전부명령을 신청할 때에는 허용되지만, 그 중 일부에 대하여 이미 전부명령을 받은 때에는 집행채권은 소멸하므로 새로운 전부명령은 허용되지 아니한다.

라. 전부명령의 신청서에는 당사자의 표시·압류한 채권의 종류와 액수·그 일부에 대하여 전부를 구할 경우에는 전부를 받을 채권액을 명시하고, 압류한 채권을 지급에 갈음하여 압류채권자에게 이전함을 구하는 취지·신청날짜·집행법원을 표시하고 채권자 또는 그 대리인의 기명날인이 있어야 하며, 전부명령만을 별도로 신청하는 경우에는 선행의 채권압류명령사건의 표시(사건번호 등)가 있어야 한다.

그리고 민사집행법 제233조의 증권채권의 경우에는 집행관의 증권점유사실을 증명하기 위하여 그 집행조서등본을 붙여야 한다.

마. 압류명령 후에 채권자의 변동이 있는 경우에 승계인은 승계집행문을 얻어 그 승계집행문 및 승계를 증명하는 증명서의 송달증명서를 신청서에 붙여야 하고(민집 제31조, 제39조, 민집규 제19조 제3항), 압류명령 후 채무자 또는 제3채무자에게 상속·합병 등의 일반승계가 생긴 경우에는 전부명령신청서에 그러한 사실을 분명하게 하여야 하며, 또 이를 증명하는 자료를 붙여야 한다. 강제집행은 그 성질상 집행채무자의 사망 기타 원인에 의한 절차의 중단이란 것이 없다.⁶⁾

2. 관할법원

전부명령을 신청하여야 할 관할법원은 압류명령의 집행법원과 동일한 지방법원이다.

전부명령이 압류명령과 별도로 신청되는 경우에 압류명령이 송달된 뒤에 채무자나 제3채무자의 주소가 변경되어 그 보통재판적이 달라지더라도 전부명령을 압류명령을 전제로 하여 내려지는 것이므로 전부명령은 압류명령을 발령한 법원이 그 관할법원으로 된다.

II. 전부명령의 재판과 송달

1. 심리

가. 집행법원은 전부명령의 신청이 있으면 관할권의 유무, 신청의 적법 여부, 집행장애(채무자의 파산, 채무자를 위한 회생절차개시, 집행정지결정 등의 제출)의 유

6) 대법원 1969. 11. 28.자 69마845 결정【결정요지】경매절차에 있어 소유자가 사망하였다 하여도 수계절차를 필요로 하지 않는다.

무, 압류효력의 유무, 전부명령의 요건을 심리하여 그 신청의 허부를 결정한다.

이러한 심리에 있어 채무자 또는 제3채무자를 심문할 수도 있지만(민집 제23조 제1항, 민소 제134조), 압류명령의 신청과 동시에 신청된 경우에는 그 심문이 허용되지 않는다고 본다(민집 제226조 참조).

또 집행법원에 의한 요건 심리는 형식적 심사이므로 형식적으로 유효한 집행행본이 있는 한 집행채권의 존재에 관하여 실질적으로 심사하지 않고 그 목적채권의 존부 내지 내용에 관하여도 실질적으로 심사하지 아니한다.

나. 전부명령의 목적인 채권의 표시는 이해관계인 특히 제3채무자로 하여금 채무자의 다른 채권과 구별할 수 있을 정도로 기재하여 그 동일성의 인식을 저해할 정도에 이르지 아니하는 한 유효하다.⁷⁾

판례⁸⁾는, 아파트 건축·분양 사업의 시행사가 공사도급변경약정에 정한 배분순위에 따라 각 세부 항목별로 분양수입금을 지급받을 수 있는데, 위 시행사의 채권자가 항목을 특정하지 아니한 채 ‘분양수입금 청구채권’ 일부에 대하여 채권압류 및 전부명령을 받은 사안에서, 전부명령에서 피전부채권인 분양수입금 청구채권은 공사도급변경약정에 기하여 시행사가 제3채무자에 대하여 가지는 채권임을 명시하고 있어 채권의 발생원인과 채무자가 구체적으로 특정되어 있는 점 등에 비추어, 위 전부명령의 피전부채권이 채권의 동일성을 인식할 수 없을 정도로 불특정된 것은 아니라고 보고 있다.

다. 심리 결과 전부명령을 발할 것이 아닌 부적법한 신청인 경우에는 그 신청을 기각(각하)하며, 이 기각결정은 집행채권자에게만 송달하면 되고 그와 같은 결정에 대하여 집행채권자는 즉시항고로서 불복할 수 있다. 그 밖에 신청에 관한 설명은 제4장에서 본 추심명령의 경우와 거의 같다.

2. 송달

가. 제3채무자에 대한 송달

전부명령도 추심명령과 같이 제3채무자에게 송달하여야 한다(민집 제229조 제4

7) 대법원 1965. 10. 26. 선고 65다1699 판결【판결요지】중증원에게 명의신탁된 중증소유 부동산에 관하여 제3자 명의로 원인무효의 소유권이전등기가 경유된 경우에는 중증은 수탁자가 가지고 있는 소유권이전등기 말소등기절차이행 청구권을 대위행사 할 수 있다.; 대법원 2011. 4. 28. 선고 2010다89036 판결

8) 대법원 2011. 4. 28. 선고 2010다89036 판결

항, 제227조 제2항).

법원사무관 등은 정보 송달 전에 명령원본과 정보의 기재를 대조하여 송달할 정보에 오기 또는 탈루가 없도록 주의하여야 하며, 만약 제3채무자에게 송달된 정보의 기재 중 중요한 사항에 관하여 오기·탈루가 있으면 전부의 효력이 생기지 아니한다.

연대채무 등 제3채무자가 수인인 경우에는 각 별도로 송달하며, 신청에 보증인이 표시되어 있는 때에는 보증인에게도 송달한다. 물상보증에 의한 저당권 기타 담보부채권의 경우에는 물상보증인(부동산소유자)에게도 송달한다. 권리능력 없는 사단·재단에 대한 송달은 대표자에 대하여 하면 충분하고, 제3채무자가 제한능력자인 경우에는 법정대리인에게 송달하여야 한다. 은행과 같이 점포가 다수일 경우에는 그 점포명을 특정할 필요가 있으며, 이 경우에는 당해 지점장에게 직접 송달함이 상당할 것이나,⁹⁾ 본점에 송달되었다 하더라도 그 송달은 유효하다고 본다.

전부명령은 제3채무자에게 송달된 후 확정되어야 효력이 발생하므로 제3채무자가 소재불명으로 송달불능이 된 경우에는 담보부채권의 경우 외에는 실제 문제로서 채권의 추심도 불가능하게 되어 집행 자체의 실익이 없게 되는바, 이때에는 채권자에게 취하를 권고함이 바람직할 것이나, 만약 채권자가 이에 불응한다면 제3채무자에 대한 송달을 공시송달로 할 수 있을 것인가가 문제로 된다. 이에 대해서는 이를 긍정하는 견해¹⁰⁾와 부정하는 견해¹¹⁾가 나타나고 있다.

나. 채무자에 대한 송달

전부명령은 채무자에게도 송달하여야 한다(민집 제229조 제4항, 제227조 제2항). 채무자에게 전부명령이 송달되지 않으면 전부명령이 확정되지 않고 따라서 전부명령의 효력이 발생하지 않는다(민집 제229조 제6항, 제7항).¹²⁾

채무자에 대한 송달이 소재불명으로 불능으로 된 때에는 어떻게 할 것인가. 이에 대하여는 전부의 효력은 제3채무자에 대한 송달에 의하여 이미 발생되어 있으므로

9) 남기정, 실무 강제집행법(3), 육법사(1989), 83.

10) 조성수(주5), 272.

11) 이영섭 대표, 위 주석강제집행법(中), 48. 이 견해는 공시송달 뿐만 아니라 우편송달도 할 수 없다고 주장하는데 그 이유로서, 이 경우 제3채무자는 당사자가 아니며 또 우편송달은 발송만으로 송달된 것으로 간주하고 공시송달은 게시일부터 2주가 경과하면 송달의 효력이 생기므로 두 종류의 송달이 모두 제3채무자에게는 실제로 도달되지 않은 상태이므로 압류의 효력이 발생할 수 없을 뿐 아니라 그러한 송달로는 압류가 있음을 인식할 수 없다는 것을 들고 있다.

12) 즉시항고의 기회가 주어지지 않았기 때문이다.; 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 법원행정처(2014), 395.

새삼스럽게 공시송달을 할 필요가 없다는 견해,¹³⁾ 채권자의 신청에 의하여 공시송달 할 것이라는 견해, 집행법원이 직권 또는 신청에 의하여 공시송달할 수 있다는 견해,¹⁴⁾ 집행법원은 채무자의 소재를 조사할 필요 없이 직권으로 공시송달을 할 수 있다는 견해¹⁵⁾ 등이 나오고 있다. 집행법원이 직권 또는 신청에 의하여 공시송달할 수 있다고 봄이 적절하다고 생각한다.

다. 채권자에 대한 고지

전부명령은 즉시항고할 수 있는 재판이므로(민집 제229조 제6항) 신청인인 채권자에게 적당한 방법으로 고지하여야 한다(민집규 제7조 제1항 제2호).

위 고지의 방법에 관하여는 특별한 규정이 없으므로 반드시 송달방법에 의할 필요는 없고 등기우편 또는 보통우편 등에 의하거나 직접 교부하더라도 무방하다.

13) 松岡義正, 強制執行要論, 清水書店(1935), 1,100.

14) 이영섭 대표, 위 주석강제집행법(中), 48.

15) 조성수(주5), 272.

제3절 전부명령의 요건·내용·효력 등

I. 전부명령의 요건

1. 서

전부명령은 추심명령과 같이 금전채권에 대한 압류명령에 이어 행하는 현금화수단으로서 압류된 채권을 그 실질적 가치를 고려하지 아니하고 그 권면액으로 채권자에게 이전하는 효력을 가지고 있다는 점에서 다음과 같은 요건이 필요하게 된다.

2. 강제집행의 일반적 요건 및 채권압류명령의 존재

전부명령도 강제집행의 일종이므로 강제집행의 요건과 강제집행개시의 요건을 모두 갖추어야 하는 것은 채권압류명령의 경우와 같다.

이처럼 강제집행의 요건이나 집행개시의 요건을 갖추지 못한 전부명령의 효력에 대하여는 논의가 있었고, 전부명령에 대하여 즉시항고가 인정되지 않던 때의 종래 통설¹⁶⁾은 강제집행의 요건이 결여된 경우뿐만 아니라 강제집행개시의 요건이 결여된 경우에도 전부명령이 송달되면 불복방법이 없다는 점을 들어 전부명령이 아닌 다른 강제집행과는 달리 무효라고 보고 있었으나, 전부명령에 대하여 즉시항고가 가능하게 된 이상 강제집행의 요건을 갖추지 못한 경우는 별론으로 하고 강제집행개시의 요건을 갖추지 못한 경우에는 다른 강제집행의 경우와 마찬가지로 즉시항고에 의하여 취소되지 않는 한 유효하다고 볼 것이다.¹⁷⁾

그리고 강제집행의 일시정지를 명하는 재판이 집행기관에 제출되었거나 채무자에 대하여 (개인)회생절차가 개시된 때에는 전부명령을 발령할 수 없다. 이에 위반된 전부명령에 관해 무효라고 보는 것이 종래 통설이었지만,¹⁸⁾ 이 경우도 즉시항고에 의하여 취소되지 않는 한 유효하다고 본다.¹⁹⁾

16) 종래 통설에 대하여는 이재성, “전부명령에 대하여”, 이재성평석집 3권, 144.; 남기정(주9), 191-192. 등 참조; 鈴木忠一 = 三ヶ月章 責任編集, 注解民事執行法(4), 第一法規出版株式會社(昭和60), 425. [稻葉威雄 집필부분]은 집행항고가 인정되는 민사집행법하에서도 종래 통설과 같은 입장을 취하고 있다.

17) 김능환·민일영 편집대표, 주석민사집행법[V], 한국사법행정학회(2012), 472.

18) 방순원(주1), 284.; 이재성(주16), 146.

19) 김능환·민일영 편집대표, 위 주석민사집행법[V], 472.; 鈴木忠一 외, 위 注解民事執行法(4), 603.

다만 전부명령을 발한 후에 민사집행법 제49조 제2호 또는 제4호의 서류를 제출한 것을 이유로 전부명령에 대한 즉시항고가 제기된 경우에는 항고법원은 다른 이유로 전부명령을 취소하는 경우를 제외하고는 항고에 관한 재판을 정지하여야 한다(민집 제229조 제8항). 이는 개인회생재단에 속하는 채권에 대한 전부명령이 확정되지 않은 상태에서 개인회생절차가 개시되고 이를 이유로 전부명령에 대하여 즉시항고가 제기된 경우도 동일하고,²⁰⁾ 당초 신청한 개인회생절차가 채무자의 개인회생신청 취하 등을 이유로 폐지되었다고 하더라도, 그 압류 및 전부명령에 대한 항고재판 진행중에 채무자가 새롭게 신청한 개인회생절차가 다시 개시되었다면 변제계획이 인가 시까지 그 항고재판을 정지하여야 하는 것은 마찬가지이다.²¹⁾

채권압류 및 전부명령에 대한 항고심에서 항고인이 가집행의 선고가 있는 판결을 취소한 항소심 판결의 사본을 제출하였다면 항고심으로서의 항고인으로 하여금 그 정본을 제출하도록 한 후 즉시항고를 받아들여 채권압류 및 전부명령을 취소하여야 하고,²²⁾ 저당권에 기한 물상대위권의 행사를 위해 압류 및 전부명령을 발령받은 때 그 기초가 된 저당권의 피담보채권의 부존재를 확인하는 취지의 확정판결정본이 항고심 또는 재항고심 계류 중에 제출된 경우도 동일하다.²³⁾

또한 전부명령이 유효하기 위해서는 우선 채권압류명령이 있어야 한다. 법원이 전부명령을 발부하기 전에 이미 채권압류명령의 효력이 발생하여야 할 필요는 없고, 압류명령과 전부명령을 동시에 신청하여도 무방하지만, 유효한 압류명령이 없는 한 전부명령의 효력이 생길 여지는 없다.²⁴⁾ 같은 건지에서 압류명령을 발한 뒤 2, 3일 후 전부명령을 발하여 각각 제3채무자에게 송달하였는데 늦게 송달한 전부명령이 먼저 송달된 경우에도 그 후 압류명령이 송달됨으로써 전부명령의 하자도 보정되어 그 때에 전부명령의 효력이 발생한다고 해석하는 것이 상당할 것이다.²⁵⁾

3. 피압류채권이 금전채권으로 권면액을 가질 것

가. 금전채권일 것

1) 전부명령은 압류된 채권을 지급에 갈음하여 압류채권자에게 이전시키고 그것으로 채무자가 채무를 변제한 것으로 간주하는 것이므로 전부명령의 대상인 채권은

20) 대법원 2008. 1. 31.자 2007마1679 결정

21) 대법원 2009. 9. 24.자 2009마1300 결정

22) 대법원 2004. 7. 9.자 2003마1806 결정

23) 대법원 2008. 10. 9.자 2006마914 결정

24) 방순원(주1), 284.; 中野貞一郎, 民事執行法, 靑林書院(1991), 555.

25) 이재성, 민사재판의 이론과 실제(Ⅱ), 법조문화사, 146.

집행채권과 마찬가지로 금전채권이어서 한다.

따라서 금전채권이 아닌 채권은 피전부채권으로서의 적격이 없다. 민사집행법 제245조가 “유체물의 인도나 권리이전의 청구권에 대하여는 전부명령을 하지 못한다.”라고 하고 있는 것은 이 점을 주의적으로 규정하는 것이라고 볼 수 있다.

2) 또한 민사집행법 제233조의 지시채권 중 화물상환증 등 인도증권에 표창된 유체물인도청구권에 대한 집행의 경우에도 전부명령이 부적당하다.

나아가 채무자와 제3채무자 사이의 채권관계가 돈으로 받기로 한 것이 아니고 쌀로만 받기로 특약한 채권인 때에는 금전채권이 아니므로 이에 대하여 전부명령이 있었다 하여도 무효이고,²⁶⁾ 건설공제조합 조합원의 지분 내지 지분권은 금전채권이 아니므로 피전부적격이 없으며,²⁷⁾ 채무자가 제3채무자에 대하여 가지는 부당이득한 채권의 반환청구권(채무자가 제3채무자에게 명의신탁한 부동산이 경매되어 경매법원이 제3채무자 명의로 남겨놓은 경락대금지급청구권의 반환청구권) 또한 피전부채권으로서의 적격이 없다.²⁸⁾

3) 상계가 금지되는 채권이라도 압류금지채권에 해당하지 않는 한 강제집행에 의한 전부명령의 대상이 될 수 있다.²⁹⁾

나. 권면액을 가질 것

1) 금전채권이라고 하더라도 이른바 권면액을 가진 것이라야 전부명령의 대상이 되는가에 관하여는 학설과 판례상 논의가 있다.

여기서 권면액이라 함은 채권의 목적으로 표시되어 있는 금전의 확정된 일정액

26) 대법원 1962. 1. 25. 선고 4294민상148 판결

27) 대법원 1979. 12. 11. 선고 79다1487 판결 【판결요지】건설공제조합법에 의하여 설립된 특수법인인 건설공제조합의 조합원의 출자는 출자증권에 표상된 조합원의 지분이며 위 조합원의 지분내지 지분권은 민사소송법 제563조 제1항에서 말하는 금전채권이 아니므로 피전부채권의 적격이 없다.

28) 대법원 1985. 3. 12. 선고 84다카1784 판결 【판결요지】전부명령에 있어 채무자가 제3채무자에게 동인의 타인에 대한 채권의 반환청구권을 가지고 있다 하더라도 위와 같은 채권의 반환청구권은 피전부채권으로서의 적격을 가지고 있다 할 수 없으므로 명의신탁된 부동산에 관하여 경매가 실시되어 경매법원이 경락대금을 채권자들에게 배당한 후 그 배상잔여금을 명의수탁자 앞으로 남겨 놓은 경우 위 명의신탁 계약이 해지되어 명의신탁자가 위 배상잔여금을 교부받을 권리의 반환청구권을 가지게 된다 하더라도 명의신탁인을 채무자, 명의수탁인을 제3채무자로 하여 하는 압류전부명령은 허용되지 아니한다.

[이 판결에 대하여는 그것이 아직 발생하지 않은 장래채권의 피전부적격성을 부정한 것으로 이해하고 이 사건에서는 제3채무자의 채무자에 대한 원상회복청구권은 현재 발생한 것으로서 피전부적격이 있다는 취지로 비판하는 견해가 있으나[이재성, “장래채권의 피전부적격성”, 이재성평석집 (Ⅸ), 211. 이하], 위 판결이 채무자의 제3채무자에 대한 채권의 피전부적격을 부정한 것은 그 채권이 금전채권이 아니라는 데에 그 이유가 있는 것이라고 볼 것이다.]

29) 대법원 2017. 8. 21.자 2017마499

을 말하며, 그 채권의 거래의 실가(實價)를 말하는 것은 아니다.

권면액이라는 용어를 사용하지 않고 있는 현행법의 해석으로는 채권이 권면액을 가질 것이 전부명령의 요건이 아니라는 견해도 있으나,³⁰⁾ 현행법의 해석으로도 전부 될 채권은 반드시 권면액을 가진 것이라야 한다는 것이 압도적 다수설³¹⁾로 보인다.

이처럼 다수설이 전부명령의 경우에 채권의 권면액을 요구하는 이유는 전부명령이라는 제도가 본래 제3채무자의 자력 유무 또는 장래의 변제 여부에 관계없이 압류한 채권을 압류채권자가 취득하게 함으로써 집행채무자의 채무는 변제된 것으로 간주하겠다는 것이므로 압류된 채권의 실가(實價)와는 관계없이 그 권면액으로 변제에 갈 음한다고 할 수밖에 없을 것이기 때문이라는 데에 있다.³²⁾

2) 그러나 다수설에서도 금전채권 중 장래의 채권, 조건부채권, 반대급부에 걸린(동시이행관계에 있는) 채권 등과 같이 채권의 확정적 실현이 의문시되어 권면액의 존재를 인정하기 어려운 채권을 전부명령의 대상으로 할 수 있는지에 대하여는 견해가 일치되어 있지 않고, 이를 부정하는 것이 다수의 견해로 보인다.³³⁾

30) 이영섭, 신민사소송법(하), 박영사(1960), 175-176.; 김종대, “임차보증금의 법적 성질과 그 전부에 따른 실무상 제문제”, 사법논집 18집, 132-133, 등

31) 방순원(주1), 286.; 이재성(주16), 159-160.; 박두환, 신강제집행법, 고시계(1991), 240.; 김영일, “장래채권의 피전부적격”, 사법논집 11집, 464., 467-468.; 조성수(주5), 283-284.; 조무제, “임대차보증금반환청구권이전의 법률관계”, 사법논집 18집, 122.; 신창수, “임대차보증금관계의 법률적 구성”, 사법논집 19집, 133.; 유승정, “장래의 채권에 대한 전부명령 그 허부 및 효력”, 민사재판의 제문제 6권, 153-154, 등

32) 이재성(주16), 160.

33) 예컨대, 장래의 금료채권이나 사용수익에 대한 차임채권과 같은 것은 현실적으로 반대채권인 임대차목적물의 사용수익 또는 노무의 제공이 없이는 구체적으로 발생하지 아니하므로 그 채권의 존부가 미확정이기 때문에 전부명령의 대상이 되지 않고, 피용자가 퇴직하기 전의 퇴직금채권도 그에 대하여 전부명령을 허용하여도 채권자가 현실적으로 그 채권을 추심할 수는 없고 제3채무자가 전부명령 발령 후에 취득한 채권으로 상계를 할 수 있는가 하는 점 등 복잡한 문제가 생기므로 전부명령을 허용할 수 없으며, 조건부채권 중 임차인의 보증금반환청구권은 임대차계약종료 후에도 인도할 때 임대인이 임차인에 대하여 가지는 모든 채권을 공제하고 남는 것이 있음을 조건으로 하여 그 잔액에 대하여 발생하는 것인 만큼 그 발생 및 금액이 불확실한 채권이어서 권면액이 없고, 반대급부에 걸린 채권이라고 할 수 있는 공사완성 전의 공사금채권에 대하여 권면액의 존재를 인정하기 어렵다고 한다. 다만 권면액의 존재를 요구하면서도 타인의 질권의 목적이 되는 채권이나 공탁의 상대방이 질권과 동일한 권리를 가지는 보증공탁금 내지 해방공탁금의 회수청구권 등과 같이 타인의 우선권의 목적이 되는 채권에 대하여는 후일 타인이 우선권을 행사하여 채권이 소멸하더라도 이는 권면액과는 관계가 없다고 하여 그 피전부적격을 인정하는 설이 유력하고 방순원(주1), 287.], 조건부채권이나 반대급부와 동시이행의 관계에 있는 채권도 후일에 권면액대로 피전부채권이 실현되지 못하는 사태가 생기더라도 집행채권자가 채무자에게 부당이득반환을 청구하면 되므로 피전부적격을 인정할 수 있다는 견해[이재성(주16), 164-165면]도 있다. 또한 권면액의 존재를 너무 엄격하게 해석하면 채권자의 권리실현을 어렵게 하는 결과로 초래하므로 임대차보증금과 같은 경우에는 그 채권발생의 기초가 되는 원인사실이 발생한 것이기 때문에 건물의 인도시에 보증금(혹은 잔액)의 반환이 확실시된다는 이유로 임대차보증금반환채권의 피전부적격을 인정하는 입장(강병호, “건물임대차가 종료된 경우 보증금반환에 관한 제문제”, 사법논집 20집 214.; 손진곤, “임대차보증금반환청구권에 대한 전부명령의 효력”, 민사판례연구 11권, 439.)도 있다.

3) 우리의 판례 중에도 대법원 1973. 1. 24.자 72마1548 결정과 같이, “강제집행에 있어서 평등배당주의를 쓰고 있는 우리의 집행법하에서는 압류한 금전채권을 지급에 갈음하여, 권면액으로 압류채권자에게 이전시켜 우선적 변제의 효과를 주는 전부명령은 압류가 경합한 때에는 허용되지 않는다고 하여야 되리니, 한 사람의 채권자에게 독점적 만족을 주는 것은 위에서 말하는 평등배당주의의 취지에 맞지 않는 까닭이다.”라고 판시하여 전부명령의 요건으로서 권면액의 존재가 필요하다는 입장을 취한 것도 있고, 또 장래의 채권 중 그 발생의 기초가 확정되어 있어 채권의 특징이 가능하고 가까운 장래에 채권이 발생할 것이 상당한 정도로 확실시되는 경우에는 일정한 권면액을 갖는 금전채권으로 보아 이에 대한 채권압류 및 전부명령은 유효하다고 보는 사안도 있으나,³⁴⁾ 대부분의 판례는 학설상으로 권면액이 없다고 보고 있는 장래의 채권, 조건부채권, 반대급부에 걸린 채권에 관하여도 권면액에 대한 언급 없이 대부분 전부명령을 인정하고 있다.

가) 장래의 채권에 관하여 : 교육공무원에게 지급할 장래의 봉급은 공무원보수규정(당시는 교육공무원보수규정)에 미리 그 지급조건이 명확하게 되어 있어 교육공무원이 제공하는 근로기간의 경과에 따라 봉급의 지급이 확실시되므로 피전부적격이 없다고는 할 수 없고,³⁵⁾ 사용자가 근로자에게 지급하는 퇴직금은 본질적으로 후

34) 대법원 2000. 10. 6. 선고 2000다31526 판결; 대법원 2010. 4. 29. 선고 2007다24930 판결(매매계약이 해제되는 경우 발생하는 매수인의 매도인에 대한 기지급 매매대금의 반환채권은 매매계약이 해제되기 전까지는 채권 발생의 기초가 있을 뿐 아직 권리로서 발생하지 아니한 것이기는 하지만 일정한 권면액을 갖는 금전채권이라 할 것이므로 전부명령의 대상이 될 수 있다고 판시); 대법원 2002. 11. 8. 선고 2002다7527 판결(건설업자가 지방자치단체가 지방재정법과 그 시행령 및 그에 의하여 준용되는 국가를당사자로하는계약에관한법률과 그 시행령에 의하여 시행하는 공사의 경쟁입찰에 참가하여 낙찰자로 결정된 후 낙찰자의 채권자가 낙찰자를 채무자로 하고, 지방자치단체를 제3채무자로 하여 낙찰자가 지방자치단체와 장차 공사도급계약을 체결하고 공사를 시공함에 따라 지방자치단체로부터 지급받게 될 공사대금채권에 대하여 채권압류 및 전부명령을 받은 경우, 피압류 및 전부채권인 공사대금채권은 그 발생의 기초가 확정되어 있어 채권의 특징이 가능할 뿐 아니라, 공사대금이 확정되어 있어 권면액도 있으며, 가까운 장래에 채권이 발생할 것이 상당한 정도로 확실시되므로 그 공사대금채권에 대한 채권압류 및 전부명령은 유효하다고 판시)

35) 대법원 1977. 9. 28. 선고 77다1137 판결【판결요지】사용자가 근로자에게 지급하는 퇴직금은 근로자의 근로제공에 대한 미지급 임금에 축적된 것이 그 재원이 된 것으로서 본질적으로는 후불적 임금의 성질을 지닌 것이라 할 것이고 퇴직금은 근로자가 사망 또는 퇴직할 때에 근로자에게 지급되는 것이기는 하나 근로기준법, 단체협약, 취업규칙, 근로계약 등에서 미리 그 지급조건이 명확히 되어 있어 그의 권리성이 부여되어 있고 근로자의 사망 또는 퇴직시에 지급될 것이 확실시되는 것이므로 근로자의 사망 또는 퇴직 전의 퇴직금 급여청구권을 추상적인 청구권에 불과한 것이라고 볼 수 없는 것이라 할것이니 퇴직금 급여청구권도 피전부적격이 있는 것이라 단정하여 후불적 임금의 성질인 퇴직금청구권이 그 지급기의 도래 전에도 민사소송법 제579조 제4항의 제한 내에서 피전부적격이 있다.

불적 임금의 성질을 지닌 것으로서 미리 그 지급조건이 명확하게 되어 있어 그 권리성이 부여되어 있고 근로자의 사망 또는 퇴직시에 지급될 것이 확실시되므로 사망 또는 퇴직 전의 퇴직금급여청구권도 그 2분의 1에 한하여 피전부적격이 있으며,³⁶⁾ 합자회사의 유한책임사원이 회사에 대하여 출자의무의 이행을 완료하면 그때에 벌써 지분환급채권은 권리성이 부여되어 발생하므로 비록 위 사원이 퇴사하기 전이라서 현실적으로 확정된 채권은 아니라도 압류 및 전부명령의 대상이 될 수 있다³⁷⁾고 한다.

또한 매매계약이 해제되는 경우 발생하는 매수인의 매도인에 대한 기지급 매매대금의 반환채권은 매매계약이 해제되기 전까지는 채권 발생의 기초가 있을 뿐 아직 권리로서 발생하지 아니한 것이기는 하지만 일정한 권면액을 갖는 금전채권이라 할 것이므로 전부명령의 대상이 될 수 있다고 보고 있으며,³⁸⁾ 사업인정 고시 후 수용재결 이전 단계에 있는 피수용자의 손실보상금채권 등에 대하여도 피전부적격을 인정하고 있다.³⁹⁾

나) 조건부채권에 관하여 : 장래 경매가 취하될 것을 조건으로 한 경매보증금의 반환청구권에 대한 전부명령은 유효하고,⁴⁰⁾ 법무사합동사무소 구성원의 위 합동사무소에 대한 배당금청구채권은 그가 계속 위 구성원으로서 근무하고 또한 그의 활동으로 배당할 이익이 생기는 것을 정지조건으로 발생하는 채권이지만 그에 대한 전부명령은 유효하며,⁴¹⁾ 골프클럽의 회원이 퇴회(退會)할 때 행사할 수 있는 정지조건부채권인 예치금반환청구권에 대하여는 압류 및 전부명령을 받는 방법으로 강제집행할 수

36) 대법원 1975. 7. 22. 선고 74다1840 판결【판결요지】퇴직금은 근로자의 근로제공에 대한 미지급 임금이 축적된 것이 그 재원이 된 것으로서 본질적으로는 후불적 임금의 성질을 지닌 것이고 근로자가 사망 또는 퇴직한 때에 지급되는 것이기는 하나 근로기준법, 단체협약, 취업규칙, 근로계약 등에서 미리 그 지급조건이 명확히 되어 있어 그의 권리성이 부여되어 있는 것이므로 퇴직금 급여청구권도 피전부적격이 있는 것이며 민사소송법 제579조 제4호의 규정에 따라 그 지급시에 받을 금액의 2분의 1에 한하여 전부의 대상이 된다.

37) 대법원 1978. 10. 31. 선고 78다1290 판결【판결요지】합자회사의 유한책임사원의 회사에 대한 지분환급채권은 그 사원이 퇴사하기 전이라서 현실적으로 확정된 채권은 아니라 하더라도 압류 및 전부명령의 대상이 될 수 없는 것은 아니다.

38) 대법원 2000. 10. 6. 선고 2000다31526 판결; 대법원 2010. 4. 29. 선고 2007다24930 판결

39) 대법원 2000. 5. 26. 선고 98다22062 판결

40) 대법원 1976. 2. 24. 선고 75다1596 판결【판결요지】장래 경매가 취하될 것을 조건으로 한 경매보증금의 반환청구권은 그 채권액이 확정된 것이므로 이에 대한 전부명령은 유효하다.

41) 대법원 1978. 5. 23. 선고 78다441 판결【판결요지】피전부채권이 정지조건부 채권인 경우에는 전부명령도 정지조건이 성취된 때에 효력이 생기므로 위 전부명령을 받아 집행된 것 만으로서는 곧 채무자의 채무변제가 있는 것으로 되어 확정적으로 채권자의 채권이 소멸한 것으로 간주할 수 없다.

있다⁴²⁾고 한다. 또한 임차인이 임대차목적물을 반환하기 전의 임차보증금반환청구권은 일종의 정지조건부채권이라 할 것인데, 판례는 그에 대한 전부명령을 유효한 것으로 보고 있다.⁴³⁾ 또 매각허가결정에 대한 즉시항고를 함에 있어 구 소송촉진등에관한특별법에 의하여 담보로 공탁한 공탁금의 회수청구권에 대하여 그 채권자가 압류 및 전부명령을 얻은 사안에 관하여, 피압류채권이 장래의 조건부채권이거나 소멸할 가능성이 있는 것이라고 하더라도 그 채권의 압류 및 전부명령의 효력에는 아무런 영향이 없고 공탁원인의 소멸 등으로 공탁자에게 공탁물회수청구권이 발생한 때에 비로소 전부명령의 효력이 발생하는 것이 아니므로 그 전부명령이 있는 후에 다시 위 공탁금회수청구권에 대하여 있는 제2의 압류 및 전부명령은 효력이 없다⁴⁴⁾고 한다.

42) 대법원 1989. 11. 10. 선고 88다카19606 판결【판결요지】[1] 피고회사에 의하여 운영되는 컨트리클럽의 골프개인회원은 입회회망자가 피고회사 이사회의 입회승인을 얻어 입회금을 납입함으로써 취득하게 되며 재산적 가치를 갖는 계약상의 지위로서 자유로이 양도할 수 있으나 그 회칙상 회원자격 심사위원회의 심의와 이사회의 승인을 얻은 후 소정의 수수료를 납부하도록 되어 있다면, 그 회원권의 양수인이 위 이사회의 승인을 얻지 못한 단계에서는 그 회원권 양도양수계약은 계약당사자 사이에 서만 효력이 있을 뿐 피고회사나 제3자에 대한 관계에서는 양수인이 아직 회원으로서의 지위를 취득하지 못하여 여전히 양도인이 회원권자라고 할 수밖에 없고, 그 양도인의 채권자는 양도인이 보유하는 회원권이나 또는 회원으로서의 지위에서 피고회사에 대하여 가지는 입회금반환청구권을 가압류할 수 있을 것이며 그 가압류 후에는 그 회원권의 양수인이 피고회사 이사회의 승인을 얻어 회원의 지위를 취득하였더라도 위 가압류채권자에 대해서는 그 회원권 취득의 효력을 주장할 수 없다. [2] 골프회원은 민사소송법 제584조 소정의 강제집행방법에 의한 집행대상이 되지만 회원이 퇴회할 때 행사할 수 있는 정지조건부 채권인 예치금반환청구권에 대하여 압류 및 전부명령을 받는 방법으로 집행할 수도 있다. [3] 골프클럽회원의 회원가입계약 해지권이 일신전속적인 권리가 아니고 그 해지(탈퇴)에 특별한 제약이 없는 것인 이상, 입회금반환청구권은 비록 입회금반환사유가 발생할 것을 정지조건으로 하는 채권이라 할지라도 그에 대한 압류 및 전부명령이 제3자인 골프장운영회사에게 송달된 때에 채권자가 집행법원을 통하여 제3자에게 채무자를 대위하여 회원가입계약 해지권을 행사한 것이라고 볼 수 있으므로 입회금반환 사유는 그 송달시에 이미 발생하였다고 볼 것이다.

43) 대법원 1981. 11. 10. 선고 81다378 판결 등【판결요지】[3] 임차인의 채권자가 임차인의 임대인에 대한 임대보증금반환채권 중 일부에 대한 전부명령을 받았다면 임차인이 임대인으로부터 받을 수 있는 임대차보증금 잔액(연체차임과 기타 손해 등을 공제한 잔액)을 확정하여 전부채권자에게 전부된 채권금액을 특정하여야 하고, 위 잔액이 전부채권자의 청구금액에 미달된다고 하여도 그 전부명령은 임대차보증금에 대한 것이므로 임차인의 임대인에 대한 부속물매수대금채권에는 미치지 아니한다. [2] 임차인이 임대인의 동의를 얻어 전대한 경우에 전차인은 임대인에 대하여 그 사용의 편익을 위하여 임대인의 동의를 얻어 시설한 부속물의 매수청구권을 행사할 수 있고, 임대인을 대위하여 명도청구를 하는 원고에 대하여도 부속물 매수대금 지급시까지의 연가적 항변권을 주장할 수 있다.

44) 대법원 1984. 6. 26.자 84마13 결정【결정요지】[1] 집행력 있는 채무명의에 터잡아 채권의 압류 및 전부명령이 적법하게 이루어진 이상 피압류채권은 집행채권의 범위 안에서 지금에 갈음하여 당연히 압류(전부)채권자에게 이전하고 채무자는 채무를 변제한 것으로 간주되어 그 후 그 압류 및 전부를 받은 채권자가 그 채권을 추심하는 과정과는 관계없이 그 강제집행은 이미 종료되었다고 할 것이므로 그 집행채권이 장래의 조건부 채권이거나 소멸할 가능성이 있는 것이라 하여도 그 채권의 압류 및 전부명령의 효력에는 아무런 영향이 없다 할 것이고 따라서 그 이후에 발령된 동일한 채권을 목적으로 하는 압류 및 전부명령은 무효라 할 것이다. [2] 공탁자의 공탁물 회수청구권에 대한 압류 및 전부명령에 있어서 그 공탁물 회수청구권은 담보취소결정이 있어야 비로소 실현될 수 있는 것이지만 전부명령의 효력으로서의 채권자의 변제의 효력에는 영향이 없는 것이므로 담보취소결정 전에 제2의 채권압류 및 전부명령이 발하여졌다 하여도 이는 무효이므로 제1의 전부채권자의 공탁금회수청구는 정당하다 할 것이다.

다) 반대급부에 걸린 채권에 대하여 : 공사대금채권은 도급계약 성립과 동시에 발생하므로 공사완성 전이라도 이를 압류하고 전부할 수 있으며,⁴⁵⁾ 공사가 완료되기 전에 전부명령이 있었을 때에는 그 공사대금채권은 공사의 정도 기타에 의하여 상호 청산시에 확정적으로 결정되는 것이므로 그 결산에 의하여 구체적으로 확정되었을 경우에 그 공사대금채권을 표준으로 하여 전부명령의 효력도 확정된다⁴⁶⁾고 한다. 그러나 공사도급계약 체결 전에는 공사대금채권이 아직 발생하지 않았으므로 그에 대한 전부명령은 무효이고 따라서 공사도급계약이 이미 체결되어 그에 기한 공사대금채권에 대하여 발부된 전부명령의 효력은 그 전부명령 송달 후 체결된 추가공사계약으로 인한 공사대금채권에는 미치지 아니하고,⁴⁷⁾ 다만 공사대금채권에 대하여 전부명령이 발부될 당시에는 채무자와 제3채무자 사이에 아직 공사도급계약이 체결되지 아니하였으나 전부명령이 제3채무자에게 송달될 당시에는 공사도급계약이 체결되었다면 그 전부명령은 유효하다⁴⁸⁾고 한다. 또한 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 그 시행령에 의하여 시행되는 공사경쟁입찰에서 회사가 이미 낙찰자로 결정됨에 따라 위 관계규정들에 의하여 지방자치단체가 그로부터 10일 이내에 낙찰자인 회사와 사이에 공사도급계약을 체결하도록 하는 의무를 부담하게 되어 특별한 사정이 없는 한 조만간 공사도급계약이 체결되도록 예정되어 있었던 경우에는 채권압류 및 전부명령정본이 지방자치단체에 송달될 당시 비록 아직 회사와 자치단체간에 공사도급계약이 체결되지 아니하여 공사대금채권이 현실적으로 발생하지는 않았지만, 위 공사대금채권은

45) 대법원 1965. 4. 27. 선고 65다142 판결 참조

46) 대법원 1974. 7. 23. 선고 73다245 판결 참조

47) 대법원 1965. 4. 27. 선고 65다142 판결; 대법원 1981. 9. 22. 선고 80누484 판결 등

48) 대법원 1989. 2. 28. 선고 88다카13394 판결 등 【판결요지】채권에 대한 압류명령은 압류목적 채권이 현실로 존재하는 경우에 그 한도에서 효력을 발생할 수 있는 것이고 그 효력이 발생된 후 새로 발생한 채권에 대하여는 압류의 효력이 미치지 아니한다. 【판결이유】원심은 그 적시의 증거에 의하여 1986.11.6.에 조달청과 남양건설(주) 사이에 체결된 계약은 새로운 추가 도급계약이 아니고 그 이전에 성립한 당초의 도급계약의 내용을 변경한 것에 지나지 아니한다고 인정하고 원고가 주장하는 채권압류 전부명령이 채무자와 제3채무자에게 송달되기 이전에 이미 채권자 박용직 외 3인으로부터 채권가압류 또는 압류가 경합되어 있어서 그 금액이 공사대금 총액(변경 후 것을 포함하는 취지임)을 초과하고 있기 때문에 원고가 취득한 전부명령은 법률상 효력이 없다고 판시하여 원고의 청구를 기각하였다. 그러나 채권에 대한 압류명령은 압류목적채권이 현실로 존재하는 경우에 그 한도에서 효력을 발생할 수 있는 것이고 그 효력이 발생된 후 새로 발생한 채권에 대하여는 압류의 효력이 미치지 아니한다고 할 것이다. 이 사건에서 1986.11.6.에 체결한 계약이 원심 인정과 같이 추가도급계약이 아니고 당초의 도급계약을 수정 변경한 것이라고 하더라도 그 이전에 있어서는 도급공사 대금액이 310,748,000원에 불과하였으므로 위 박용직 외 3인의 채권가압류 또는 압류는 위 금액범위 내에만 미치고 압류 후의 계약수정으로 새로이 추가된 금 25,852,000원에까지 미칠 수는 없다 할 것이다.

그 발생의 기초가 이미 확정되어 있어 채권의 특징이 가능할 뿐 아니라 공사대금이 확정되어 있어 권면액도 있고 나아가 가까운 장래에 채권이 발생할 것임이 상당한 정도로 확실시된 상태에 있었다 할 것이어서, 경쟁입찰에서의 낙찰자의 지위의 특수성에 비추어 비록 전부명령의 대상이 되는 위 공사대금채권이 장래의 채권이라고 하더라도 이에 대한 전부명령이 유효하다고 보고 있다.⁴⁹⁾

라) 타인의 우선권의 목적인 채권에 관하여 : 강제집행정지를 위한 보증공탁금반환청구권에 대하여 강제집행정지명령의 효력이 소멸한 다음에 압류 및 전부명령을 얻어 담보취소신청을 하는 것은 정당하다고 한다.⁵⁰⁾ 또한 질권자의 물상대위권의 효력이 미치는 채권에 대한 압류 및 전부명령이 있었으나 압류·전부된 채권이 질권자에게 모두 귀속되고 잔액이 없으면 압류·전부명령의 효력이 없다고 판시하고 있는바,⁵¹⁾ 이 판결도 물상대위권의 목적인 채권의 피전부적격을 부정한 것으로 볼 수 없을 것이다.⁵²⁾

4) 강제집행의 정지에 관하여 실무에서 문제되는 경우로는 가집행선고가 붙은 판결에 기초한 강제집행에 대하여 채무자가 상소를 제기하면서 민사소송법 제501조에 의하여 강제집행정지신청을 하고 그 담보를 공탁한 경우에 가집행채권자가 강제집행정지결정이 소멸되기 전에 위 담보공탁금회수청구권에 대하여 압류 및 전부명령을 신청하는 사례가 있는데, 가집행선고부 판결에 대한 강제집행정지를 위한 보증공탁금회

49) 대법원 2002. 11. 8. 선고 2002다7527 판결

50) 대법원 1982. 9. 23.자 82마556 결정【결정요지】이 사건 가집행선고부 판결에 대한 강제집행정지 결정은 원심의 본안판결 선고시까지 존속하는 것임이 그 결정 자체에 의하여 명백하므로 원심이 본안판결을 선고한 1982.4.29 그 정지명령의 효력은 소멸되었다 할 것인 즉 그 후에 채권자가 위 가집행선고부 판결의 채무명의로 하여 재항고인의 공탁금 반환청구권에 대하여 채권압류 및 전부명령을 얻고 이 사건 담보 취소신청을 함에 이른 것으로서 이는 위 압류전부명령에 의하여 공탁금반환청구권을 취득한 채권자가 담보 제공자인 재항고인을 대위하여 담보취소신청을 하는 것이므로 그 신청을 인용한 원심결정은 타당하다.

51) 대법원 1987. 5. 26. 선고 86다카1058 판결【판결요지】[1] 국세징수법 제34조, 제80조 제2호, 제81조 제1항 및 제84조 등의 규정은 국가의 체납처분으로 인하여 질물인 금전채권들이 압류되어 그 질권 등이 상실되는 경우 이러한 질권자를 보호하기 위하여 세무서장으로 하여금 그 배분된 금원을 한국은행에 예탁하도록 의무화할 것이고 이처럼 세무서장에게 배분된 금원에 대하여 공탁의 무가 부과된 이상 위 금원은 압류된 것과 같이 특정되었다 할 것이므로 질권자는 민법 제342조 단서에 의한 압류를 하지 않더라도 당연히 그 물상대위권의 효력이 미쳐 국가로부터 이를 지급받을 수 있으며 질권설정자 또는 이로부터 양도·전부받은 자는 그 배분된 금전 중에 위 담보채권을 초과한 잔액이 없는 한 국가에 대하여 직접 이를 청구할 수는 없다. [2] 위의 경우 질권자의 채권액을 제한 잔여금액이 존재하지 아니하는 이상 비록 질권자가 위 환급채권에 대하여 민법 제342조 단서에 의한 압류를 하기 전에 제3채권자가 미리 위 환급채권에 대하여 압류 및 전부명령을 받은 바 있다고 하더라도 그 압류 및 전부명령은 효력을 발생할 수 없다.

52) 유승정(주31), 159.

수청구권도 피전부적격이 인정되므로 그 채권에 대하여 압류명령 및 전부명령을 얻은 채권자는 다른 특단의 사정이 없는 한 당해 보증공탁금으로부터 집행채권의 만족을 얻을 수 있다.⁵³⁾

5) 한편 이러한 권면액에 대한 판례의 태도에 관하여는, 전부명령제도의 본래 취지에 맞지 않고 장래의 불확정한 채권과 관련해서는 집행채권의 소멸범위 내지 소멸시기가 불명확해져 당사자 사이에 분쟁을 증가시키는 등의 문제점이 있다는 비판이 제기되고 있다.⁵⁴⁾

즉 판례가 권면액의 개념을 넓게 해석하고 있는 데에는 기본적으로 전부명령이 확정된 후에 피전부채권이 소멸하거나 부존재한 것으로 판명되더라도 그로 인한 위험은 집행채권자 스스로가 전부명령을 신청할 때 이미 감수하겠다는 의사표시를 한 것으로 볼 수 있으므로 그에게 그로 인한 위험을 부담시키더라도 크게 부당할 것은 없을 뿐만 아니라 우리 강제집행법상의 평등주의가 가장채권자에 의한 배당요구 등으로 인하여 진정한 채권자가 만족을 얻지 못하는 단점이 많다고 보아 평등주의에 대한 예외라고 할 수 있는 전부명령이 허용되는 범위를 넓힘으로써 그러한 평등주의의 단점을 보완하려는 정책적 고려가 바탕에 깔려 있다고 추측되나, 그러한 점을 감안하더라도 판례와 같이 장래의 채권 내지 조건부채권 등에 관하여 거의 무제한적으로 전부명령을 허용함으로써 사실상 권면액의 요건을 불필요한 것으로 취급하고 있는 것은 전부명령제도의 본래의 취지에 부합하지 않고, 또한 전부명령제도는 압류된 채권이 지급에 갈음하여 압류채권자에게 이전됨으로써 간편한 방법으로 집행채권을 소멸시키는 제도인데, 장래의 불확정한 채권의 경우에는 그 채권의 존부 내지 범위가 불명확하고 그로 인하여 집행채권의 소멸범위 내지 소멸시기가 불명확해짐으로써 집행채권자와 채무자 및 제3채무자 사이에 분쟁만을 증가시키는 결과를 가져온다는 것이다.

4. 피전부채권이 양도가능할 것

양도할 수 없는 채권은 원칙적으로 압류도 할 수 없다. 따라서 전부명령의 대상이 되기 위해서는 그 채권이 양도할 수 있는 것이어야 한다.

53) 대법원 1996. 11. 25.자 95마601, 602 결정【결정요지】가집행선고부 판결에 대한 강제집행정지를 위한 보증공탁금회수청구권도 피전부적격이 인정되므로 그 채권에 대하여 압류명령 및 전부명령을 얻은 채권자는 다른 특단의 사정이 없는 한 당해 보증공탁금으로부터 집행채권의 만족을 얻을 수 있다.; 다만 보증공탁의 경우에는 공탁금회수청구권은 손해의 발생 여부가 미확정인 동안에는 권면액을 가지지 않으므로 피전부적격이 없다는 견해도 있다.

54) 김능환·민일영 편집대표, 위 주석민사집행법[V], 479-480.

당사자 사이에 양도금지의 특약이 있음에 불과한 채권의 경우에도 압류채권자가 양도금지의 특약이 있는 사실에 관하여 선의인지 악의인지를 불문하고 전부명령은 유효하다.⁵⁵⁾ 이와 같이 양도금지특약부 채권에 대한 전부명령이 유효한 이상 그 전부채권자로부터 다시 그 채권을 양수한 자가 그 특약의 존재를 알았거나 중대한 과실로 알지 못하였다고 하더라도 채무자는 위 특약을 근거로 삼아 채권양도의 무효를 주장할 수 없다.⁵⁶⁾

5. 압류, 가압류의 경합이나 배당요구가 없을 것

가. 전부명령은 실질적으로 피압류채권을 압류채권자에게 이전시킴으로써 그에게 독점적인 만족을 주는 제도이므로 다른 채권자에 의한 압류나 가압류가 경합되거나 배당요구(교부청구의 경우도 같다)가 있을 경우에는 그러한 경합채권자를 배제하고 압류채권자에게만 독점적 만족을 주는 것은 민사집행법상의 채권자평등주의 원칙에 어긋난다.

따라서 전부명령이 제3채무자에게 송달될 때까지 그 금전채권에 관하여 다른 채권자가 압류·가압류 또는 배당요구를 한 때에는 전부명령은 효력을 가지지 않는다(민집 제229조 제5항). 위 조항이 있기 전에도 판례는 동일한 취지로 판시하고 있었다.⁵⁷⁾ 채권자대위소송이 제기되고 대위채권자가 채무자에게 대위권 행사사실을 통지하거나 채무자가 이를 알게 된 이후에는 민사집행법 제229조 제5항이 유추적용되어 피대위채권에 대한 전부명령은, 우선권 있는 채권에 기초한 것이라는 등의 특별한 사정이 없는 한 무효이다.⁵⁸⁾

국세징수법에 의하여 체납처분이 행하여진 채권에 대하여 전부명령이 있는 경우에도 압류 등이 경합한 경우와 같이 그 전부명령은 무효이다.⁵⁹⁾

55) 대법원 1976. 10. 29. 선고 76다1623 판결【판결요지】당사자 사이에 양도금지의 특약이 있는 채권이라도 압류 및 전부명령에 의하여 이전할 수 있고, 양도금지의 특약이 있는 사실에 관하여 압류채권자가 선의인가 악의인가는 전부명령의 효력에 영향을 미치지 못한다.

56) 대법원 2003. 12. 11. 선고 2001다3771 판결

57) 대법원 1976. 9. 28. 선고 76다1145, 1146판결; 대법원 1978. 9. 26. 선고 78다1137 판결; 대법원 1979. 5. 15. 선고 79다372 판결 등【판결요지】가압류 또는 압류가 경합되어 있는 채권에 대한 전부명령은 무효이므로 무효인 전부채권자에 대한 제3채무자의 변제로서 다른 압류채권자에게 대항할 수 없으나, 동 채권에 대한 추심명령을 받은 채권자에 대한 제3채무자의 변제는 모든 채권자에게 대항할 수 있다.

58) 대법원 2016. 8. 29. 선고 2015다236547 판결

59) 대법원 1991. 10. 11. 선고 91다12233 판결; 대법원 2015. 8. 27. 선고 2013다203833 판결; 조정래, “채권에 대한 강제집행에 있어서의 다수채권자의 경합”, 재판자료(35), 452.;鈴木忠一外, 위 注解民事執行法(4), 610.; 서울민사지판 1984. 3. 22. 83가합6019

채권가압류에 있어서 채권자가 가압류신청을 취하하면 가압류결정은 그로써 효력이 소멸되지만, 채권가압류결정정본이 제3채무자에게 이미 송달되어 가압류결정이 집행되었다면 그 취하통지서가 제3채무자에게 송달되었을 때 비로소 가압류집행의 효력이 장래를 향하여 소멸되는 것이고, 이러한 법리는 그 취하통지서가 제3채무자에게 송달되기 전에 제3채무자가 집행법원 법원사무관 등의 통지에 의하지 아니한 다른 방법으로 가압류신청 취하사실을 알게 된 경우에도 마찬가지이다.⁶⁰⁾

나. 그리고 압류 등의 경합이 있었는지의 여부를 결정하는 기준시점은 전부명령이 제3채무자에게 송달된 때이고(민집 제229조 제5항),⁶¹⁾ 이러한 법리는 피압류채권이 장래에 발생하는 조건부채권 또는 불확정채권이라고 하더라도 다를 바가 없다.⁶²⁾

장래의 불확정채권에 대하여 압류가 중복된 상태에서 전부명령이 있는 경우에도 그 압류의 경합으로 인하여 전부명령이 무효가 되는지의 여부는 나중에 확정된 피압류채권액을 기준으로 판단할 것이 아니라 전부명령이 제3채무자에게 송달된 당시의 계약상의 피압류채권액을 기준으로 판단하여야 하고, 장래의 불확정채권에 대한 전부명령을 허용하는 것은 가까운 장래에 채권이 발생할 것이 상당한 정도로 기대되기 때문이므로 전부명령 송달 당시 피압류채권의 발생 원인이 되는 계약에 그 채권액이 정해지지 아니하여 그 채권액을 알 수 없는 경우에는 그 계약의 체결 경위와 내용 및 그 이행 경과, 그 계약에 기하여 가까운 장래에 채권이 발생할 가능성 및 그 채권의 성격과 내용 등 제반 사정을 종합하여 그 계약에 의하여 장래 발생할 것이 상당히 기

60) 대법원 2008. 1. 17. 선고 2007다73826 판결

61) 대법원 1995. 9. 26. 선고 95다4681 판결【판결요지】[1] 전부명령이 확정되면 피압류채권은 제3채무자에게 송달된 때에 소급하여 집행채권의 범위 안에서 당연히 전부채권자에게 이전하고 동시에 집행채권 소멸의 효력이 발생하는 것이므로 전부명령이 제3채무자에게 송달될 당시를 기준으로 하여 압류가 경합되지 않았다면 그 후에 이루어진 채권압류가 그 전부명령의 효력에 영향을 미칠 수 없고, 이러한 이치는 피압류채권이 공사 완성 전의 공사대금 채권과 같이 장래의 채권액의 구체적인 확정에 불확실한 요소가 내포되어 있는 것이라 하여 달라질 수 없다. [2] 채권액의 확정에 불확실한 요소가 내포된 공사 완성 전의 공사대금 채권에 대하여 전부명령을 허용하면서 동시에 그 전부명령의 효력이 장래의 채권 확정시가 아니라 전부명령이 제3채무자에게 송달된 때 발생된다고 해석하는 이상, 압류 및 전부명령을 받은 자보다 먼저 당해 피압류채권을 압류한 자가 있을 경우에 압류가 경합되어 전부명령이 무효로 되는지의 여부는, 나중에 확정된 피압류채권액을 기준으로 판단할 것이 아니라 전부명령이 제3채무자에게 송달된 당시의 계약상의 피압류채권액을 기준으로 판단하여야 한다.; 대법원 2000. 4. 21. 선고 99다70716 판결; 대법원 2001. 9. 25. 선고 99다15177 판결; 대법원 2002. 7. 12. 선고 99다68652 판결

62) 대법원 1998. 8. 21. 선고 98다15439 판결; 대법원 2000. 10. 6. 선고 2000다31526 판결

대되는 채권액을 산정한 후 이를 그 계약상의 피압류채권액으로 봄이 상당하다.⁶³⁾

다. 다만 예컨대 피압류채권 1,000만 원에 대하여 채권자 甲이 200만 원 범위에서 압류를 하고, 다른 채권자 乙이 400만 원 범위에서 압류를 한 경우와 같이 동일한 채권에 대하여 중복하여 압류 등이 있다고 하더라도 그 압류 등의 효력이 미치는 범위가 채권의 각 일부에 국한되고, 이를 합산하더라도 총 채권액(위의 경우 1,000만 원)에 미치지 아니할 때에는 여기서 말하는 압류의 경합이 있다고는 할 수 없고, 이 경우에는 채권의 일부에 관하여 발부된 전부명령은 유효하다(위의 경우에 甲이 위 200만 원에 대하여 전부부명령을 받더라도 압류가 경합되지 않은 상태에서 甲의 압류명령의 효력이 피압류채권의 전체로 확장되지 않으므로 乙은 나머지 800만 원 범위 내에서 자신의 채권 400만 원에 관하여 유효하게 다른 전부명령을 발령받을 수 있게 된다).⁶⁴⁾

동일한 채권에 두 개 이상의 채권압류 및 전부명령이 발령되어 제3채무자에게 동시에 송달된 경우 당해 전부명령이 채권압류가 경합된 상태에서 발령된 것으로서 무효인지의 여부는 그 각 채권압류명령의 압류액을 합한 금액이 피압류채권액을 초과하는지를 기준으로 판단하여야 하므로 전자가 후자를 초과하는 경우에는 당해 전부명령은 모두 채권의 압류가 경합된 상태에서 발령된 것으로서 무효로 될 것이지만 그렇지 않은 경우에는 채권의 압류가 경합된 경우에 해당하지 아니하여 당해 전부명령은 모두 유효하게 된다고 할 것이며, 그 때 동일한 채권에 관하여 확정일자 있는 채권양도통지가 그 각 채권압류 및 전부명령 정본과 함께 제3채무자에게 동시에 송달되어 채권양수인과 전부채권자들 상호간에 우열이 없게 되는 경우에도 마찬가지이다.⁶⁵⁾

라. 또한 여러 채권자에 의하여 공동압류가 행해진 경우에는 각 채권자에 대한 분할비율을 명시하는 방법에 의하여 전부할 수 있으므로 집행채권의 총액이 집행을 목적인 채권액을 초과하더라도 공동으로 전부명령을 얻을 수 있다.⁶⁶⁾

63) 대법원 2010. 5. 13. 선고 2009다98980 판결(부동산담보신탁계약에 기하여 신탁부동산을 매각할 경우 위탁자가 신탁회사에 대하여 가지는 배당금교부채권에 대한 전부명령이 압류의 경합으로 인하여 무효가 되는지 여부는 전부명령 송달 당시의 부동산 시가 상당액 등 당시까지의 수입액에서 부동산의 매각과 배당이 진행될 것을 전제로 하여 그 당시를 기준으로 산정한 우선배당금과 예상되는 환가수수료를 공제한 금액을 기준으로 판단하여야 한다고 한 사례)

64) 대법원 1979. 6. 5.자 79마715 결정 참조

65) 대법원 2002. 7. 26. 선고 2001다68839 판결, 따라서 당해 전부명령의 무효 여부를 판단함에 있어 압류액에 채권양도의 대상이 된 금액을 합산하여 피압류채권과 비교하거나 피압류채권액에서 채권양도의 대상이 된 금액 부분을 공제하고 나머지 부분만을 압류액의 합계와 비교할 것은 아니다.

66) 鈴木忠一 外, 위 注解民事執行法(4), 609.

마. 이처럼 전부명령이 제3채무자에게 송달될 당시에 압류 등의 경합이 있으면 그 전부명령은 무효이고 후에 경합된 압류나 가압류 또는 배당요구 등의 효력이 소멸된다고 하더라도 그 전부명령의 효력이 되살아나는 것은 아니다.⁶⁷⁾ 다만 다시 전부명령을 신청하는 것은 무방하다. 반면 전부명령이 압류의 경합 등으로 인하여 무효가 되는 경우에 그 전부명령의 기초가 되었던 압류명령까지 무효가 되는 것은 아니므로 무효인 전부명령을 얻었던 압류채권자도 위의 압류명령에 기초하여 추심명령을 얻을 수 있다.⁶⁸⁾

바. 한편 장래의 채권에 관하여 압류 및 전부명령이 확정되면 그 부분 피압류채권은 이미 전부채권자에게 이전된 것이므로 그 이후 동일한 장래의 채권에 관하여 다시 압류 및 전부명령이 발하여졌다고 하더라도 압류의 경합은 생기지 않고, 다만 장래의 채권 중 선행 전부채권자에게 이전된 부분을 제외한 나머지 중 해당 부분 피압류채권이 후행 전부채권자에게 이전된다.⁶⁹⁾

6. 전부명령의 무효와 제3채무자의 변제

가. 전부명령이 앞서 살펴본 요건을 갖추지 못하면 무효이다. 또한 채무자가 수인이거나 제3채무자가 수인인 경우 또는 채무자가 제3채무자에 대하여 여러 채권을 가지고 있는 경우에는 집행채권액을 한도로 하여 각 채무자나 제3채무자별로 얼마씩의 전부를 명하는 것인지 또는 채무자의 어느 채권에 대하여 얼마씩의 전부를 명하는 것인지를 특정하여야 하고, 이를 특정하지 아니한 경우에는 집행의 범위가 명확하지 아니하므로 그 전부명령은 무효라고 보아야 한다.⁷⁰⁾

67) 대법원 2001. 10. 12. 선고 2000다19373 판결; 대법원 2008. 1. 17. 선고 2007다73826 판결; 이재성(주16), 150-15.; 남기정(주9), 227.

68) 대법원 1976. 9. 28. 선고 76다1145, 1146 판결; 대법원 1983. 8. 23. 선고 83다카450 판결【판결요지】[1] 압류채권에 대한 추심명령을 받아 추심금 청구소송을 제기, 진행중 청구금액을 감축한 것은 소의 일부취하를 뜻하는 것이고 취하된 부분의 청구를 포기하였다고는 볼 수 없으며, 위 채권압류는 추심하고 남은 잔여채권에 대하여 그 효력을 지속하는 것이다. [2] 압류가 경합된 상태에서 발부된 전부명령은 효력이 없다 할 것이다.

69) 대법원 2004. 9. 23. 선고 2004다29354 판결

70) 대법원 2004. 6. 25. 선고 2002다8346 판결(이 사건 전부명령은 제3채무자가 두 명이었고, 그 중 이길수에 대하여는 기발생 이자채권과 원금채권이 따로 존재하는 데도 불구하고, 원고의 어느 제3채무자에 대한 채권이 얼마씩 전부되는 것인지, 그리고 원고의 이길수에 대한 채권은 원금과 기발생 이자채권 중 어느 부분이 얼마씩 전부되는 것인지 그 범위가 특정되지 아니하여 무효라고 할 것이라고 판시); 대법원 2010. 6. 24. 선고 2007다63997 판결(채권자들이 채무자의 제3채무자인 정리회사에 대한 공사도급계약상 '계약이행보증금채권'에 대하여 압류 및 전부명령을 받은 사안에서, 위 계약이행보증금이 지체상금과 마찬가지로 손해배상액의 예정으로서의 성질을 갖는 것으로서 정리채권확정소송에서 계약이행보증금의 액수를 초과하는 지체상금이 손해배상액으로 인정

이와 같이 전부명령이 무효인 경우 제3채무자는 이를 이유로 하여 전부명령을 얻은 채권자의 이행청구를 거부할 수 있다.

나. 문제는 제3채무자가 무효인 전부명령을 얻은 채권자에게 변제를 한 경우 그것을 가지고 채무자 또는 다른 집행채권자에게 대항할 수 있는가 여부인데, 이에 대해 판례는 원칙적으로 무효인 전부명령을 얻은 자를 민법 제470조가 규정하는 채권의 준점유자에 해당하는 것으로 보고 있다.⁷¹⁾

또한 전부명령이 압류 등의 경합으로 인하여 무효인 경우에도 제3채무자가 무효인 전부명령에 의한 전부채권자에게 그 전부금을 변제하였다면 제3채무자가 선의·무과실인 때에는 채권의 준점유자에 대한 변제로서 유효하다는 취지로 판시⁷²⁾ 73)하고 있다.

되었다고 하더라도, 집행대상의 명확성을 요하는 전부명령의 본질에 비추어, 위 압류 및 전부명령에서 집행대상 채권으로 기재하고 있는 ‘계약이행보증금채권’을 ‘지체상금채권’과 동일하게 볼 수 없을 뿐만 아니라 이를 ‘지체상금채권’에 대한 압류 및 전부명령으로서 효력을 갖는다고 볼 수도 없다고 한 사례); 대법원 2014. 5. 16. 선고 2013다52547 판결

71) 대법원 1977. 5. 24. 선고 77다309 판결【판결요지】퇴직금은 후불적 노임의 성질이 있으므로 민사소송법 제579조 소정의(노무로 인하여 받는 보수) 임이 분명하여 압류제한의 대상이 되고, 무효한 전부명령에 의하여 채권을 행사하는 자는 채권의 준점유자에 해당하니 그에 대한 변제는 유효한 변제가 되는 바 위 채권자에 대한 부당이득반환채권을 퇴직금채권의 변형으로 보아야 하므로 이를 수동채권으로 한 상계는 허용되지 않는다.; 학설도 이러한 판례의 태도를 수긍하고 있다. 이재성(주16), 183.; 남기정(주9), 243.; 宮脇幸彦, 強制執行法(各論), 有斐閣(昭和53), 155. 등

72) 대법원 1980. 9. 30. 선고 78다1292 판결; 대법원 1988. 8. 23. 선고 87다카546 판결【판결요지】[1] 원고가 압류 및 전부명령에 터잡아 제3채무자인 피고를 상대로 전부금의 지급을 청구하여 오다가 피고가 경합되는 압류 및 전부명령 채권자에게 피전부채권을 무단변제하고 원고가 손해를 입었음을 이유로 그 배상을 구하는 청구로 변경하는 것은 동일한 생활사실 또는 경제적 이익에 관한 분쟁에서 그 해결방법만을 달리하는 경우에 지나지 않는 것이어서 그 청구의 기초에 변경이 있다고 할 수 없다. [2] 채권가압류나 압류가 경합된 경우에 있어서는 그 압류채권자의 한 사람이 전부명령을 얻더라도 그 전부명령은 무효가 되지만 이경우에도 그 전부채권자는 채권의 준점유자에 해당한다고 보아야 할 것이므로 제3채무자가 그 전부채권자에게 전부금을 변제하였다면 제3채무자가 선의 무과실일 때에는 민법 제470조 에 의하여 그 변제는 유효하고 제3채무자는 다른 압류채권자에 대하여 이중변제의 의무를 부담하지 아니하나 반면에 제3채무자가 위 전부금을 변제함에 있어서 선의 무과실이 아니었다면 제3채무자가 전부채권자에게 한 전부금의 변제는 효력이 없고, 또 그것이 경합압류채권자에 대하여는 불법행위가 될 수 있는 것이므로 제3채무자는 경합압류채권자에 대하여 그로 인한 손해를 배상할 의무가 있다. [3] 을의 전부명령이 갑의 압류와 경합된 상태에서 이루어져 제3채무자인 병이 무효인 사실을 알았거나 알 수 있었음에도 불구하고 병은 을의 전부금 청구에 대하여 다투어 보지도 아니한 채 의제자백에 의한 을의 승소판결이 선고되게 하고 그 8일만에 이를 변제해 버렸다면 병에게는 갑의 압류채권을 적극적으로 침해하는 불법행위를 구성하는 고의 또는 과실이 있다고 보아야 한다.

73) 다만 대법원 1979. 5. 15. 선고 79다372 판결은, “가압류 또는 압류가 경합되어 있는 채권에 대한 전부명령은 무효이므로 무효인 전부채권자에 대한 제3채무자의 변제로서 다른 압류채권자에게 대항할 수 없으나, 동 채권에 대한 추심명령을 받은 채권자에 대한 제3채무자의 변제는 모든 채권자에게 대항할 수 있다.”라고 판시하여 무효인 전부채권자에 대한 변제가 채권의 준점유자에 대한 변제인지 여부에 관해 언급하지 않고 단지 그것으로써 다른 압류채권자에게 대항할 수 없다는 취지이다.

이와 같은 판례의 태도에 비추어보면 제3채무자가 선의, 무과실인 경우에 그는 채무를 면하고, 그가 아닌 채무자 또는 다른 압류채권자가 변제를 받은 채권자에 대하여 부당이득반환청구권을 행사하여야 할 것이다.

다. 나아가 어떠한 경우에 제3채무자의 선의·무과실, 특히 무과실을 인정할 수 있는가 하는 점이 또한 문제로 되는데, 이는 압류 등의 경합으로 전부명령이 무효인 경우에 주로 논의된다.

판례는 이 경우 일반적으로 무효인 전부명령에 의한 전부채권자에 대한 변제는 선의·무과실에 의한 것이라 하면서도 실제로 있어서는 변제를 한 제3채무자에게 과실이 있었다고 인정하여 유효한 변제가 아닌 것으로 보고 있다.⁷⁴⁾ 이에 대하여 학설은 제3채무자가 일반사법도 아닌 채권에 관한 강제집행절차의 해석을 몰랐다고 하여 과실이 있다고 하는 것은 가혹하므로 과실이 없었던 것으로 인정함이 상당하다는 견해,⁷⁵⁾ 여러 가지의 사정을 고려하여 특별한 사정이 있는 경우에 준점유자에 대한 변제로서 제3채무자의 면책을 인정해야 할 것이라는 견해,⁷⁶⁾ 채권자의 경합이 있는 경우 전부명령이 무효라는 것은 현재의 법률상식이 되었으므로 이 경우 변제를 한 제3채무자에게 적어도 과실은 인정되어 그의 면책이 인정될 여지가 없다는 견해⁷⁷⁾ 등이 나오고 있다.

생각건대 이 경우 제3채무자로서는 다른 채권자의 배당요구가 있거나 압류가 경합된 경우 뿐 아니라 압류채권자가 1인인 때에도 공탁에 의하여 채무를 면할 수 있는 점(민집 제248조 제1항)을 고려하면, 이 경우 전부채권자에게 변제를 한 제3채무자의 무과실이 인정될 수 있는 여지는 실제로 거의 없을 것이다.

74) 대법원 1980. 9. 30. 선고 78다1292 판결; 앞서 본 대법원 1988. 8. 23. 선고 87다카546 판결 참조; 다만 위 87다카546 판결은 이러한 경우 제3채무자의 변제행위는 경합하는 압류채권자의 채권을 침해하는 불법행위가 된다고 하고 있으나, 제3채무자의 변제가 무효라면 압류채권자로서는 채무자의 제3채무자에 대한 채권이 여전히 존재하는 것으로 보아 그에 대하여 강제집행을 할 수 있을 것이므로 제3채무자의 변제로 인하여 손해를 입었다고 보기는 어려울 것이다.

그 밖에 대법원 1995. 4. 7. 선고 94다59868 판결(甲의 전부명령을 송달받기 이전에 이미 乙의 가압류결정을 송달받았을 뿐만 아니라, 을이 제기한 전부금 청구소송에서 乙의 전부명령을 압류 또는 가압류가 경합된 상태에서 발하여진 것으로서 무효라는 주장을 스스로 제기한 바 있음에도, 그 후 甲이 제기한 전부금 소송절차에서 乙의 압류가 경합되어 있다는 주장을 내세우지도 아니함으로써 패소판결을 받고 바로 그 전부금을 변제하여 버렸다면, 제3채무자로서는 乙의 전부명령은 물론 甲의 전부명령 또한 乙의 가압류와 경합된 상태에서 발하여진 것으로서 무효라는 것을 알았거나 알 수 있었다는 이유로 위 제3채무자가 한 변제의 효력을 부인한 사례)

75) 이재성(주16), 184.

76) 我妻榮, 新訂債權總論, 岩波書店(昭和40), 275.

77) 남기정(주9), 245.; 宮脇幸彦(주71), 240.

II. 전부명령의 내용

전부명령에는 사건번호, 당사자의 표시, 압류된 채권, 앞서 발령한 압류명령, 압류된 채권을 지급에 갈음하여 압류채권자에게 이전한다는 취지의 선언, 결정날짜, 집행법원의 표시 및 판사(사법보좌관)의 기명날인이 있어야 한다.⁷⁸⁾

전부명령은 집행행위이지만 결정의 일종으로서 그 성질에 반하지 않는 한 판결 경정규정(민소 제211조)이 준용되므로(민소법 제224조) 전부명령에 위산, 오기, 그 밖에 이에 유사한 오류가 있는 것이 명백한 때에는 법원은 직권 또는 당사자의 신청에 의하여 경정결정을 할 수 있다.

통상 전부명령상의 당사자나 집행채권 피전부채권의 표시가 집행정본이나 신청서의 기재와 다를 경우이거나 이자·지연손해금의 오산이 있는 경우 또는 신청서의 기재 자체가 전부명령 전에 제출된 다른 소송자료에 비추어 명백한 오류가 있었고, 이로 인하여 전부명령에도 잘못 기재된 경우에 경정의 대상으로 된다.

그러나 전부명령의 동일성이 침해되지 않는 범위 내에서만 경정이 허용됨은 판결의 경정과 같으므로 경정결정은 전부명령의 원본과 정본의 여백에 부기하여 행함이나 원칙이나 전부명령정본이 송달된 후에는 따로 경정결정서를 작성하여 당사자에게 송달하여야 하며, 이 경정결정이 제3채무자에게 송달되면 전부명령 송달시에 소급하여 효력이 발생한다.⁷⁹⁾

III. 전부명령과 공탁

이와 같이 전부명령이 발령된 경우에 있어서 제3채무자의 공탁에 대한 문제에 관하여는 제8장 집행공탁 제2절 VIII. 이하에서 자세히 다루고 있으므로 여기서는 상론하지 아니한다.

78) 별지서식 [5-2] 채권전부명령 및 [5-3] 채권압류 및 전부명령 참조(제5장 말미 수록)

79) ① 경정결정과 관련하여 판례의 입장 중 소급효를 인정한 예 → 대법원 1998. 2. 13. 선고 95다15667 판결(사망자를 제3채무자로 표시하여 채권압류 및 전부명령을 받았다가 제3채무자 표시를 사망자에서 그 상속인으로 경정하는 경정결정의 경우)

② 소급효를 부정한 예(경정결정이 송달된 때에 효력 발생) → 대법원 1999. 12. 10. 선고 99다42346 판결(당초 채무자의 상호 '만성기계산업 주식회사'를 경정결정에 의하여 '민성산업기계 주식회사'로 경정한 경우), 대법원 2001. 7. 10. 선고 2000다72589 판결(채권압류 및 추심명령을 채권압류 및 전부명령으로 경정한 결정), 대법원 2005. 1. 13. 선고 2003다29937 판결(채권압류명령의 채무자를 '척산개발'에서 '광산중건'으로 변경하는 경정결정) 등

IV. 전부명령의 효력

1. 효력과 그 발생시기 등

가. 전부명령의 기본적인 효력은 피전부채권의 전부채권자에게의 이전(권리이전 효과)과 그로 인한 집행채권의 소멸(변제효)이다.

나. 한편 다음에 자세히 보듯이 전부명령이 발부되고 그 명령이 적법하게 송달되었다 하더라도 전부명령의 내용이 되는 피전부채권이 존재하지 아니한 때에는 집행채권 소멸 등과 같은 전부명령의 효력이 발생하지 아니하고,⁸⁰⁾ 그 전부명령은 실체상 무효이다.

채무자가 수인이거나 제3채무자가 수인인 경우 또는 채무자가 제3채무자에 대하여 여러 채권을 가지고 있는 경우, 전부명령에 각 채무자나 제3채무자별로 얼마씩의 전부를 명하는 것인지 또는 채무자의 어느 채권에 대하여 얼마씩의 전부를 명하는 것인지를 특정하여야 하고, 이를 특정하지 않은 전부명령의 효력은 무효이다.⁸¹⁾ 따라서 채권자들이 채무자의 제3채무자인 정리회사에 대한 공사도급계약 해제로 인한 '계약이행보증금등의 청구채권'에 대한 압류 및 전부명령을 받은 경우, 그 압류 및 전부명령에서 대상채권을 '계약이행보증금등의 청구채권'이라고 표시한 것만으로는 이를 정리채권의 일부인 '지체상금채권'에 대한 압류 및 전부명령으로 볼 수 없다.⁸²⁾

80) 대법원 1992. 4. 15.자 92마213 결정【결정요지】[1] 현행 민사소송법 제561조와 제563조는 구 민사소송법(1990.1.13. 법률 제4201호로 개정되기 전의 것)과는 달리 금전채권의 압류 및 전부명령의 신청에 관한 재판에 대하여 즉시항고를 할 수 있도록 규정하고, 또 전부명령은 확정되어야 효력이 있다고 규정하고, 같은 법 제564조는 전부명령이 확정된 경우에는 전부명령이 제3채무자에게 송달된 때에 채무자는 채무를 변제한 것으로 본다고 규정하고 있으므로 확정되지 아니한 전부명령에 의하여 변제의 효과가 발생하고 강제집행절차가 종료할 수는 없다. [2] 채권의 압류 및 전부명령은 금전채권의 채무명의를 가지는 채권자가, 그 채무명의상의 채무자가 제3채무자에 대하여 가지는 금전채권을 대상으로 하는 강제집행으로서, 법원은 압류 및 전부명령의 결정을 함에 있어서는 채무명의의 송달, 선행하는 압류명령의 존부, 피전부적격의 유무 등의 요건을 심리하면 되고, 실제로 채무자가 제3채무자에게 압류 및 전부명령의 대상이 되는 채권을 가지고 있는지 여부는 따질 필요가 없는 것이 원칙이고, 만일 채무자의 제3채무자에 대한 그와 같은 채권이 존재하지 아니하는 경우에는 전부명령이 확정되더라도 변제의 효력이 없는 것이며, 채무자로서는 제3채무자에게 그와 같은 채권을 가지고 있지 않다고 하더라도 특별한 사정이 없는 한 이로 인하여 어떠한 불이익이 있는 것이 아니므로 이것을 이유로 하여서는 스스로 불복의 사유로 삼을 수 없다.

81) 대법원 2004. 6. 25. 선고 2002다8346 판결; 대법원 2010. 6. 24. 선고 2007다63997 판결; 대법원 2014. 5. 16. 선고 2013다52547 판결

82) 대법원 2010. 6. 24. 선고 2007다63997 판결(채권자들이 채무자의 제3채무자인 정리회사에 대한 공사도급계약상 '계약이행보증금채권'에 대하여 압류 및 전부명령을 받은 사안에서, 위 계약이행보증금이 지체상금과 마찬가지로 손해배상액의 예정으로서의 성질을 갖는 것으로서 정리채권확정소송에서 계약이행보증금의 액수를 초과하는 지체상금이 손해배상액으로 인정되었다고 하더라도, 집행대상의 명확성을 요하는 전부명령의 본질에 비추어, 위 압류 및 전부명령에서 집행대상 채권으로 기재하고 있는 '계약이행보증금채권'을 '지체상금채권'과 동일하게 볼 수 없을 뿐만 아니라 이를 '지체상금채권'에 대한 압류 및 전부명령으로서 효력을 갖는다고 볼 수도 없다고 한 사례)

다. 전부명령의 효력은 전부명령의 확정시, 즉 즉시항고가 제기되지 않은 경우에는 1주일의 즉시항고기간이 경과한 때, 즉시항고가 제기된 경우에는 그 기각 또는 각하결정이 확정된 때에 발생하지만(민집 제229조 제7항), 그 확정에 의하여 발생하는 효력은 전부명령이 제3채무자에게 송달된 때로 소급한다(소급효). 다시 말해 전부명령이 제3채무자에게 송달된 때에 채무자는 채무를 변제한 것으로 볼 뿐만 아니라(민집 제231조), 전부명령이 제3채무자에게 송달될 때까지 그 금전채권에 관하여 압류 등이 경합되면 전부명령은 무효이지만 압류의 경합이 전부명령 송달 뒤에 발생하였다면 비록 그 전부명령이 확정되기 전이었다 하더라도 이는 전부명령의 효력에 영향을 미치지 않는다(민집 제229조 제5항).

이와 같이 전부명령의 효력이 확정시에 발생하는 것으로 하면서도 그 효력에 소급효를 인정한 것은 전부명령이 확정될 때까지 경합하는 채권자등이 출현하는 경우 위 전부명령의 효력을 인정하지 않는다면 채권자에게 독점적 만족을 줄 수 있는 전부명령의 실효성이 약화될 수 있기 때문이다.⁸³⁾

라. 민사집행법 제233조의 지시채권에 대한 전부명령의 효력발생시기에 관하여는 채권자가 전부명령정본에 기초하여 집행관으로부터 증권을 교부받은 때라고 하는 입장도 있으나, 그 효력발생시기는 다른 전부명령과 다를 것이 없고 증권의 채권자에의 인도는 채권을 행사하는 자격의 문제에 불과하다고 보아야 할 것이다.⁸⁴⁾

마. 원인채무의 이행을 위하여 제3채무자가 자기의 채권자에게 어음이나 수표를 발행교부하고 그 뒤에 원인채권이 압류되었는데, 그 압류 뒤에 어음금이나 수표금을 지급한 때에는 그 지급에 따라 원인채권이 소멸한 것을 압류채권자에게 대항할 수 있고, 따라서 위 원인채권을 목적으로 하는 채권압류·전부명령은 효력이 생기지 않는다.⁸⁵⁾

바. 채권자가 약속어음금 채권을 집행채권으로 하여 약속어음 채무자가 제3채무자에 대하여 가지는 채권의 압류 및 전부명령을 받아 확정되었다면 위 전부명령이 제3채무자에게 송달된 때에 소급하여 피전부채권이 채권자에게 이전하고, 이는 집행채무자가 채무의 이행에 갈음하여 현실적인 출연을 한 것과 법률상 동일하게 취급되어 집행채권인 약속어음금 채권은 변제된 것으로 보아 소멸한다. 이와 같이 집행채권인 약속어음금 채권

83) 박두환(주31), 244.; 鈴木忠一 外, 위 注解民事執行法(4), 625.

84) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 397.

85) 대법원 1994. 3. 25. 선고 94다2374 판결; 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 397-398.

이 전부명령의 확정에 의하여 소멸한 경우, 그 시점에 약속어음금 채권에 의하여 담보되는 원인채권인 대여금채권도 같은 액수만큼 변제로 인하여 확정적으로 소멸하게 된다.⁸⁶⁾

사. 채권압류 및 전부명령의 주문에 압류·전부되는 채권들이 모두 명시되어 있는 이상 그 명령의 이유에 압류·전부되는 채권 중 일부 채권에 관한 집행권원의 기재가 누락되어 있다고 하더라도 그와 같은 사정만으로 그 집행권원의 기재가 누락된 일부 채권에 대하여 위 압류·전부명령의 효력이 미치지 않는다고 볼 수는 없다.⁸⁷⁾

아. 국세기본법 제51조 제2항에 의한 국세환급금의 충당의 효력은 그 행위가 행하여진 날로부터 장래에 향하여서만 발생하므로 국세환급금에 의한 충당이 행하여진 경우 충당된 국세의 납기에 소급하여 환급금의 반환채무가 소멸한다고 볼 수 없는 바, 국세환급금으로 충당한 납세자에 대한 관세채권이 국세환급금에 대한 압류 및 전부명령의 송달 전에 발생한 것이라 하더라도 그 충당이 위 송달 후에 행하여진 이상 과세관청은 전부채권자에게 대항할 수 없다.⁸⁸⁾

자. 전부명령이 확정된 후 그 집행권원상의 집행채권이 소멸한 것으로 판명된 경우에는 소멸 부분에 관하여는 집행채권자가 집행채무자에 대한 관계에서 부당이득을 한 셈이 되므로 집행채권자는 위 전부명령에 따라 전부받은 채권 중 실제로 추심한 금전 부분에 관하여는 그 상당액을, 추심하지 아니한 부분에 관하여는 그 채권 자체를 집행채무자에게 양도하는 방법으로 반환하여야 한다.⁸⁹⁾

2. 피전부채권의 이전

가. 채권이전의 범위

1) 전부명령에 의하여 피전부채권은 집행채권 범위 안에서 그 동일성을 유지한 채로 전부채권자에게 이전된다. 따라서 피전부채권이 집행채권과 집행비용의 합산액보다 적으면 피전부채권의 전액이 이전되지만, 피전부채권이 위 합산액보다 많으면 그 합산액을 한도로 이전된다.⁹⁰⁾ 이는 지명채권양도의 경우와 그 효과가 동일하나

86) 대법원 2009. 2. 12. 선고 2006다88234 판결

87) 대법원 2009. 11. 26. 선고 2006다37106 판결

88) 대법원 2008. 7. 24. 선고 2008다19843 판결

89) 대법원 2010. 12. 23. 선고 2009다37725 판결

90) 대법원 1984. 6. 26. 선고 84마13 판결; 대법원 1995. 9. 26. 선고 95다4681 판결; 대법원 2004. 5. 28. 선고 2004다6542 판결; 방순원(주), 290.

다만 전부명령에 의한 피전부채권의 이전은 집행행위에 기초한 것이므로 채권양도의 대항요건에 관한 민법의 규정은 적용되지 않는다.⁹¹⁾

전부명령이 제3채무자에게 송달될 당시에 채무자가 제3채무자에 대하여 가지는 채권은 이전되지만,⁹²⁾ 전부명령 송달 뒤에 발생한 채권은 이전되지 않는다.⁹³⁾

2) 전부명령으로 인한 이전의 효력은 피전부채권의 종된 권리, 즉 전부 후의 이자 및 지연손해금, 물적담보(저당권 등) 등에도 미친다.

보증인에 대한 경우에는, 보증인에게 별도로 전부명령을 송달하지 않아도 보증인에 대한 채권도 전부채권자에게 이전한다는 견해⁹⁴⁾와 보증인에 대한 별도의 압류명령이 없으면 보증인에게는 압류의 효력이 미치지 않는다는 견해⁹⁵⁾가 나타나고 있으나, 보증채무의 부종성과의 관계에서 보증인에 대한 별도의 압류 및 전부명령을 요하지 않으며 주채무자에 대한 압류명령등을 보증인에게 송달하지 않더라도 주채무자에 대해 송달함으로써 압류등의 효력이 생긴 때에는 보증채무에 대하여도 압류 및 전부명령의 효력이 생긴다고 보아야 할 것이다.⁹⁶⁾

그러나 임차인의 임대차보증금 반환청구권에 대한 전부명령의 효력은 임차인의 임대인에 대한 부속물매수대금청구권에는 미치지 아니한다.⁹⁷⁾ 그리고 전부명령에 의

91) 민사집행법, 사법연수원(2012), 324.; 대법원 1993. 9. 28. 선고 92다55794 판결 참조

92) 대법원 1977. 6.28. 선고 77다66 판결; 대법원 1977. 8. 23. 선고 76다2123 판결; 대법원 1989. 2. 28. 선고 88다카13394 판결 【판결요지】채권에 대한 압류명령은 압류목적채권이 현실로 존재하는 경우에 그 한도에서 효력을 발생할 수 있는 것이고 그 효력이 발생된 후 새로 발생한 채권에 대하여는 압류의 효력이 미치지 아니한다.

93) 대법원 1965. 4.27. 선고 65다142 판결; 대법원 1981. 9. 22. 선고 80누484 판결 【판결요지】[1] 채권압류 및 전부명령 송달 당시에 피전부채권이 이미 제3자에 대한 대항요건을 갖추어 양도되었다가, 위 전부명령 송달 후에 위 채권양도 계약이 해제되어, 동 채권이 원채권자에게 복귀하였다고 하여도 동 채권은 위 압류채권자에게 전부되지 아니한다. [2] 공사금채권에 대한 압류 및 전부명령은 그 송달 후 체결된 추가 공사계약으로 인한 추가 공사금채권에는 미치지 아니한다.

94) 이재성(주16), 189.;鈴木忠一 外, 위 注解民事執行法(4), 622. 등

95) 宮脇幸彦(주71), 115.; 남기정(주9), 81. 등

96) 위 법원실무제요 민사집행(III), 399.

97) 대법원 1981. 11. 10. 선고 81다378 판결 【판결요지】[3] 임차인의 채권자가 임차인의 임대인에 대한 임대보증금반환채권 중 일부에 대한 전부명령을 받았다면 임차인이 임대인으로부터 받을 수 있는 임대차보증금 잔액(연체차임과 기타 손해 등을 공제한 잔액)을 확정하여 전부 채권자에게 전부된 채권잔액을 특정하여야 하고, 위 잔액이 전부 채권자의 청구금액에 미달된다고 하여도 그 전부명령은 임대차보증금에 대한 것이므로 임차인의 임대인에 대한 부속물매수대금채권에는 미치지 아니한다. [4] 임차인이 임대인의 동의를 얻어 전대한 경우에 전차인은 임대인에 대하여 그 사용의 편익을 위하여 임대인의 동의를 얻어 시설한 부속물의 매수청구권을 행사할 수 있고, 임대인을 대위하여 명도청구를 하는 원고에 대하여도 부속물 매수대금 지급시까지의 연기적 항변권을 주장할 수 있다.

한 민사집행법 제233조의 지시채권의 이전은 지명채권양도의 효력밖에 없으므로 인적항변 절단의 효과는 생기지 않는다.⁹⁸⁾

3) 집행력 있는 집행권원에 기하여 채권압류 및 전부명령이 적법하게 이루어진 이상 피압류채권은 집행채권의 범위 내에서 당연히 집행채권자에게 이전한다 할 것이어서 그 집행채권이 이미 소멸하였거나 실제 채무액을 초과하더라도 그 채권압류 및 전부명령에는 아무런 영향이 없고, 제3채무자로서는 채무자에 대하여 부담하고 있는 채무액의 한도 내에서 집행채권자에게 변제하면 완전히 면책된다.⁹⁹⁾

4) 집행채권에 수개의 채권이 표시된 경우 또는 채권의 일부에 대하여 집행을 구하는 경우에는 어느 채권을 위해 집행을 구하는지를 명백히 하여야 한다. 따라서 집행권원에 완제일까지 이자, 지연손해금 등의 부대청구가 인정되어 있고 이를 원금에 부기하여 청구하는 때에는 그 뜻을 명확하게 하여야 한다. 그리고 전부명령에 의한 채무소멸의 효과는 채권자가 압류명령 신청시에 명시한 집행채권의 변제를 위해서만 생긴다.¹⁰⁰⁾ 다만 채권자가 원금과 이에 대한 변제일까지의 부대채권을 집행채권으로 하여 전부명령을 받은 경우에는 집행채권의 원금의 변제일은 전부명령이 제3채무자에게 송달된 때가 되어 결국 집행채권액은 원금과 제3채무자에 대한 전부명령 송달시가지의 부대채권액을 합한 금액이 된다. 따라서 피압류채권(피전부채권)은 그 금액 범위 안에서 전부채권자에게 이전한다.¹⁰¹⁾

5) 장래의 채권에 관하여 압류 및 전부명령이 확정되면 그 부분 피압류채권은 이미 전부채권자에게 이전된 것이므로 그 이후 동일한 장래의 채권에 관하여 다시 압류 및 전부명령이 발하여졌다고 하더라도 압류의 경합은 생기지 않고, 다만 장래의 채권 중 선행 전부채권자에게 이전된 부분을 제외한 나머지 중 해당 부분 피압류채권이 후행 전부채권자에게 이전된다.¹⁰²⁾

또한 장래에 계속적으로 발생하는 피압류채권 중 청구금액에 이를 때까지의 부

98) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 399.

99) 대법원 2004. 5. 28. 선고 2004다6542 판결

100) 대법원 1996. 4. 12. 선고 95다55047 판결(따라서 채권자가 청구금액을 '대여금 중 일부금'으로 표시한 채권압류 및 전부명령을 신청한 경우, 집행권원상의 대여금채권만이 집행채권으로 되었을 뿐 그 이자나 지연손해금은 집행채권으로 되었다고 할 수 없으므로 원금과 이자 사이의 변제충당에 관한 문제가 발생할 여지가 없다는 취지로 판시). 전부명령은 압류된 금전채권을 그 권면액으로 채권자에게 이전시키고 그 대신 같은 금액 상당의 집행채권을 소멸시킴으로써 채무자의 채무변제에 갈음하게 하는 제도이기 때문이다.

101) 대법원 1999. 12. 10. 선고 99다36860 판결

102) 대법원 2004. 9. 23. 선고 2004다29354 판결

분에 대한 전부명령이 송달·확정되면, 계속적으로 발생하여 그 합계액이 청구금액에 이를 때까지의 채권은 전부채권자에게 당연히 이전하고 동시에 같은 금액의 집행채권이 소멸한다. 따라서 전부채권자가 위와 같이 당연히 이전하는 장래의 계속적 수입채권 중 그 중 일정한 기간을 임의로 지정하여 그 기간 동안에 발생하는 채권을 지급받지 않는 대신 그 기간 경과 후에 발생하는 채권을 자신에게 지급하도록 제3채무자에게 요청하거나 제3채무자와 합의하였다고 하더라도, 이로 인하여 이미 전부명령에 의하여 특정되어 전부채권자에게 이전되는 피전부채권의 범위가 변경되는 것은 아니다. 그리고 장래의 계속적 수입채권이 발생하여 존재하고 그 합계가 청구금액에 이르게 된 이상, 전부채권자가 그 전부 또는 일부를 현실적으로 변제받지 못하였다고 하더라도 전부명령의 효력이 실효되거나, 청구금액에 이르게 된 이후 새로이 발생한 계속적 수입채권에 대하여 전부명령의 효력이 미치게 되는 것도 아니다.¹⁰³⁾

나. 전부채권자의 지위

1) 전부의 효과에 따라 피전부채권이 전부채권자에게로 이전되고, 민법상의 채권양도와 마찬가지로 전부채권자는 피전부채권의 채권자로서의 지위를 승계한다.

즉 전부채권자는 원래의 채권자인 집행채무자에 갈음하여 그의 채권을 취득하며, 자기의 채권으로서 이를 자유롭게 처분할 수 있다. 따라서 이를 추심하거나 양도 또는 포기 등의 일체의 행위를 할 수 있다.

2) 피전부채권은 동일성을 유지하면서 전부채권자에게 이전하므로 종된 권리, 피전부채권을 담보하는 담보권도 이전한다.

피전부채권의 이전은 전부의 효과로서 당연히 생기고, 채권양도와 같은 대항요건 즉 제3채무자에 대한 통지나 승낙을 요하지 아니하며, 그것 자체로 제3채무자와 제3자에게 대항할 수 있다.

3) 전부채권자는 채권을 양도받은 경우와 같이 제3채무자가 임의로 변제하지 않을 때에는 그에 대하여 민사집행법 제238조에 따라 이행을 구하는 소송을 제기할 수 있다.

이 경우에는 집행채무자에 대하여 소송고지를 하여야 한다(민집 제238조). 민사집행법 제233조의 지시채권에 대한 전부명령을 받은 채권자의 경우에는 그 정본을 집행관에게 제시하여 증권을 교부받을 수 있다.

4) 또한 전부명령이 효력을 발생할 당시에 집행채무자가 제3채무자에 대하여 이

103) 대법원 2011. 2. 10. 선고 2010다88941 판결

행을 구하는 소가 이미 소송계속중이면 전부채권자는 권리승계인으로서 그 소송에 승계참가를 할 수 있고(민소 제81조, 제82조), 피전부채권에 관하여 강제집행이나 담보권실행절차가 진행되고 있으면 이를 수계할 수 있다.

5) 전부채권자가 그 채권을 위하여 설정된 저당권의 실행을 위한 경매신청을 하거나 경매절차를 수계하기 위하여 저당권이전의 등기를 하여야 하는가에 대하여는 견해가 나뉘어지고 있으나, 이러한 전부채권자의 저당권취득은 법률의 규정에 의한 부동산물권변동(민법 제187조)에 해당하므로 저당권이전의 부기등기가 저당권실행을 위한 요건은 아니라고 보아야 할 것이다.¹⁰⁴⁾

한편, 전부명령이 확정됨으로써 집행채권에 관한 집행절차는 종료되므로 이러한 피전부채권의 추심을 위한 비용은 원래의 집행채권을 위한 집행비용에는 포함되지 아니하고 채권자가 부담할 성질의 것이다.

6) 집행채무자가 피전부채권에 관하여 이미 얻은 집행권원이 있으면 승계집행문을 부여받아 강제집행에 착수할 수 있다.

만일 집행채무자가 전부명령이 있었음에도 불구하고 집행권원에 채권자가 자기 이름으로 되어 있는 것을 기화로 하여 집행문을 부여받는다면 제3채무자가 집행문부여에 대한 이의를 신청할 수 있고, 집행채권자로서도 집행문부여에 대한 이의신청을 할 수 있다고 볼 것이다.^{105) 106)}

7) 전부명령의 효력이 발생한 후에 집행채무자가 파산하더라도 전부명령의 효력에는 원칙적으로 영향이 없다. 다만 채무자 회생 및 파산에 관한 법률상의 부인권의 대상이 될 수 있음은 별개의 문제이다.

또한 전부명령이 발령되었다거나 확정되었다는 것만으로 피전부채권의 소멸시효가 중단되지 않음은 압류명령에 있어서와 같다.

8) 전부채권자가 제3채무자와 같은 때에는 피전부채권은 혼동의 법리(민법 제507조)에 따라 소멸한다.

다만 상계금지의 요건에 해당하고 또 그 상계금지의 취지가 공익적인 이유 또는 당사자간의 이익형량에 의하여 채무의 현실적인 이행을 요구하는 것인 때에도 전부채권자에 대하여 채권의 전부명령을 할 수 있는가가 문제로 되는데, 이에 관하여는 이

104) 남기정(주9), 232.; 이에 반대하는 견해로는 김정현, 경매실무요론(上), 사법행정학회, 74.

105) 이재성(주16), 176-177.; 남기정(주9), 232.; 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 400.

106) 다만 대법원 1973. 5. 22. 선고 70다1090 판결은 “채권자의 승계인에 대하여 승계집행문을 부여하였을 때에는 채무자(여기서는 제3채무자)만이 그 승계사실을 다투어 그 집행문부여에 대한 이의의 소를 제기할 수 있다.”라고 판시하고 있다.

경우 상계금지의 취지를 잠탈하는 것이므로 허용할 수 없다는 견해¹⁰⁷⁾도 있으나, 상계금지의 채권에 대하여도 전부명령의 결과 혼동에 의하여 상계가 되는 것과 같은 결과가 되어도 무방하다는 취지의 견해¹⁰⁸⁾도 등장하고 있다.

9) 이와 관련하여 여기서 잠깐 살펴보고 갈 것은, 임차인의 임대차보증금 반환청구채권에 관하여 전부명령이 있는 경우에 대한 다음과 같은 문제들이다.

즉 먼저 임대차가 종료되더라도 제3채무자인 임대인으로서의 채무자인 임차인이 임대차목적물을 반환하기까지는 보증금반환청구채권의 지급을 거절할 동시이행의 항변권을 행사할 수 있으므로 채무자인 임차인이 임대차목적물을 반환할 때까지는 전부 받은 임대차보증금반환청구채권을 행사할 수 없고 극단적으로는 위 임대차보증금에서 차임 내지 차임 상당의 손해배상액이 공제되어 임대차보증금이 한 푼도 남지 않게 되는 결과도 생길 수 있다. 이러한 결과를 방지하기 위해서는 전부채권자가 채무자인 임차인에 대하여 임대인에게 임대차목적물을 반환할 것을 청구할 수 있도록 할 필요가 있는데, 그렇게 청구할 수 있는 근거가 무엇인지가 문제로 된다.

이에 대해서 실무상 이 경우 채권자대위권의 법리에 의하여 전부채권자로서는 제3채무자인 임대인을 대위하여 그가 무자력이 아니더라도 그의 임차인에 대한 임대차목적물 인도청구권을 대위행사할 수 있다는 견해¹⁰⁹⁾와 이를 부정하는 견해¹¹⁰⁾가 있었으나, 대법원¹¹¹⁾은, “채권자가 자기 채권을 보전하기 위하여 채무자의 권리를 행사하려면 채무자의 무자력을 요건으로 하는 것이 통상이지만 임대차보증금반환채권을 양수한 채권자가 그 이행을 청구하기 위하여 임차인의 가옥인도가 선이행되어야 할 필요가 있어서 그 인도를 구하는 경우에는 그 채권의 보전과 채무자인 임대인의 자력 유무는 관계가 없는 일이므로 무자력을 요건으로 한다고 할 수 없다.”라고 판시하였는바, 이러한 이론은 임대차보증금반환청구권이 전부된 경우에도 동일하게 적용될 수 있을 것이다.¹¹²⁾

또한 이에 대하여는 이러한 경우 전부채권자가 임대인을 대위한다는 우회적인 법률구성보다는 원래 집행채권의 채무자인 임차인으로서의 전부채권에 대하여 그가 집행채권을

107) 남기정(주9), 233.; 宮脇幸彦(주71), 12, 157. 등

108) 이재성(주16), 173-174.

109) 대구고등법원 1986. 7. 24. 선고 86나229 판결(하판집 1986년 3권 57-58.); 대구지방법원 1988. 2. 10. 선고 87나485 판결(하판집 1988년 1권 229-230.)

110) 서울민사지방법원 1988. 10. 26. 선고 88나25184 판결(하판집 1988년 3·4권, 105.)

111) 대법원 1989. 4. 25. 선고 88다카4253, 4260 판결

112) 이재성, “임대차보증금반환청구권의 양도와 그 추심”, 황적인 화갑기념손해배상법의 제문제, 777. 이하; 김종대(주30), 141.

실효있게 회수할 수 있도록 협력해야 할 의무(협력의무, Mitwirkungspflicht)가 있다는 전제하에 비록 전부명령에 의하여 형식적으로 집행채권이 소멸하였다 하더라도 임대차가 종료된 때에는 임대인에게 임대차목적물을 인도함으로써 전부채권자가 채권을 회수할 수 있도록 협력해야 할 의무는 여전히 잔존하므로(이른바 사후적인 성실의무, Nachwirkende Treupflicht), 전부채권자로서는 채무자인 임차인에 대하여 임대인에게 임대차목적물을 인도할 것을 임대인에게 대위해서가 아니라 자기의 권리로서 청구할 수 있다고 보아야 한다는 견해¹¹³⁾도 제기되고 있다. 그러나 전부명령에 의하여 피전부채권이 이전됨으로써 집행채권이 이미 소멸하였는데 그 이후에 과연 채무자에게 그와 같은 의무를 법률상 인정할 수 있을 것인가에 관하여 여전히 의문이 남게 되므로 선뜻 수긍하기 어렵다.

10) 임대차와 관련된 또 한가지 문제는, 임대차보증금반환청구권이 압류·전부된 이후에 임차인이 임대인과 합의에 의하여 임대차기간을 연장하거나 법정갱신할 수 있는가 하는 점이다.

그러나 임대차목적물의 인도에서와 같이 채무자인 임차인은 전부채권자에 대한 관계에 있어서는 보증금반환청구권의 실현에 방해가 되는 기간의 갱신 내지 법정갱신을 해서는 안 될 의무를 부담한다고 보아야 하고, 전부명령의 송달을 받은 제3채무자인 임대인으로서도 그와 같은 사정을 알 수 있을 것이므로 전부명령 송달 후에 임차인과 임대인 사이에 기간연장의 합의가 있었다 하더라도 제3채무자인 임대인으로서 전부명령 후에 발생한 그러한 사유를 이유로 하여 전부채권자에게 대항할 수 없다고 보아야 할 것이다.¹¹⁴⁾

11) 재판상 담보공탁¹¹⁵⁾에 있어 담보권리자(피공탁자)는 담보물에 대하여 질권자와 동일한 권리가 있는바(민소 제123조), 담보권리자가 공탁금회수청구권을 압류하고 추심명령이나 확정된 전부명령을 받은 후 담보취소결정을 받아 공탁금회수청구를 하는

113) 김능환·민일영 편집대표, 위 주석민사집행법[V], 492.

114) 김능환·민일영 편집대표, 위 주석민사집행법[V], 492.; 한기택, “임대차보증금반환청구권을 양수한 자의 임대인의 임차인에 대한 목적물명도청구권의 대위행사”, 민사판례연구 12권, 43-45.도 같은 취지로 보인다.

115) 담보공탁이라 함은 장래 피공탁자에게 발생할 손해배상채권을 담보하기 위한 공탁이다. 이러한 담보공탁의 종류로는 재판상 담보공탁, 영업보증공탁, 납세담보공탁 등이 있다. 그 중 재판상 담보공탁은 당사자의 소송행위(소송비용의 담보)나 가압류·가처분, 강제집행의 정지, 실시, 취소 등 법원의 처분으로 인하여 담보권리자가 받게 될 손해를 담보하기 위한 공탁이고, 영업보증공탁은 영업거래 등으로 발생할 피해자의 손해배상채권 등을 담보하기 위한 공탁이며, 납세담보공탁은 국세, 지방세 등의 징수유예나 상속세나 증여세의 연부연납 등의 허가시 그 세금의 납부나 징수를 담보하기 위한 공탁이다. 담보공탁은 공탁물에 대하여 피공탁자 등 일정한 상대방에게 일종의 우선변제권을 부여함으로써 담보제공의 기능을 하게 된다.

경우에도 그 담보공탁금의 피담보채권을 집행채권으로 하는 것인 이상, 담보권리자의 위와 같은 담보취소신청은 어디까지나 담보권을 포기하고 일반 채권자로서 강제집행을 하는 것이 아니라 오히려 적극적인 담보권실행에 의하여 그 공탁물회수청구권을 행사하기 위한 방법에 불과하다고 보는 것이 합리적이므로 이는 담보권의 실행방법으로 인정된다. 따라서 이 경우에도 질권자와 동일한 권리가 있다고 할 것이므로 그에 선행하는 일반 채권자의 압류 및 추심명령이나 전부명령으로 이에 대항할 수 없다.¹¹⁶⁾

다. 집행채무자의 지위

전부명령에 의하여 집행채무자는 피전부채권을 상실하게 된다. 전부명령이 형식적으로 유효한 집행권원에 기초한 것이었다면 비록 집행채권이 전부명령 당시에 이미 소멸하였거나 또는 집행권원이 가집행선고부 판결이었는데 후에 그 가집행선고가 실효되더라도 이러한 피전부채권 상실의 효과에는 변함이 없다.¹¹⁷⁾

다만 집행채권이 존재하지 않았던 때에는 그 자가 배당절차에서 배당을 수령한 경우와 마찬가지로 채무자는 채권자에게 부당이득반환을 청구할 수 있다.¹¹⁸⁾ 그리고 무효인 집행권원에 기초한 강제집행의 경우에는 전부명령의 요건을 충족하더라도 전부의 효력이 생기지 않는다.

또한 임차인의 임대인에 대한 보증금반환청구채권이 전부된 경우에도 임차인의 건물인도의무와 임대인의 보증금반환의무 사이의 동시이행관계는 존속하므로 임대인이 임차인에게 보증금반환의무를 이행하거나 그 현실적인 이행의 제공을 하지 않는 한 임차인의 건물인도의무는 이행지체에 빠지지 않는다는 것이 판례¹¹⁹⁾의 입장이나,

116) 대법원 2004. 11. 26. 선고 2003다19183 판결

117) 대법원 1976. 5. 25. 선고 76다626 판결【판결요지】집행력 있는 채무명의에 기하여 채권압류 및 전부명령이 적법하게 이루어진 이상 피압류채권은 집행채권의 범위 내에서 당연히 집행채권자에게 이전하는 것이어서 그 집행채권이 이미 소멸하였거나 소멸할 가능성이 있다고 하더라도 위 채권의 압류 및 전부명령의 효력에는 아무런 영향이 없다 할 것이므로 전부금 청구사건에 있어서는 특단의 사정이 없는 한 그 집행채권의 소멸 또는 소멸가능성에 대하여 심리판단할 필요없다.

118) 이재성(주16), 174.; 남기정(주9), 233.; 鈴木忠一 外, 위 注解民事執行法(4), 618-619.; 권광중, “채권의 부당이득과 그 반환의무의 이행방법”, 민사판례연구 12권, 147.; 대법원 1991. 10. 1. 선고 89다카24270 판결 등

119) 대법원 1989. 10. 27. 선고 89다카4298 판결【판결요지】[1] 임대차종료시 발생하는 임차인의 임차목적물반환채무와 임대인의 잔존임차보증금반환채무는 서로 동시이행의 관계에 있는 것이므로 임차인이 동시이행의 항변권에 기하여 임차보증금반환청구채권을 확보하려고 임차목적물을 계속 점유하는 경우에는 본래의 용도대로 사용 수익하고 있지 아니한 이상 그로 인하여 실질적으로 이익을 얻고 있다고도 할 수 없으므로 임차인이 임차목적물을 계속 점유하였다고 하여 바로 불법점유로 인한 손해배상책임이나 부당이득반환채무가 발생하는 것은 아니라고 볼 것이다. [2] 임차인의 임차보증금반환청구채권이 전부된 경우에도 채권의 동일성은 그대로 유지되는 것이어서 동

이 경우 임대차보증금반환청구권을 상실한 채무자가 그 반환을 위하여 동시이행의 항변권을 행사할 이익을 가진다고 볼 수 있을지는 의문이다.¹²⁰⁾

라. 제3채무자의 지위

제3채무자는 피전부채권이 존재하는 한 종전의 채권자인 집행채무자에 대하여 부담하고 있던 채무를 채권자에 대하여 부담하게 되며, 채권자에게 이를 이행하면 된다.

제3채무자는 채무자에 대하여 가지고 있던 종전의 법률상의 지위를 그대로 가지고 있으므로 채무자에 대한 채권압류 전의 각종의 항변사유, 예를 들어 취소, 해제, 상계¹²¹⁾ 등의 형성권의 행사나 동시이행 내지 선이행의 항변으로써 채권자에 대하여 대항할 수 있다.¹²²⁾ 그 항변사유가 형성권의 행사일 때에는 그 의사표시는 원칙적으로 집행채무자에 대하여 하여야 하지만, 상계의 경우에는 전부채권자에 대하여 하여야 한다.¹²³⁾ 다만 가분적인 금전채권의 일부에 대한 전부명령이 확정되면 전부명령이 제3채무자에 송달된 때에 소급하여 전부된 채권 부분과 전부되지 않은 채권 부분에 대하여 각기 독립한 분할채권이 성립하게 되므로 그 채권에 대하여 압류채무자에 대

시이행관계도 당연히 그대로 존속한다고 해석할 것이므로 임대차계약이 해지된 후에 임대인이 잔존임차보증금반환청구채권을 전부받은 자에게 그 채무를 현실적으로 이행하였거나 그 채무이행을 제공하였음에도 불구하고 임차인이 목적물을 명도하지 않음으로써 임차목적물반환채무가 이행지체에 빠지는 등의 사유로 동시이행의 항변권을 상실하게 되었다는 점에 관하여 임대인이 주장, 입증을 하지 않은 이상, 임차인의 목적물에 대한 점유는 동시이행의 항변권에 기한 것이어서 불법 점유라고 볼 수 없다.

120) 김능환·민일영 편집대표, 위 주석민사집행법[V], 493.; 오세빈, “임대차종료시 임차인의 보증금채권이 압류된 경우 동시이행관계가 존속하는지 여부”, 민사재판의 제문제 6권, 150.은 이러한 경우에도 동시이행관계는 유지되지만 임차인의 임대목적물 점유가 압류채권자의 보증금수령을 목적으로 계속되었다는 사정이 인정되지 않는 한 이를 가리켜 동시이행의 항변권에 기한 점유라고 보아서는 안될 것이라고 한다.

121) 대법원 1980. 9. 9. 선고 80다939 판결

122) 대법원 1968. 7. 24. 선고 68다895 판결【판결요지】[1] 전세계약에 있어서 전세금은 전세권자의 고의, 과실에 의한 목적물의 손해를 담보하며 압류채권자의 지급명령을 다룰 수 있는데도 불구하고 다투지 아니함으로써 생길 강제집행으로 인한 위험까지 담보한다고는 할 수 없다. [2] 전부명령이 있는 경우에 제3채무자는 전부명령이 있는 이후에 있어서도 채무자에 대하여 가지고 있었던 종전의 법률상 지위를 그대로 가지고 있는 것이므로 제3채무자는 채무자에 대한 채권압류 전의 항변사유로서 압류채권자에게 대하여도 대항할 수 있다.; 대법원 1984. 8. 14. 선고 84다가545 판결【판결요지】전부명령에 의하여 피전부 채권은 동일성을 유지한 채로 집행채무자로부터 집행채권자에게 이전되고 제3채무자는 채권압류전에 피전부채권자에 대하여 가지고 있었던 항변사유로서 전부채권자에게 대항할 수 있다 할 것이므로 공사도급계약시 수급인의 종업원들에 대한 노임채불로 공사가 지연되는 경우 도급인이 그 노임을 수급인에게 지급할 공사대금중에서 종업원들에게 직접 지급하기로 약정하였다면 도급인은 채불노임상당의 공사 대금에 대하여는 수급인에게 그 지급을 거부할 수 있고 따라서 전부채권자에 대해서도 위와 같은 항변사유를 가지고 대항할 수 있다.

123) 宮脇幸彦(주71), 157.; 中野貞一郎(주24), 570.; 남기정(주9), 242.; 日最判 昭和 32(1957). 7. 9.(民集 11-7, 1297)

한 반대채권으로 상계하고자 하는 제3채무자로서는 전부채권자 혹은 압류채무자 중 어느 누구도 상계의 상대방으로 지정하여 상계하거나 상계로 대항할 수 있고, 그러한 제3채무자의 상계 의사표시를 수령한 전부채권자는 압류채무자에 잔존한 채권 부분이 먼저 상계되어야 한다거나 각 분할채권액의 채권 총액에 대한 비율에 따라 상계되어야 한다는 이의를 할 수 없다.¹²⁴⁾ 또한 제3채무자는 전부채권자에 대하여 가지는 채권으로 상계할 수 있다.¹²⁵⁾

전부명령이 무효인 경우에는 제3채무자로서는 전부금청구소송에서 이를 주장할 수 있을 뿐만 아니라 전부명령에 대한 즉시항고를 제기할 수도 있다(민집 제229조 제6항).

그 밖에 무효인 전부명령을 받은 채권자에게 대한 제3채무자의 변제가 채권의 준점유자에 대한 변제가 될 수 있는 것은 이미 본 바와 같다.

나아가 임대차보증금반환채권이 압류·전부된 경우에 그 임대차보증금은 임대인이 임차인의 목적물 인도시까지 임대차계약에 의하여 임차인에 대하여 가지는 일체의 채권을 담보하는 것이라는 이유로, 제3채무자인 임대인은 전부명령 송달시까지 발생한 임차인에 대한 채권뿐만 아니라 그 이후에 발생한 채권도 공제한 나머지를 전부채권자에게 지급하면 된다는 것이 판례¹²⁶⁾의 태도이다.

또한 주택임대차보호법 제3조 제1항의 대항요건을 갖춘 임차인의 임대차보증금반환채권에 대한 압류 및 전부명령이 확정되어 임차인의 임대차보증금반환채권이 집행채권자에게 이전된 경우 제3채무자인 임대인으로서 임차인에 대하여 부담하고 있던 채무를 집행채권자에 대하여 부담하게 될 뿐 그가 임대차목적물인 주택의 소유자로서 이를 제3자에게 매도할 권능은 그대로 보유하는 것이며, 위와 같이 소유자인 임대인이 당해 주택을 매도한 경우 주택임대차보호법 제3조 제2항에 따라 전부채권자에 대한

124) 대법원 2010. 3. 25. 선고 2007다35152 판결

125) 김능환·민일영 편집대표, 위 주석민사집행법[V], 495.

126) 대법원 1987. 6. 9. 선고 87다68 판결 【판결요지】[1] 건물임대차에 있어서의 임차보증금은 임대차 존속중의 임료뿐만 아니라 건물명도의무 이행에 이르기까지 발생한 손해배상채권 등 임대차 계약에 의하여 임대인이 임차인에 대하여 갖는 일체의 채권을 담보하는 것으로서 임대차 종료 후에 임차건물을 임대인에게 명도할 때에 체불임료 등 모든 피담보채무를 공제한 잔액이 있을 것을 조건으로 하여 그 잔액에 관한 임차인의 보증금반환청구권이 발생한다. [2] 임차보증금을 피전부채권으로 하여 전부명령이 있는 경우에도 제3채무자인 임대인은 임차인에게 대항할 수 있는 사유로써 전부채권자에게 대항할 수 있는 것이므로 건물임대차보증금의 반환채권에 대한 전부명령의 효력이 그 송달에 의하여 발생한다고 하여도 위 보증금반환채권은 임대인의 채권이 발생하는 것을 해제조건으로 하는 것이므로 임대인의 채권을 공제한 잔액에 관하여서만 전부명령이 유효하다. ; 다만 대법원 1981. 11. 10. 선고 81다378 판결은, 전부명령이 송달된 때까지 발생한 채권만을 공제할 수 있다는 취지로 보인다.

보증금지금의무를 면하게 되므로 결국 임대인은 전부금지금의무를 부담하지 않는다.¹²⁷⁾

마. 제3자에 대한 효력

전부명령에 의한 채권이전의 사실은 제3자에게도 이를 주장할 수 있다. 그러나 제3자가 이를 다룰 이익이 있을 때(예를 들어, 채권을 미리 양수한 자 등)에는 전부채권자를 상대로 하여 위 채권이 전부채권자에게 귀속되지 않았거나 자기에게 속한다는 확인을 구하는 소를 제기할 수 있고, 채무자나 제3채무자가 즉시항고를 할 수 있는 기간 내에는 전부명령에 대한 즉시항고를 제기할 수도 있다.¹²⁸⁾

3. 집행채권의 소멸

전부명령이 발효하면 피전부채권이 존재하는 한 그 권면액 상당의 집행채권은 집행채권자에게 변제된 것으로 보아 전부명령이 제3채무자에게 송달된 때로 소급하여 소멸된다.¹²⁹⁾

이처럼 집행채권이 소멸하면 그 한도에서 집행권원의 집행력도 소멸한다. 제3채무자가 자력이 없어서 현실적으로 변제를 받지 못하더라도 집행채권 소멸의 효력에는 영향이 없다. 집행채권인 약속어음금 채권이 전부명령의 확정에 의하여 소멸한 경우 그 시점에 약속어음금 채권에 의하여 담보되는 원인채권인 대여금채권도 같은 액수만큼 변제로 인하여 확정적으로 소멸한다.¹³⁰⁾

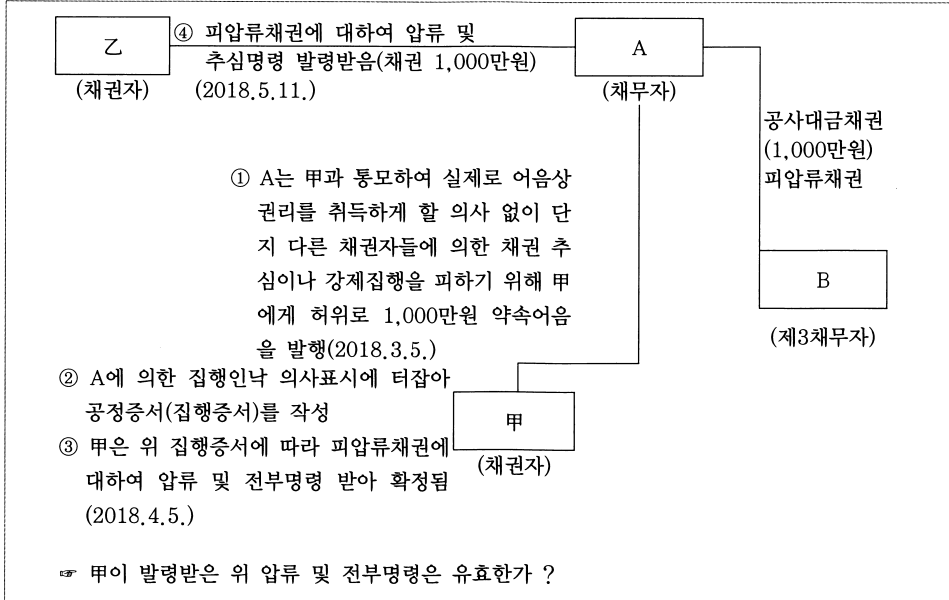
127) 대법원 2005. 9. 9. 선고 2005다23773 판결. 이는 임대차보증금반환채권에 대한 전부명령이 확정된 경우라도 임대인, 즉 임대차 부동산의 소유권이전을 금지할 수 없는 것인데, 임대차보증금반환채무자가 임대인으로 확정된다고 본다면 임대인은 소유권 이전시 임대차보증금을 포함하여 양도대금을 정하여야 하므로, 양수인에게 임대차의 부담을 안고 소유권을 취득하는 마당에 임대차보증금을 포함한 양도대금의 지불을 기대하기 어렵다는 점에서 일반적 거래관행에 부합하지 않을 뿐만 아니라 임대인의 지위를 너무 불리하게 만드는 결과가 되기 때문이다. 또한 임차인의 임대차보증금반환채권이 가압류된 상태에서 임대주택이 양도되면 양수인이 채권가압류의 제3채무자의 지위에 승계하고, 가압류권자 또한 임대주택의 양도인이 아니라 양수인에 대하여만 위 가압류의 효력을 주장할 수 있다[대법원 2013. 1. 17. 선고 2011다49523 전원합의체 판결].

128) 鈴忠一 外, 위 注解民事執行法(4), 620.

129) 대법원 2004. 5. 28. 선고 2004다6542 판결 【결정요지】집행력 있는 집행권원에 기하여 채권압류 및 전부명령이 적법하게 이루어진 이상 피압류채권은 집행채권의 범위 내에서 당연히 집행채권자에게 이전한다 할 것이어서 그 집행채권이 이미 소멸하였거나 실제 채무액을 초과하더라도 그 채권압류 및 전부명령에는 아무런 영향이 없고, 제3채무자로서는 채무자에 대하여 부담하고 있는 채무액의 한도 내에서 집행채권자에게 변제하면 완전히 면책된다.

130) 대법원 2009. 2. 12. 선고 2006다88234 판결

가. 집행채권에 무효사유 등이 있는 경우



위 사례는 채무자 또는 그 대리인의 유효한 작성촉탁과 집행인낙의 의사표시에 터잡아 작성된 공정증서를 집행권원으로 하는 금전채권에 대한 강제집행절차에서, 실제로 어음상의 권리를 취득하게 할 의사는 없이 단지 채권자들에 의한 채권의 추심이나 강제집행을 피하기 위하여 채권자 1인에게 통정허위표시로서 약속어음을 발행하고 그에 따른 공정증서(집행증서)에 기하여 그 채권자가 압류 및 전부명령을 받아 그 전부명령이 확정된 경우에도 피전부채권의 이전이라는 효과는 발생하는가가 문제에 관한 것이다.

결론을 말하자면, 우선 위의 경우라도 확정된(압류 및) 전부명령의 효력, 즉 전부명령에 따라 피전부채권이 이전되는 효력에는 지장이 없다. 이 경우비록 그 공정증서에 표시된 청구권의 기초가 되는 법률행위에 무효사유가 있다고 하더라도 그 강제집행절차가 청구이의의 소 등을 통하여 적법하게 취소·정지되지 아니한 채 계속 진행되어 채권압류 및 전부명령이 적법하게 확정되었다면, 그 강제집행절차가 반사회적 법률행위의 수단으로 이용되었다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 단지 이러한 법률행위의 무효사유를 내세워 확정된 전부명령에 따라 전부채권자에게 피전부채권이 이전되는 효력 자체를 부정할 수는 없는 것이다.¹³¹⁾

다만 위와 같이 전부명령이 확정된 후 그 집행권원인 집행증서의 기초가 된 법

131) 대법원 2005. 4. 15. 선고 2004다70024 판결; 대법원 2001. 3. 13. 선고 99다26948 판결 등

를행위 중 전부 또는 일부에 무효사유가 있는 것으로 판명된 경우(乙이 위 약속어음 발행행위에 대하여 통정허위표시로서 무효임을 주장하여 소송에서 승소한 경우)에는 그 무효 부분에 관하여는 집행채권자가 부당이득을 한 셈이 되므로(즉 이 경우 압류 및 전부명령은 채무자에 대한 관계에서 효력이 없다), 그 집행채권자는 집행채무자에게 위 전부명령에 따라 전부받은 채권 중 실제로 추심한 금전 부분에 관하여는 그 상당액을 반환하여야 하고, 추심하지 아니한 나머지 부분에 관하여는 그 채권 자체를 양도하는 방법에 의하여 반환하여야 한다.¹³²⁾

그리고 위 사례에서 집행채무자 A의 채권자인 乙이 위 집행채권자인 甲을 상대로 부당이득금 반환채권을 대위행사하는 경우 집행채무자에게 그 반환의무를 이행하도록 청구할 수도 있지만, 직접 대위채권자에게 이행하도록 청구할 수도 있다고 보아야 한다.¹³³⁾ 이와 같이 채권자대위권을 행사하는 채권자에게 변제수령의 권한을 인정하더라도 그것이 채권자 평등의 원칙에 어긋난다거나 제3채무자를 이중 변제의 위험에 빠뜨리게 하는 것이라고 할 수 없기 때문이다.

이와 같은 법리는 집행권원에 기한 금전채권에 대한 강제집행의 일환으로 채권 압류 및 전부명령이 확정된 후 그 집행권원상의 집행채권이 소멸한 것으로 판명된 경우도 마찬가지이다.¹³⁴⁾

나. 피전부채권이 부존재한 경우

1) 피전부채권이 존재하지 않는 경우에는 전부명령은 실체법상 무효이므로 집행채권 소멸의 효력은 발생하지 않는다(민집 제231조 단서).¹³⁵⁾

132) 이러한 부당이득반환청구에서 집행채무자가 집행채권 소멸의 원인으로 주장할 수 있는 사유가 여러 가지인 경우 이들은 법률상의 원인 없는 사유에 관하여 공격방법이 다른 데 지나지 않으므로 그 중 어느 사유를 주장하여 패소의 확정판결을 받은 경우에 다른 사유를 주장하여 다시 청구하는 것은 기판력에 저촉되어 허용될 수 없다(대법원 2008. 2. 29. 선고 2007다49960 판결).

133) 위 대법원 2005. 4. 15. 선고 2004다70024 판결 참조

134) 대법원 2010. 12. 23. 선고 2009다37725 판결 【판결요지】집행권원에 기한 금전채권에 대한 강제집행의 일환으로 채권압류 및 전부명령이 확정된 후 그 집행권원상의 집행채권이 소멸한 것으로 판명된 경우에는 그 소멸한 부분에 관하여는 집행채권자가 집행채무자에 대한 관계에서 부당이득을 한 셈이 되므로, 집행채권자는 그가 위 전부명령에 따라 전부받은 채권 중 실제로 추심한 금전 부분에 관하여는 그 상당액을, 추심하지 아니한 부분에 관하여는 그 채권 자체를 집행채무자에게 양도하는 방법으로 반환하여야 한다.; 대법원 2008. 2. 29. 선고 2007다49960 판결

135) 대법원 1992. 4. 15.자 92마213 결정 【결정요지】[1] 현행 민사소송법 제561조 와 제563조 는 구 민사소송법(1990.1.13. 법률 제4201호로 개정되기 전의 것)과는 달리 금전채권의 압류 및 전부명령의 신청에 관한 재판에 대하여 즉시항고를 할 수 있도록 규정하고, 또 전부명령은 확정되어야 효력이 있다고 규정하고, 같은 법 제564조 는 전부명령이 확정된 경우에는 전부명령이 제3채무자에게 송달될 때에 채무자는 채무를 변제한 것으로 본다 고 규정하고 있으므로 확정되지 아니한 전부명령에 의하여 변제의 효과가 발생하고 강제집행절차가 종료할 수는 없다. [2] 채권의 압류 및 전

이 경우에 전부채권자는 피전부채권이 존재하지 아니함을 입증하여 다시 집행력 있는 정보를 부여받아 강제집행을 할 수 있다. 그러나 피전부채권이 존재하지 않음을 이유로 전부명령 신청 당시 제출한 집행권원의 반환을 청구할 수는 없다.¹³⁶⁾

피전부채권이 존재하지 않는다는 입증방법으로는 이론적으로는 제3채무자 명의의 피전부채권 부존재의 증명서와 같은 것도 생각할 수 있으나, 실제에서는 전부금청구소송에서의 전부채권자 패소의 판결을 제출하는 것이 보통이다.¹³⁷⁾

여기서 피전부채권이 존재하지 않는 경우란 전부명령이 송달될 당시 피전부채권이 처음부터 존재하지 아니하였거나 또는 소멸 내지 제3자에게 양도된 경우 등은 물론이고, 전부명령이 송달될 당시에는 피전부채권이 유효하게 존재하고 있었으나 그 후 제3채무자의 취소나 해제 또는 상계 등에 의하여 소급하여 소멸한 경우,¹³⁸⁾ 장래의 조건부채권에 대한 전부명령이 확정된 후에 그 피압류채권의 전부 또는 일부가 존재하지 아니한 것으로 밝혀진 경우¹³⁹⁾ 등도 포함된다. 따라서 이처럼 피전부채권이 소급하여

부명령은 금전채권의 채무명의를 가지는 채권자가, 그 채무명의상의 채무자가 제3채무자에 대하여 가지는 금전채권을 대상으로 하는 강제집행으로서, 법원은 압류 및 전부명령의 결정을 함에 있어서는 채무명의의 송달, 선행하는 압류명령의 존부, 피전부채권의 유무 등의 요건을 심리하면 되고, 실제로 채무자가 제3채무자에게 압류 및 전부명령의 대상이 되는 채권을 가지고 있는지 여부는 따질 필요가 없는 것이 원칙이고, 만일 채무자의 제3채무자에 대한 그와 같은 채권이 존재하지 아니하는 경우에는 전부명령이 확정되더라도 변제의 효력이 없는 것이며, 채무자로서는 제3채무자에게 그와 같은 채권을 가지고 있지 않다고 하더라도 특별한 사정이 없는 한 이로 인하여 어떠한 불이익이 있는 것이 아니므로 이것을 이유로 하여서는 스스로 불복의 사유로 삼을 수 없다.

136) 재판예규 제866-3호, “강제집행이 불능된 경우 집행력 있는 집행권원의 반환(재민 62-9)” 문.

집행법원의 전부명령이 있은 후 민사집행법 제227조 제2항의 절차를 완료한바, 전부된 채권이 존재하지 아니하여 전부명령이 그 효력을 발하지 못한다 하여 신청채권자가 집행법원에 그 집행권원의 반환을 구하였을 경우, 그 처리 방법으로서 다음 3설이 있는 바, 그 어느 것이 타당합니까.

갑설 : 집행권원을 반환할 수 없다.

을설 : 제3채무자 혹은 채무자와 제3채무자의 전부채권이 존재하지 않았다는 뜻의 증명서를 첨부 신청하면 반환하여야 한다.

병설 : 전부채권 부존재의 확정판결을 득한 후 신청하면 반환할 수 있다.

답.

갑설이 옳다고 생각한다.

부 칙(2002. 6. 26. 제866호)

이 예규는 2002. 7. 1.부터 시행한다. 다만 2002. 7. 1. 전에 접수된 사건에 대하여는 이 예규를 적용하지 아니한다.

137) 이재성(주16), 180.; 남기정(주9), 249.

138) 이재성(주16), 180.; 남기정(주9), 242.; 宮脇幸彦(주71), 157.; 中野貞一郎(주24), 561.

139) 대법원 2004. 8. 20. 선고 2004다24168 판결【판결요지】[1] 토지수용으로 인한 피수용자의 손실보상금채권은 관할 토지수용위원회의 수용재결로 인하여 비로소 발생하는 것이지만, 구 토지수용법 제14조, 제16조 소정의 사업인정의 고시가 있음으로써 고시된 수용대상 토지에 대하여 피수용자와의 협의 등 일정한 절차를 거칠 것을 조건으로 한 기업자의 수용권이 발생하고, 같은 법 제

소멸한 경우에는 일단 소멸하였던 집행채권도 소급적으로 부활하는 것으로 보아야 한다.¹⁴⁰⁾

특히 문제가 되는 것은 상계의 경우인데, 제3채무자가 채무자에 대한 자동채권으로써 전부채권자에게 대항할 수 있는 경우에 그 상계적상이 압류 전에 성립된 것이면 상계의 효력도 상계적상 시점으로 소급하므로 문제가 없지만, 상계적상이 압류 후에 있는 경우에도 일정한 범위 내에서는 상계가 허용되고,¹⁴¹⁾ 그렇다면 이 경우에는 상계의 효력이 압류명령 내지 전부명령 이전까지는 소급할 수 없게 되며 따라서 이때에는 상계가 집행채권 소멸의 효과에 영향을 미치지 않는 것이라고 볼 여지도 있다.¹⁴²⁾ 그러나 상계적상이 압류명령 송달 후라는 이유로 집행채권의 소멸에는 영향이 없고 따라서 집행채권자로서는 채무자를 상대로 부당이득반환청구권만을 행사할 수밖에 없다고 하는 것은 제3채무자가 자동채권을 압류 전에 취득한 경우에 상계를 널리 허용하는 취지에도 부합하지 않으므로 상계적상의 성립시기가 언제였는지를 불문하고 집행채권의 부활을 인정하여야 할 것이다.¹⁴³⁾

2) 또한 이와 관련하여 제3채무자의 상계의 자동채권이 어음채권인 경우에 제3채무자가 그 어음을 누구에게 반환해야 하는지가 문제로 될 수 있는바, 이에 대하여 상계적상이 전부명령 이전에 성립하여 상계의 효력도 전부명령 이전으로 소급하는 경

18조 소정의 사업의 폐지, 같은 법 제17조 소정의 사업인정의 고시가 있는 날로부터 1년 이내 혹은 같은 법을 준용하는 개개 법률 소정의 사업시행기간 내의 재결의 미신청 등의 특별한 사정이 없는 한 사업인정은 실효되지 아니하여 수용권이 소멸하지 아니하므로, 사업인정의 고시가 있으면 수용대상 토지에 대한 손실보상금의 지급이 확실시된다 할 것이니, 사업인정 고시 후 수용재결 이전 단계에 있는 피수용자의 기업자에 대한 손실보상금채권은 피전부채권의 적격이 있다. [2] 전부명령은 압류된 채권(채권)을 지급에 갈음하여 압류채권자에게 이전시키고 그것으로 채무자가 채무를 변제한 것으로 간주하는 것이어서 전부명령의 대상인 채권(채권)은 금전채권으로 한정되는 것이므로, 토지수용에 대한 보상으로서 채권(채권)지급이 가능하고, 기업자가 현금 또는 채권(채권) 중 어느 것으로 지급할 것인지 여부를 선택하지 아니한 상태에 있는 경우, 손실보상금채권에 대한 압류 및 전부명령은 기업자가 장래에 보상을 현금으로 지급하기로 선택하는 것을 정지조건으로 하여 발생하는 손실보상금채권을 그 대상으로 하는 것이라고 할 것이고, 위와 같은 장래의 조건부채권에 대한 전부명령이 확정된 후에 그 피압류채권의 전부 또는 일부가 존재하지 아니한 것으로 밝혀졌다면 민사집행법 제231조 단서에 의하여 그 부분에 대한 전부명령의 실제적 효력은 소급하여 실효된다.

140) 김능환·민일영 편집대표, 위 주석민사집행법[V], 497.

141) 대법원 1973. 11. 13. 선고 73다518 판결; 대법원 1989. 9. 12. 선고 88다카25120 판결 [판결요지]채권가압류명령을 받은 제3채무자는 그 후에 취득한 채권에 의한 상계로 그 가압류채권자에게 대항하지 못하지만 수동채권이 가압류될 당시 자동채권과 수동채권이 상계적상에 있거나 자동채권의 변제기가 수동채권의 그것과 동시 또는 그보다 먼저 도래하는 경우에는 제3채무자는 자동채권에 의한 상계로 가압류채권자에게 대항할 수 있다.

142) 박두환(주31), 244.

143) 宮脇幸彦(주71), 167.; 中野貞一郎(주24), 571.; 유승정(주31), 163.; 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 404.

우에는 어음을 채무자에게 반환하여야 하지만 상계의 효력이 전부명령 이전으로 소급하지 않는 경우에는 전부채권자에게 반환해야 한다는 입장¹⁴⁴⁾도 있으나, 이 경우도 상계적상이 언제 있었는지를 불문하고 어음은 항상 전부채권자 아닌 채무자에게 반환해야 한다고 볼 것이다.¹⁴⁵⁾

다. 장래의 채권 등에 대한 전부명령의 경우

1) 피전부채권이 정지조건부 권리이거나 그 밖에 장래의 채권으로서 전부명령의 효력 발생시에는 아직 현실적으로 존재하지 않는 경우 또는 전부명령의 효력발생시에는 피전부채권이 존재하였더라도 타인의 질권 등과 같은 우선권의 목적이었는데 그 후 그 우선권이 실행되어 채권이 소멸한 때 등과 같이 일반적으로 피전부채권의 권면액 존재가 부정되는 채권의 경우 그 집행채권의 소멸시기를 언제로 보아야 할 것인가.

2) 이에 관하여 학설은 다음과 같이 세 가지로 대립되어 있다.

가) 제1설¹⁴⁶⁾ : 위와 같은 채권 등에 대한 전부명령이 있는 경우에도 전부명령이 확정되면 제3채무자에게 송달된 때에 소급하여 피전부채권의 이전과 집행채권의 소멸이라는 효력이 발생하고, 전부명령의 효력 발생 후 전부된 채권의 전부 또는 일부가 부존재하는 것으로 확정되었을 경우 그러한 사정은 이미 발생한 효과에 영향을 미치지 아니하며, 다만 채무자는 전부채권자에 대한 관계에 있어서 부당이득한 것이 되므로 전부채권자는 채무자를 상대로 부당이득반환청구권에 관한 새로운 집행권원을 얻어 강제집행을 해야 한다는 설이다.

나) 제2설¹⁴⁷⁾ : 전부명령이 확정되면 제1설과 같이 전부명령 송달시에 소급하여 집행채권 소멸의 효과가 발생하지만, 그 후 전부된 채권의 전부 또는 일부가 부존재한 것으로 확정되었을 때에는 그 부존재하는 부분에 대한 전부명령은 본조 단서에 의해 효력이 없게 되므로 집행채권자는 기존의 집행권원에 기해 새로이 채무자의 재산에 대해 강제집행할 수 있다고 보는 견해이다.

다) 제3설¹⁴⁸⁾ : 위와 같은 장래의 채권 등에 전부명령의 실체적 효력은 채권의 존부 내지 그 범위를 불확실하게 하는 요소가 확정되었을 때(정지조건부 채권에 있어

144) 日最判 昭和 50(1975). 9. 25.(民集 29-8, 1287)

145) 宮脇幸彦(주71), 157. 169-170.; 中野貞一郎(주24), 570.; 남기정(주9), 243.

146) 이재성(주16), 161.; 中野貞一郎(주24), 571.; 鈴木忠一 外, 위 注解民事執行法(4), 621.; 남기정(주9), 249-250.

147) 김종대(주30), 135-136.; 신창수(주31), 135-136.

148) 박우동, 판례회고 제7호, 170.

서는 그 조건이 성취되었을 때)에 발생한다는 입장이다.

살피건대, 위 견해들은 모두 어느 것이나 난점을 안고 있는 것이다. 우선 위 제3설에 대하여는 장래의 채권 등에 대한 전부명령의 효력발생시기에 관하여 일반 채권의 경우와 달리 취급할 근거가 없고, 만일 그에 따라 집행채권 소멸의 효과는 채권의 존부 및 범위가 확정되었을 때에 발생하지만 피전부채권 이전의 효과는 전부명령 효과 발생시에 이미 발생한 것이라고 본다면 피전부채권의 이전과 집행채권의 소멸이 표리관계(表裏關係)를 이루어야 하는 전부명령의 본질에 반하며, 채권의 존부 및 범위가 확정될 때까지 전부명령의 효력이 발생하지 않는다면 그때까지는 청구이의의 소도 제기할 수 없다고 보아야 할 것이나, 이는 전부명령제도의 취지와 맞지 않는 해석이다.¹⁴⁹⁾ 그리고 제2설에 대하여는 채권의 존부 및 범위를 불확실하게 하는 요소가 현실적으로 나타나서 전부된 채권의 전부 또는 일부가 더 이상 존재하지 아니하는 것으로 확정되는 것은 상계, 취소, 해제권의 행사 등에 의하여 피전부채권이 전부명령의 효력발생시점 이전으로 소급하여 소멸되는 경우와는 달리 피전부채권이 사후적으로 소멸되는 것에 지나지 아니하므로 민사집행법 제231조¹⁵⁰⁾ 단서를 적용할 수는 없고, 채권자와 채무자 사이에서 집행채권의 소멸 여부가 문제될 때 위와 같은 사정이 나타나는 시기에 따라 결론이 상이하게 되는 난점이 있다.¹⁵¹⁾

결국 위 제1설이 이론적으로 일관된 면이 있으나, 채무자를 상대로 본안소송을 하여 집행권원을 얻고 이에 기하여 전부명령을 받아 제3채무자를 상대로 전부금 청구소송을 하여 전부 또는 일부 기각됨으로써 기진맥진한 채권자에게 또 다시 채무자를 상대로 하여 부당이득반환청구의 소송을 제기하라고 하는 것은 아무리 위험부담을 각오한 채권자라고는 하지만 지나치다는 느낌을 가지지 않을 수 없다.¹⁵²⁾

3) 나아가 이에 대한 판례의 입장 또한 명확하지가 않다. 위 제3설의 입장에 따라 정지조건부채권에 대한 전부명령의 경우 전부명령의 효과는 그 정지조건이 성취된

149) 이재성, “전부명령과 집행채권의 소멸시기”, 이재성평석집(V), 205.; 김영일(주31), 470.; 조무제(주31), 105.; 신창수(주31), 134.; 김종대(주30), 134.; 유승정(주31), 167-168.

150) 민사집행법 제231조 [전부명령의 효과] 전부명령이 확정된 경우에는 전부명령이 제3채무자에게 송달된 때에 채무자가 채무를 변제한 것으로 본다. 다만 이전된 채권이 존재하지 아니한 때에는 그러하지 아니하다.

151) 유승정(주31), 168-169.

152) 유승정(주31), 169.

때에 발생한다는 판례¹⁵³⁾가 있는가 하면, 공사금채권에 대하여 원래 전부명령에 있어서는 그 전부명령이 제3채무자에게 송달됨으로써 당연히 채무자의 제3채무자에 대한 채권은 전부채권자에게 변제에 갈음하여 이전되고, 채무자의 제3채무자에 대한 채권은 이로써 소멸하는 것이라 할 것이므로 국세징수법 제21조 제1호, 같은 법 시행령 제14조 제2호(현행 국세징수법 제5조 제1호, 같은 법 시행령 제4조 제2호) 소정의 납세완납증명서나 징수유예증명서는 채무자의 제3채무자에 대한 채권이 전부채권자에게 전부되는 당시의 것이면 족하다고 하면서 나아가 이와 같은 이론은 전부명령이 본건에 있어서와 같이 공사완성 전의 공사금채권에 관한 것이라 하여 이를 달리할 바가 없다고 판시¹⁵⁴⁾하거나 혹은 피전부채권이 장래의 조건부채권이거나 소멸할 가능성이 있는 것이라고 하더라도 집행력 있는 채권의 압류 및 전부명령이 적법하게 이루어진 이상 피압류채권은 집행채권의 범위 안에서 당연히 전부채권자에게 이전하고 채무자는 채무를 변제한 것으로 간주되므로 이후에 발령된 동일한 채권을 목적으로 하는 압류 및 전부명령은 무효라고 하거나¹⁵⁵⁾ 또는 건물임대차보증금반환채권에 대한 전부명령의 효력은 그 송달시에 발생한다고 하는¹⁵⁶⁾ 등으로 제1설 또는 제2설을 취했다

153) 대법원 1978. 5. 23. 선고 78다441 판결【판결요지】피전부채권이 정지조건부 채권인 경우에는 전부명령도 정지조건이 성취된 때에 효력이 생기므로 위 전부명령을 받아 집행된 것 만으로서는 곧 채무자의 채무변제가 있는 것으로 되어 확정적으로 채권자의 채권이 소멸한 것으로 간주할 수 없다.

154) 대법원 1973. 10. 23. 선고 73다158 판결【판결요지】원래 전부명령에 있어서는 그 전부명령이 제3채무자에 대하여 송달이 됨으로써 당연히 채무자의 제3채무자에 대한 채권은 전부채권자에게 변제에 갈음하여 이전되고, 채무자의 제3채무자에 대한 채권은 이로써 소멸하는 것이라 할 것이므로 국세징수법 제21조 제1호 같은 법 시행령 제14조 제2호 소정의 납세완납증명서나 징수유예증명서는 채무자의 제3채무자에 대한 채권이 전부채권자에게 전부되는 당시의 것이면 족하다고 봄이 상당하다.

155) 대법원 1984. 6. 26. 선고 84마13 판결【판결요지】[1] 집행력 있는 채무명령에 터잡아 채권의 압류 및 전부명령이 적법하게 이루어진 이상 피압류채권은 집행채권의 범위 안에서 지급에 갈음하여 당연히 압류(전부)채권자에게 이전하고 채무자는 채무를 변제한 것으로 간주되어 그 후 그 압류 및 전부를 받은 채권자가 그 채권을 추심하는 과정과는 관계없이 그 강제집행은 이미 종료되었다고 할 것이므로 그 집행채권이 장래의 조건부 채권이거나 소멸할 가능성이 있는 것이라 하여도 그 채권의 압류 및 전부명령의 효력에는 아무런 영향이 없다 할 것이고 따라서 그 이후에 발령된 동일한 채권을 목적으로 하는 압류 및 전부명령은 무효라 할 것이다. [2] 공탁자의 공탁물 회수청구권에 대한 압류 및 전부명령에 있어서 그 공탁물 회수청구권은 담보취소결정이 있어야 비로소 실현될 수 있는 것이지만 전부명령의 효력으로서의 채권자의 변제의 효력에는 영향이 없는 것이므로 담보취소결정 전에 제2의 채권압류 및 전부명령이 발하여졌다 하여도 이는 무효이므로 제1의 전부채권자의 공탁금회수청구는 정당하다 할 것이다.

156) 대법원 1987. 6. 9. 선고 87다68 판결; 대법원 1988. 1. 19. 선고 87다카1315 판결【판결요지】[1] 건물임대차에 있어서의 임차보증금은 임대차존속중의 임료뿐만 아니라 건물명도의무 이행에 이르기까지 발생한 손해배상채권 등 임대차계약에 의하여 임대인이 임차인에 대하여 갖는 일체의 채권을 담보하는 것으로서 임대차종료 후에 임대인에게 명도할 때 체불임료 등 모든 피담보채무를 공제한 잔액이 있을 것을 조건으로 하여 그 잔액에 관한 임차인의 보증금반환청구권이 발생한다. [2] 임차보증금을 피전부채권으로 하여 전부명령이 있을 경우에도 제3채무자인 임대인은

고 보여지는 판례들도 있는데, 근래에 들어서서는 전부명령이 확정되면 피압류채권은 제3채무자에게 송달된 때에 소급하여 집행채권의 범위 안에서 당연히 전부채권자에게 이전하고, 동시에 집행채권 소멸의 효력이 발생하는 것으로, 이 점은 피압류채권이 그 존부 및 범위를 불확실하게 하는 요소를 내포하고 있는 장래의 채권인 경우에도 마찬가지라고 할 것이라고¹⁵⁷⁾ 판시하는 등 위 제3설보다는 제1설 또는 제2설의 입장으로 나아가고 있는 듯한 느낌도 있다.

이와 같이 판례가 이 문제에 대하여 그 태도가 엇갈리는 이유는 앞서 보았듯이 확설상 권면액이 없다고 주장되는 채권들에 대하여도 모두 전부명령을 허용하고 있기 때문이라고 보여진다.¹⁵⁸⁾ 이론적인 면에 치중하여 본다면 제1설이 위 견해들 중에서 가장 간명하고 일관되어 보이기는 하지만 위에서 본 바와 같은 단점이 발목에 걸리기는 하다.

4) 채무자회생절차에서 변제계획인가결정이 있는 때에는 채무자의 급료·연금·봉급·상여금, 그 밖에 이와 비슷한 성질을 가진 급여채권에 관하여 개인회생절차개시 전에 확정된 전부명령은 변제계획인가결정 후에 제공한 노무로 인한 부분에 대하여는 그 효력이 상실된다(채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제616조 제1항).

위 변제계획인가결정으로 인하여 전부채권자가 변제받지 못하게 되는 채권액은 개인회생채권으로 한다(동법 제616조 제2항).

임차인에게 대항할 수 있는 사유로서 전부채권자에게 대항할 수 있는 것이어서 건물임대차보증금의 반환채권에 대한 전부명령의 효력이 그 송달에 의하여 발생한다고 하여도 위 보증금반환채권은 임대인의 채권이 발생하는 것을 해제조건으로 하는 것이므로 임대인의 채권을 공제한 잔액에 관하여서만 전부명령이 유효하다.

157) 대법원 2000. 4. 21. 선고 99다70716 판결【판결이유】피고가 부산지방법원 동부지원 97가단7785호 대여금청구사건의 집행력 있는 판결정본에 기하여 그 판결에서 지급을 명한 금 25,000,000원 및 이에 대한 1988. 1. 20.부터 완제일까지 연 2할 5푼의 비율에 의한 지연손해금 중 원금과 이에 대한 1998. 5. 20.까지의 지연손해금 청구채권을 집행채권으로 하여 원고가 김해시로부터 매월 수령할 장래의 급료채권에 대하여 채권압류 및 전부명령을 받아, 그 명령이 1998. 5. 27. 제3채무자인 김해시에 송달되어 같은 해 6월 11일 확정된 사실을 인정한 후, 위 판결에 의한 피고의 원고에 대한 대여금채권 중 이 사건 전부명령의 집행채권인 원금과 이에 대한 1998. 5. 20.까지의 지연손해금 청구채권은 위 전부명령의 확정으로 그 명령이 김해시에 송달된 날인 1998. 5. 27.에 소급하여 전액 변제된 것으로 간주되어 소멸하였다고 한 원심의 판단은 수긍이 가고, 거기에 전부명령의 효력에 관한 법리나 변제충당에 관한 법리를 오해한 위법이 없다. 피압류채권인 원고의 김해시에 대한 급료채권은 이 사건 전부명령의 송달 시점에서 보아 그 존부 및 범위를 불확실하게 하는 요소를 내포하고 있는 장래의 채권이기는 하나, 그렇다고 하여 전부명령에 의한 집행채권 소멸의 효력이 장차 급료채권이 확정적으로 발생하는 것을 기다려 그 때 가서 비로소 생기게 되는 것은 아니라고 할 것이다. 상고이유는 이와 다른 전제에서 원심판결을 비난하는 것이어서 받아들일 수 없다. 대법원 2001. 9. 25. 선고 99다15177 판결도 동일한 취지로 보인다.

158) 김능환·민일영 편집대표, 위 주석민사집행법[V], 500-501.

V. 저당권부채권의 전부와 이전등기의 촉탁

저당권부채권에 대하여 전부명령을 얻은 때에는 저당권이 압류채권자에게로 이 전되므로 압류채권자가 저당권자로서 저당권을 실행할 수 있다.

저당권이 있는 채권에 관하여 전부명령이 확정된 경우에는 민사집행법 제228조의 규정이 준용되므로(민집 제230조) 전부채권자의 신청에 의하여 법원사무관등은 저당권이전등기를 촉탁하여야 한다(민집규 제167조).

이에 대하여는 제4절 이하에서 다시 살펴보게 되므로 여기서는 자세한 언급을 하지 않기로 한다.

VI. 전부명령에 대한 불복방법

1. 전부명령의 신청에 관한 재판에 대하여는 즉시항고를 할 수 있다(민집 제229조 제6항).¹⁵⁹⁾ 전부명령은 확정되어야 그 효력이 있다(민집 제229조 제7항).

2. 전부명령에 대하여 즉시항고를 제기할 수 있는 자는 전부명령에 의하여 자기의 정당한 이익을 침해당한 자, 통상 채무자와 제3채무자(채권을 경합하여 압류한 자 등의 제3자에게도 즉시항고의 이익이 있을 수 있다)이며, 즉시항고 사유는 전부명령을 발령함에 있어 집행법원이 스스로 조사하여 준수할 사항의 흠결에 관한 것, 즉 채권압류 자체의 무효나 취소 또는 권면액의 흠결이나 압류의 경합과 같은 전부명령에 고유한 무효나 취소사유 등이다. 채권압류 및 전부명령 등의 기초가 된 가집행의 선고가 있는 판결이 상소심에서 취소되었다는 사실도 적법한 항고이유가 될 수 있다.¹⁶⁰⁾

다만 집행채권이 변제 등에 의하여 소멸되었다거나¹⁶¹⁾ 혹은 피전부채권이 존재

159) 판결이 아닌 법원의 결정·명령에 대하여는 당사자가 그 결정·명령의 결과를 고지받기 전이라도 항고할 수 있다(대법원 2014. 10. 8.자 2014마667 전원합의체 결정).

160) 대법원 2007. 3. 15.자 2006마75 결정

161) 대법원 1994. 11. 10.자 94마1681, 1682 결정; 대법원 1997. 4. 28.자 97마360, 361 결정【결정요지】[1] 채권압류 및 전부명령의 신청에 관한 재판에 대하여는 즉시항고에 의하여 불복할 수 있으나, 집행채권이 변제 등에 의하여 소멸되었다는 것과 같은 실체상의 사유는 적법한 항고이유가 되지 아니한다. [2] 채권의 전부명령이 있은 후에 민사소송법 제510조 제2호 또는 제4호의 서류를 제출한 것을 이유로 즉시항고가 제기된 때에는 항고법원은 다른 이유로 전부명령을 취소하는 경우를 제외하고는 항고에 관한 재판을 정지하여야 하는바, 항고인이 항고를 제기하면서 채권자 작성의 영수증 2매를 첨부한 경우, 항고이유 중에 명시된 바 없더라도 이를 민사소송법 제510조 제4호 소정의 변제수령증서로 주장하여 그 서류제출의 점을 항고이유로 삼는 취지가 포함되어 있다고 볼 수 있다.

하지 않는다¹⁶²⁾는 등의 실체에 관한 사유는 전부명령에 대한 불복의 사유가 되지 않는다.¹⁶³⁾

그러나 전부명령 자체가 무효인 경우에는 이러한 즉시항고를 제기하지 아니함에 따라 전부명령이 형식적으로 확정되었다 하더라도 전부명령의 효력을 다룰 수 없는 것은 아니고, 채무자나 제3채무자는 여전히 그 전부명령의 무효를 주장할 수 있다.

3. 전부명령을 각하하거나 기각하는 결정은 신청채권자에게 고지하여야 하고(민집규 제7조 제2항), 이에 대하여 신청채권자가 즉시항고를 할 수 있다. 즉시항고 기간은 1주일이다(민집 제15조 제2항). 그 기산점은 각 즉시항고권자에게 전부명령이 송달된 때이며 즉시항고를 할 자가 전부명령을 고지받을 자가 아닌 때에는 그 재판을 고지받아야 할 자 전원에게 고지된 날로부터 진행한다(민집규 제12조).

4. 전부명령이 있는 뒤에 집행정지결정의 정본(민집 제49조 제2호) 또는 변제나 기한유예증서(민집 제49조 제4호)를 제출한 것을 이유로 즉시항고를 제기한 때에는 항고법원은 다른 이유로 전부명령을 취소하는 경우를 제외하고는 항고에 관한 재판을 정지하여야 한다(민집 제229조 제8항).¹⁶⁴⁾ 집행법원으로서의 잠정적인 집행정지가 집행취소로 결말이 나거나 아니면 집행속행으로 결말이 나는 것을 기다려, 집행취소로 결말이 난 때에는 항고를 인용하여 전부명령을 취소하고, 집행속행으로 결말이 난

162) 대법원 1992. 4. 15.자 92마213 결정【결정요지】[1] 현행 민사소송법 제561조 와 제563조 는 구 민사소송법(1990.1.13. 법률 제4201호로 개정되기 전의 것)과는 달리 금전채권의 압류 및 전 부명령의 신청에 관한 재판에 대하여 즉시항고를 할 수 있도록 규정하고, 또 전부명령은 확정되어 야 효력이 있다고 규정하고, 같은 법 제564조 는 전부명령이 확정된 경우에는 전부명령이 제3채 무자에게 송달된 때에 채무자는 채무를 변제한 것으로 본다고 규정하고 있으므로 확정되지 아니한 전부명령에 의하여 변제의 효과가 발생하고 강제집행절차가 종료할 수는 없다. [2] 채권의 압류 및 전부명령은 금전채권의 채무명의를 가지는 채권자가, 그 채무명의상의 채무자가 제3채무자에 대하여 가지는 금전채권을 대상으로 하는 강제집행으로서, 법원은 압류 및 전부명령의 결정을 함 에 있어서는 채무명의의 송달, 선행하는 압류명령의 존부, 피전부적격의 유무 등의 요건을 심리하 면 되고, 실제로 채무자가 제3채무자에게 압류 및 전부명령의 대상이 되는 채권을 가지고 있는지 여부는 따질 필요가 없는 것이 원칙이고, 만일 채무자의 제3채무자에 대한 그와 같은 채권이 존재 하지 아니하는 경우에는 전부명령이 확정되더라도 변제의 효력이 없는 것이며, 채무자로서는 제3 채무자에게 그와 같은 채권을 가지고 있지 않다고 하더라도 특별한 사정이 없는 한 이로 인하여 어떠한 불이익이 있는 것이 아니므로 이것을 이유로 하여서는 스스로 불복의 사유로 삼을 수 없 다.; 대법원 2004. 1. 5.자 2003마1667 결정도 같은 취지이다.

163) 대법원 1994. 5. 13.자 94마542 결정; 대법원 1994. 11. 10.자 94마1681, 1682 결정; 대 법원 1996. 11. 25.자 95마601, 602 결정

164) 대법원 2001. 8. 25.자 2001마313 결정 등. 이러한 규정을 두게 된 이유는, 원래는 전부명령의 확 정 전에 집행정지의 사유가 생긴 때에는 전부명령 자체를 취소하여야 하였지만, 그렇게 되면 후일 집행 정지의 사유가 소멸되어 강제집행이 속행되는 때에는 압류 등의 경합이 생겨 이전에 전부명령을 받았 던 채권자가 다시 전부명령을 받지 못하게 되어 그의 이익을 해할 우려가 있기 때문이다.

때에는 항고를 기각하여야 한다.¹⁶⁵⁾ 166)

항고법원에 집행정지서면이 제출되어 항고에 관한 재판이 정지된 상태에서 집행 취소서면이 제출된 경우 집행법원의 집행취소결정 여부를 불문하고 곧바로 항고법원이 전부명령을 취소하는 결정을 할 수 있다.¹⁶⁷⁾ 항고법원에 집행정지서면의 제출이 없이 곧바로 집행취소서면이 제출된 경우에 관하여, 판례는 전부명령에 대한 재항고 이후 채무자가 청구이의의 소에서 승소확정판결을 받고 그 정본을 대법원에 제출한 사안에서 강제집행을 불허한다는 내용의 확정판결 정본이 제출된 경우에는 채권압류 및 전부명령을 취소하여야 한다고 판시하고 있다.¹⁶⁸⁾

채권압류 및 전부명령의 기초가 된 가집행의 선고가 있는 판결을 취소한 상소심 판결의 정본은 민사집행법 제49조 제1호 소정의 집행취소서류에 해당하는 것이므로 채권압류 및 전부명령에 대한 항고심에서 항고인이 가집행의 선고가 있는 판결을 취소한 항소심 판결의 사본을 제출하였다면 항고심으로서 항고인으로 하여금 그 정본을 제출하도록 한 후, 즉시항고를 받아들여 채권압류 및 전부명령을 취소하여야 하고,¹⁶⁹⁾ 이는 저당권에 기한 물상대위권의 행사를 위해 압류 및 전부명령을 발령받은 경우 압류 및 전부명령의 기초가 된 저당권의 피담보채권의 부존재를 확인하는 취지의 확정판결 정본이 위 전부명령에 대한 항고심 또는 재항고심 계류 중에 제출된 경우에도 마찬가지이다.¹⁷⁰⁾

165) 대법원 1999. 8. 27.자 99마117, 118 결정【결정요지】[1] 전부명령이 있은 후에 채무자가 민사소송법 제510조 제2호의 서류를 제출한 경우 항고법원은 다른 이유로 전부명령을 취소하는 경우를 제외하고는 같은 법 제563조 제8항에 의하여 항고에 관한 재판을 정지하여야 하고, 그 후 잠정적인 집행정지가 종국적인 집행취소나 집행속행으로 결말이 나는 것을 기다려, 집행취소로 결말이 난 때에는 항고를 인용하여 전부명령을 취소하고, 집행속행으로 결말이 난 때에는 항고를 기각하여야 한다. [2] 채무자는 전부명령 확정 전까지 같은 법 제510조 제2호의 서류를 제출할 수 있다고 보아야 할 것이므로 재항고심 계류 중 위 서류가 제출된 경우에도 재항고법원은 마찬가지로 재항고에 관한 재판을 정지하였다가, 종국적인 집행취소 여하에 따라 재항고 인용 여부를 결정하되, 재항고법원이 재항고를 인용하여 원심결정을 파기하는 경우 사건이 직접 재판하기에 충분한 때에 해당한다고 보아야 할 것이므로 스스로 전부명령을 취소하고 전부명령신청을 기각할 수 있다.

166) 전부명령을 발령한 뒤에 즉시항고를 제기함이 없이 위와 같은 집행정지 서류만이 제출되는 경우에는 전부명령이 제3채무자나 채무자에게 송달되기 전이면 각 그 송달을 중지함으로써 확정이 차단되므로 집행정지의 목적을 달성할 수 있으나, 제3채무자 및 채무자에 대한 송달된 뒤이면 집행정지 서류가 제출되었다 하여 항고기간의 진행이 정지되는 것은 아니므로 전부명령의 확정을 차단할 수 없어 집행정지의 목적을 달성할 수 없게 되므로 즉시항고를 함께 제기하도록 유도함이 상당하다.

167) 대법원 1999. 8. 27.자 99마117, 118 결정; 대법원 2004. 1. 29.자 2003마1492 결정

168) 대법원 1999. 7. 23.자 99마1955, 1956 결정

169) 대법원 2004. 7. 9.자 2003마1806 결정

170) 대법원 2008. 10. 9.자 2006마914 결정

또한 채권자목록에 기재된 개인회생채권에 기하여 개인회생재단에 속하는 채권에 대하여 내려진 압류 및 전부명령이 아직 확정되지 않은 상태에서, 채무자에 대하여 개인회생절차가 개시되고 이를 이유로 위 압류 및 전부명령에 대하여 즉시항고가 제기되었다면, 항고법원은 다른 이유로 압류 및 전부명령을 취소하는 경우를 제외하고는 항고에 관한 재판을 정지하였다가 변제계획이 인가된 경우 압류 및 전부명령이 효력이 발생하지 않게 되었거나 그 효력이 상실되었음을 이유로 압류 및 전부명령을 취소하고 압류 및 전부명령신청을 기각하여야 한다.¹⁷¹⁾ 그리고 애초에 신청한 개인회생절차가 채무자의 개인회생신청 취하 등을 이유로 폐지되었다고 하더라도, 그 압류 및 전부명령에 대한 항고재판 진행 중에 채무자가 새롭게 신청한 개인회생절차가 다시 개시되었다면 변제계획의 인가시까지 그 항고재판을 정지하여야 하는 것은 마찬가지이다.¹⁷²⁾

Ⅶ. 집행절차의 종료

1. 채권집행절차는 전부명령이 확정되어 전부의 실체적 효력이 발생한 때에 목적을 달성하게 되어 피전부채권에 관련된 집행절차도 종료한다.

그 후에는 집행정지, 전부명령 신청의 취하 또는 취소를 할 여지가 없다. 또한 전부명령의 기초가 된 압류명령 역시 그 목적을 달성하여 존재의의를 잃고 장래에 향하여 소멸하게 되므로 그 압류명령의 취하 또는 취소가 인정되지 않고, 그 압류명령이 유효하게 존재함을 전제로 하는 압류의 경합도 생기지 않으며, 마찬가지로 그 압류명령의 유효한 존재를 근거로 하는 배당요구 또한 할 수가 없다(민집 제247조 제2항).¹⁷³⁾

2. 피압류채권의 일부만이 전부되고 만족을 얻지 못한 집행채권이 남은 때에는 만족을 얻지 못한 부분에 대한 압류사건이 존속하게 된다.

압류 및 전부명령의 효력이 발생하지 아니한 경우에도 절차상으로는 절차종료의

171) 대법원 2008. 1. 31.자 2007마1679 결정; 대법원 2009. 9. 24.자 2009마1300 결정. 채권자목록에 기재된 개인회생채권에 기하여 개인회생재단에 속하는 재산에 대하여 이미 계속 중인 강제집행, 가압류 또는 가처분절차는 개인회생절차가 개시되면 일시적으로 중지되었다가, 변제계획이 인가되면 변제계획 또는 변제계획인가결정에서 다르게 정하지 아니하는 한 그 효력을 잃게 된다.

172) 대법원 2009. 9. 24.자 2009마1300 결정

173) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 407.

효과가 생긴다.¹⁷⁴⁾ 그러나 전부명령의 요건을 갖추지 못하여 전부명령이 효력을 가지지 않더라도 압류명령에 무효사유가 없는 경우에는 압류명령의 효력에는 영향이 없으므로 집행절차는 끝나지 않고 다시 후속되는 집행행위(예컨대 추심명령)를 할 수 있다.

3. 전부명령의 경우에 집행관의 집행절차나 집행법원의 배당절차에서와 같이 집행정보의 교부·반환 등에 관한 규정(민집 제9조, 제159조)이 없으므로 집행채권 전액에 관하여 전부명령이 발령된 경우에 집행력 있는 정보의 처리에 관하여 문제가 되나, 실무에서는 집행정보를 채무자에게 교부하거나 채권자에게 반환하지 않고 집행기록에 그대로 편철하여 둔다.¹⁷⁵⁾ 따라서 그 후에 피전부채권이 존재하지 않는 것으로 밝혀진 경우에는 채권자는 집행법원의 법원사무관등으로부터 집행력 있는 정보가 전부명령에 사용되었다는 내용의 사용증명을 받아 이를 근거로 하여 다시 집행력 있는 정보를 받아 다른 재산에 대한 강제집행을 신청할 수 있다.

그러나 집행채권의 일부에 관하여 전부명령이 발령된 경우에는 채권자의 요구가 있으면 민사집행법 제159조 제3항을 준용하여 집행력 있는 정보에 채권의 일부가 전부된 취지를 적어서 그 집행력 있는 정보를 채권자에게 돌려주고 그 사본을 집행기록에 편철한다.¹⁷⁶⁾

4. 전부명령신청이 그 확정 전에 취하¹⁷⁷⁾되거나 이를 취소하는 결정이 확정된 때에는 법원사무관등은 전부명령을 송달받은 제3채무자에게 그 사실을 통지해야 하는 것은 추심명령의 경우와 같다(민집규 제160조 제2항).

174) 대법원 1976. 4. 14.자 76마102 결정【결정요지】금전채권을 압류하고 전부명령이 발부되어 채무자와 제3채무자에게 송달되면 그 집행은 종료된다고 할 것이므로 그 후에는 집행절차에 의한 불복은 하지 못한다 할 것이다.

175) 재판예규 제866-3호, “강제집행이 불능된 경우 집행력 있는 집행권원의 반환(재민 62-9)”

176) 재판예규 제866-4호, “채권일부가 강제집행된 경우 집행력 있는 집행권원의 반환(재민 80-11)”

177) 별지서식 [5-5] 전부명령신청취하서 참조(제5장 말미 수록)

제4절 이전등기의 촉탁

(민집 제230조, 민집규 제167조)

I. 규정의 취지

민사집행법 제230조는 “저당권이 있는 채권에 관하여 전부명령이 있는 경우에는 제228조의 규정을 준용한다.”라고 규정함에 대해, 다시 위 규정이 준용하는 민사집행법 제228조는, “① 저당권이 있는 채권을 압류할 경우 채권자는 채권압류사실을 등기 기록에 기입하여 줄 것을 법원사무관등에게 신청할 수 있다. 이 신청은 채무자의 승낙 없이 법원에 대한 압류명령의 신청과 함께 할 수 있다. ② 법원사무관등은 의무를 지는 부동산소유자에게 압류명령이 송달된 뒤에 제1항의 신청에 따른 등기를 촉탁하여야 한다.”라고 규정하고 있으며, 또한 민사집행규칙 제167조 제1항 내지 제3항은 그 촉탁의 절차를 정하고 있고, 위 규칙 제4항은 “법 제228조의 규정에 따른 등기가 된 경우 압류된 채권이 변제 또는 공탁에 따라 소멸되었음을 증명하는 문서가 제출된 때에는 법원사무관등은 신청에 따라 그 등기의 말소를 촉탁하여야 한다. 압류명령신청이 취하되거나 압류명령의 취소결정이 확정된 때에도 같다.”라고 규정하고 있다.

위 제230조와 규칙 제167조 제4항 등은 위 제228조가 규정하는 저당권부채권에 대해 전부명령 또는 양도명령이 확정된 경우 또는 매각명령에 의한 매각이 종료한 경우(민사집행법 제241조 제6항은 매각명령에 대하여 민사집행법 제228조 또는 제230조를 준용하고 있지 않으나, 민사집행규칙 제167조가 매각명령의 경우에도 이전등기 촉탁에 관한 절차를 규정하고 있다)에 있어서 압류채권자의 저당권의 이전등기 등의 촉탁절차와 위 채권에 대한 지급 또는 공탁이 있었던 경우 또는 채권집행의 신청이 취하된 경우 등에 있어서 압류등기의 말소촉탁절차를 정하고 있는 규정이다.

위와 같은 규정들에 의하여 현금화절차의 적정화를 도모하고, 집행절차 내에서 등기절차를 간편하게 처리하는 것이 가능하게 되었다.

II. 저당권이전등기 등의 촉탁

등기된 저당권¹⁷⁸⁾에 의하여 담보된 채권에 대하여 압류명령이 효력이 생긴 때는

178) 등기된 질권에 의해 담보되는 채권에 대하여도 이에 준하여 생각하면 될 것이다. 또한 등록된 저당권, 질권 등에 의해 담보되는 채권에 대하여도 동일한 취급이 가능하다고 본다.

그 압류의 효력은 그 저장권에도 미치지만(부종성, 수반성에 의한다), 그 효력은 부기 등기에 의해 공시방법을 갖추지 않으면 저장권자에 의한 저장권의 처분이나 변경의 결과 상실되어 버릴 수 있기 때문에, 민사집행법 제228조에 의해 법원사무관등은 압류가 된 취지의 등기 등을 촉탁해야 하는 것으로 되어 있다. 이로써 압류의 효력이 저장권에도 미치게 된다.

압류채권자는 이와 같이 하여, 압류된 채권에 대하여 추심명령을 얻은 때에는 그 채권을 추심하거나 혹은 저장권을 실행하는 것이 가능하게 되는 것이지만, 그 채권에 대하여 배타적으로 만족을 얻기 위해 전부명령을 얻는 것도 가능하다.

또한 당해 채권이 조진부 또는 기한부인 경우 혹은 반대급부에 걸려 있는 경우 등 그 밖의 사정에 의해 그 추심이 곤란한 때는 압류채권자의 신청에 의해 그 채권을 집행법원이 정한 가격으로 지급에 대신하여 압류채권자에게 양도하는 명령(양도명령) 또는 추심에 대신하여 집행법원이 정한 방법으로 그 채권의 매각을 집행관에게 명하는 명령(매각명령)을 발할 수 있는 것으로 되어 있다.

이렇게 하여 전부명령 또는 양도명령이 되어 그것이 확정된 때 또는 매각명령에 의한 매각이 된 때는 피압류채권은 압류채권자 또는 매수인에게 이전하고, 이것에 수반하여 저장권도 당연히 압류채권자 또는 매수인에게 이전하므로 이러한 자를 위해 저장권의 이전에 관하여 공시방법을 갖출 필요가 있다. 그리고 위 제228조에 기초하여 촉탁한 피담보채권의 채권압류등기가 목적을 달성하여 실효하고 무용의 것으로 되기 때문에 그 말소를 할 필요가 있게 된다.

나아가 민사집행법 제230조, 제241조 및 민사집행규칙 제167조에 의하면 전부명령, 양도명령 또는 매각명령에 의한 매각에 기초한 경우에만 이전등기 등의 촉탁이 가능한 것으로 되어 있지만, 민사집행법 제241조 제1항 제4호에 근거하여 「그 밖의 적당한 방법으로 현금화하도록 하는 명령」에 의해 채무자 이외의 자가 채권을 취득한 경우에도 위 제230조의 적용이 있고 그 성질에 응하여 양도명령 또는 매각명령에 의한 매각 중 어느 쪽인가에 준하여 취급된다고 볼 것이다.¹⁷⁹⁾

1. 촉탁의 가부가 문제로 되는 경우

민사집행규칙 제167조 제1항은, 저장권 있는 채권에 관하여 「전부명령이나 양도명령이 확정된 때」 또는 「매각명령에 따른 매각을 마친 때」에 등기의 촉탁을 하도록

179) 鈴木忠一 外, 위 注解民事執行法(4), 660.

되어 있다. 이 때문에 다음과 같은 점이 문제된다.

가. 전부명령 또는 양도명령의 확정

본조에 의한 등기 등의 촉탁을 함에는 전부명령 또는 양도명령이 확정된 후이어야 한다(민집규 제167조 제1항 참조).

또한 압류된 채권에 관하여 이러한 명령 등이 제3채무자에게 송달될 때까지 다른 압류 및 가압류의 집행이 있어서는 안 된다. 이것은 전부명령 등은, 확정되지 않으면 효력이 생기지 않을 뿐더러(민집 제229조 제7항), 제3채무자에게 송달될 때까지 전부명령에 관계된 금전채권에 대하여 다른 채권자가 압류·가압류의 집행 또는 배당요구를 한 때는 그 효력이 생기지 않는 것으로 되어 있기 때문이며(민집 제229조 제5항), 양도명령에 대하여도 동일하게 되어 있다(민집 제241조 제6항 참조). 이 때문에 실무상 이와 같은 점에 관한 증서의 제출이 요구되고 있다(민집규 제168조 제1항).

그리고 매각명령에 의한 매각의 경우는 매각이 종료한 것을 필요로 하고 있지만, 이것은 후술하는 바대로 그 종료 여부가 기록상 명확하게 되어 있는 것이므로 특히 문제가 생기지는 않는다.

나. 전부명령이 무효인 경우

전부명령, 양도명령 또는 매각명령에 의한 매각이 위 가.항에 표시한 것 이외의 사유로 효력이 생기지 않는 경우(예를 들어 압류명령이 송달되기 전에 이미 채무자가 파산선고를 받고 있는 경우나 또는 전부명령에 관계된 채권이 전부명령을 발하는 것이 불가능한 채권이었던 경우)에도 형식상 전부명령이 확정되면 법원사무관등으로서 명백하게 채권이전의 효력이 생기지 않는다고 인정할 수 없는 경우를 제외하고는 채권자의 신청에 응하여 촉탁을 할 수밖에 없을 것이다.

이 경우의 구제는 저당권자 등이 그 이전등기의 말소를 소구하는 수밖에 없다고 본다.¹⁸⁰⁾

다. 저당권설정등기가 미료(未了)된 경우 등

저당권설정등기 등이 마쳐지지 않은 경우에는, 당해 저당권이 존재하는 한 실체상 전부명령에 의해 그것이 이전하기는 한다 하더라도, 본조에 의한 등기촉탁의 여지

180) 鈴木忠一 外, 위 注解民事執行法(4), 660.; 대법원 2005. 6. 10. 선고 2002다15412, 15429 판결 참조.

는 없다.

이에 반해 저당권설정등기 등은 되어 있지만 민사집행법 제228조에 의한 채권압류등기가 되어 있지 않은 경우에는 어떤 다른 사정에 의해 압류등기가 유루(遺漏)되어 있을 수도 있는 것이어서 전부명령이 적법하게 되어 있다면 담보권의 이전이 있는 것이므로 당해 담보권에 대해 그 밖의 처분이 되어 있지 않는 한, 본조에 의한 저당권 이전등기 등을 촉탁하는 것이 가능하다.

라. 근저당권의 경우

이에 대하여는 IV.에서 다시 다루게 되므로 여기서는 그냥 넘어가기로 한다.

마. 후행 등기가 존재하는 경우

채권압류명령 이후에 전부명령이 확정된 경우 압류기입등기 후에 그 압류 등기와 저촉되는 다른 저당권의 이전 또는 처분 등이 행해진 경우 압류채권자가 저당권이전등기를 촉탁하면서 이러한 등기에 대한 말소촉탁을 동시에 하는 것이 가능한가라는 문제가 있다.

부동산경매의 경우에는 민사집행법 제144조 제1항 제2호가 「매수인이 인수하지 아니한 부동산의 부담에 관한 기입 등기의 말소」도 촉탁하는 것으로 규정하고 있으므로 이 조문을 유추적용하여 위와 같은 촉탁을 하는 것이 가능하다고 보는 견해도 있을 수 있다(이 촉탁을 하는 것이 가능하지 않다면 다른 방법에 의해 이러한 등기가 말소되지 않는 한 저당권이전등기의 촉탁이 가능하지 않게 되기 때문이다).

그러나 부동산경매에 비교하여 본조에서는 이러한 취지의 규정이 없고 또 부동산의 매각에 수반한 권리의 소멸 등에 관한 민사집행법 제91조나 위 제144조 규정이 준용되고 있지 않으며, 특히 압류기입등기와 저당권이전등기 등 사이의 우열은 등기 등의 전후에 의한 것이 아니라 압류명령의 제3채무자에의 송달과 피담보채권양도의 확정일자 있는 통지의 전후에 의하여 결정되고, 따라서 저당권이전등기 등이 압류기입등기보다 늦게 되었다고 해도 압류가 항상 우선하는 것은 아니고 그 우선 여부는 본안소송에서 다루어지는 것이 바람직하므로 이러한 등기의 말소의 촉탁을 동시에 할 수 없다고 보는 부정설이 타당하다.¹⁸¹⁾ 위 부정설에 의할 경우 채권압류의 등기에 대항할 수 없는 권리변동은 전부명령이 확정되면 그 효력을 상실하게 되므로 이를 이유로 등기의 말소를 구하고(이때 형식적으로 등기관리자는 저당권자이므로 채권자는

181) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 407.;鈴木忠一 外, 위 注解民事執行法(4), 662.

대위신청을 하게 된다), 그 후에 등기촉탁을 구해야 할 것이다.

2. 촉탁의 신청

가. 신청권자

본조에 기초하여 하는 촉탁은 전부명령 등에 의해 채권을 취득한 압류채권자 또는 매수인의 신청에 기하여 행해진다.

이러한 자의 일반승계인도 신청을 하는 것이 가능하지만, 이러한 자로부터 당해 채권을 양수한 자는 이 신청을 할 수 없다고 해석해야 한다.¹⁸²⁾ 집행절차에 의해 채권을 취득한 자의 권리실현을 위해 특히 간이한 절차를 정한 본조의 취지에 반하기 때문이다.

나. 증서의 제출

1) 위 촉탁의 신청을 할 때에는 기록상 명확한 경우를 제외하고 압류된 채권에 관해 전부명령 또는 양도명령이 제3채무자에게 송달될 때까지 다른 압류 및 가압류의 집행이 없다는 사실을 증명하는 문서를 제출해야 한다(민집규 제168조 제1항). 이미 본 바대로 전부명령이 제3채무자에게 송달될 때까지 전부명령에 관계된 금전채권에 대하여 다른 채권자가 압류 또는 가압류의 집행 또는 배당요구를 하였을 때에는 전부명령의 효력이 생기지 않게 되고, 또 양도명령에 있어서도 동일하게 되어 있기 때문이다.

이 때문에 법원사무관등으로서는 전부명령 또는 양도명령이 확정되었음을 이유로 등기촉탁의 신청이 있는 경우에는 당해 전부명령 등이 제3채무자에게 송달될 때까지 다른 압류, 가압류의 집행 또는 배당요구가 없었는지 여부를 확인할 필요가 있다고 말할 수 있다.

2) 그런데 위 사항 가운데 전부명령이 제3채무자에게 송달될 때까지 다른 채권자로부터 배당요구가 있었는가 어떤가는 기록상 명백한 사항이므로 법원사무관등은 스스로 이것을 확인할 수 있을 것이나, 문제는 다른 압류 및 가압류의 집행이 없었는 사실에 대한 증명이다(위 민사집행규칙 제168조 제1항은 이에 관한 입증을 이전 등기 등의 촉탁신청을 하는 압류채권자에게 부담시켜 그것을 증명하는 문서의 제출의무를 과하고 있다고 말할 수 있다).

182) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 406.; 鈴木忠一 外, 위 注解民事執行法(4), 662.

여기에서 말하는 증명서의 종류에 대하여는 별도의 제한이 없다. 일반적으로는 제3채무자가 압류채권자를 위해 작성한 증명서가 제출되면 될 것이다. 또 전부명령이 압류명령과 동시에 발하여지고 나아가 압류채권자의 신청에 의해 제3채무자에 대해 민사집행법 제237조에 의한 진술의 최고가 있는 후 제3채무자로부터 압류, 전부명령이 제3채무자에게 송달될 때까지 다른 압류, 가압류가 없다는 취지로 서면에 의한 진술이 된 다음 이 진술서가 기록에 편철되어 있는 경우에는 이는 민사집행규칙 제168조 제1항에서 말하는 「기록상 분명한 경우」에 해당하므로 증명서의 제출을 요하지 않는다.¹⁸³⁾ 또한 채권자는 증명문서를 제출하기 어려운 사정이 있는 때에는 제3채무자로 하여금 다른 압류 또는 가압류의 집행이 있었는지 여부에 관하여 진술하도록 법원에 신청할 수 있고, 제3채무자가 진술을 게을리 한 때에는 법원이 제3자를 심문할 수도 있다(민집규 제168조 제2항, 제3항).

3) 그리고 전부명령 또는 양도명령이 확정된 사실에 대하여는, 전부명령 또는 양도명령에 대하여 즉시항고가 제기되지 않았다는 취지의 상소법원사무관등의 증명서 제출은 필요하지 않다. 즉시항고의 항고장은, 원심법원에 제출해야 하는 것으로 되어 있어서 원심법원의 기록상 명확한 것이기 때문이다.

4) 나아가 매각명령에 의한 매각의 경우에는 매각절차를 종료한 경우 집행관이 매각조서를 신속하게 집행법원에 제출하는 것으로 되어 있어서(민집규 제165조 제4항), 매각 종료의 사실이 기록상 명확하므로 위와 같은 증명서의 제출이 요구되지 않는다.

3. 등기의 촉탁

가. 동시촉탁

압류채권자나 매수인 등에 대한 저당권이전등기 촉탁과 채권압류등기말소의 촉탁은 동시에 하여야 한다.¹⁸⁴⁾

어느 일방만의 촉탁은 허용되지 않으므로 이 촉탁이 동시에 되지 않은 때에는 부동산등기법 제29조 제5호에 따라 각하할 것이다.¹⁸⁵⁾

나. 촉탁서의 기재

위 촉탁서에는 부동산등기법 제22조(신청주의)에 따라 부동산등기규칙 제43조

183) 양도명령의 경우는 압류명령과 동시에 발하여지지 않으므로 이에 해당되는 예도 없을 것이다.

184) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 407.

185) 鈴木忠一 外, 위 注解民事執行法(4), 663.

(신청정보의 내용)가 정하는 사항을 적어야 한다.

등기의 목적은 「○○번 저당권의 이전 및 저당권부채권 압류등기말소」이고, 등기의 원인은 당해 채권 및 저당권이 이전하는 것으로 된 원인을 말하는 것이기 때문에 「2018년 ○월 ○일 전부명령(또는 양도명령 혹은 매각명령에 의한 매각)」이다. 등기원인 일자는, 전부명령 및 양도명령의 경우 확정되지 않으면 효력이 생기지 않으므로 그 명령이 확정된 날이고(전부명령에 대하여는 제3채무자에게 송달된 날에 변제가 있는 것으로 간주되지만, 나중에 확정되어 그 효력이 생긴 때에 법률상 당연히 채무자로부터 전부채권자에게 이전하고 그것에 부수하여 담보권도 이전하게 되므로 등기원인의 날짜는 그 명령이 확정된 날로 보아야 할 것이다), 매각명령에 의한 매각의 경우에는 집행관이 대금지급을 받은 날이다(매각명령에 의한 매각의 경우 민사집행규칙 제165조 제2항이, “집행관은 대금을 지급받은 후가 아니면 매수인에게 채권증서를 인도하거나 법 제241조 제5항의 통지(채무자를 대신하여 제3채무자에게 서면으로 양도 통지)를 해서는 아니된다.”라고 되어 있으므로 매각에 의해 채권이 매수인에게 이전하고 또 그것에 부수하여 저당권이 이전하는 날은 집행관이 대금의 지급을 받은 날이라고 생각하는 것이 가장 합리적이다. 또한 위 민사집행규칙 제165조 제4항은 집행관이 매각절차를 마친 때에는 바로 매각대금과 매각에 관한 조서를 법원에 제출하여야 한다고 규정하고 있어 집행관이 대금을 지급받은 날이 위 규칙에 의해 조서에 기재되게 되어 있다).

그리고 등기권리자는 압류채권자(전부명령 또는 양도명령의 경우) 또는 매수인(매각명령에 의한 매각의 경우)이며, 등기의무자는 저당권자(압류채무자)이다. 위 촉탁에 따른 비용은 채권을 취득한 채권자 또는 매수인이 부담한다(민집규 제167조 제3항).

다. 첨부서류

저당권이전의 등기 및 채권압류등기말소의 촉탁서에는 전부명령 또는 양도명령의 정본 또는 매각명령에 기초한 매각에 대하여 집행관이 작성한 문서의 등본 및 촉탁서부분 등의 첨부서류를 요한다. 전자는 전부명령 등에 기초한 권리의 이전이 있었던 것을 증명하기 위한 것이고 이것에 의해 절차의 적정보장을 도모할 수 있다.

위에서 집행관이 작성한 문서란 민사집행규칙 제165조 제4항에 따라 집행관이 매각절차의 종료 후에 집행법원에 제출하는 매각에 관련된 조서(매각조서) 등이다.¹⁸⁶⁾ 그리고 촉탁서부분은 등기필증 등의 작성을 위해 필요하게 된다.

186) 浦野雄幸, 逐條概說民事執行法(全訂版), 商事法務研究會(1971), 708.

Ⅲ. 압류등기말소의 촉탁

민사집행법 제228조에 의해 이미 등기된 질권, 저당권에 의해 담보되어 있는 채권에 대하여 압류등기가 되어 있어도 채권의 이전에 의한 저당권등의 이전등기 및 채권압류등기의 말소가 이루어지기 전에 위 압류등기를 말소해야 되는 경우가 있다.

즉 그 압류되어 있는 저당권부채권 등이 저당권 등의 실현으로서의 경매에 의한 변제, 지급, 공탁 등에 의해 소멸한 경우 및 채권집행의 신청의 취하가 있었던 경우 또는 압류명령의 취소결정이 확정된 경우 등이 이에 해당하는데, 민사집행규칙 제167조 제4항은 이와 같은 경우에 법원사무관등은 신청에 의해 그 등기의 말소를 촉탁해야 하는 것으로 규정하고 있다.

그리고 압류채권자는 제3채무자에 대하여 추심명령을 얻어 그 채권을 추심하는 것이 가능하고 당해 채권이 담보권에 의해 담보되어 있는 때는 이를 실행함으로써 피담보채권을 추심하는 것이 가능한데,¹⁸⁷⁾ 이와 같이 하여 담보권이 실행되어 압류채권자가 집행채권에 대하여 만족을 얻은 때에도 일종의 지급이라고 할 수 있지만, 이 경우에는 민사집행법 제144조 제1항에 따라 담보권부채권압류등기의 말소를 촉탁하는 것으로 되어 있다.¹⁸⁸⁾

1. 촉탁의 요건

민사집행규칙 제167조 제4항은, “압류된 채권이 변제 또는 공탁에 따라 소멸되었음을 증명하는 문서가 제출된 때” 및 “압류명령신청이 취하된 때” 또는 “압류명령의 취소결정이 확정된 때”에 채권압류등기의 말소를 촉탁하는 것으로 규정하고 있다. 이에 대해 약간 설명을 곁들이면 다음과 같다.

가. 압류된 채권이 변제 또는 공탁에 따라 소멸되었음을 증명하는 문서가 제출된 때

압류채권자가 추심에 의해 제3채무자로부터 피압류채권의 전액(그 금액이 집행채권 및 집행비용보다 적어서 이를 모두 만족시키지 못한 때) 또는 집행채권 및 집행비용 전액의 지급을 받은 때는 이로써 채권집행절차는 종료하고 압류도 장래에 향하여 실효되므로¹⁸⁹⁾ 채권압류등기의 말소 촉탁이 가능하게 된다.

187) 田中康久, 新民事執行法の解説(増補改訂版), 金融財政事情研究会, 313.[吉野 衛·宅弘人 共著, 香川保一 監修, 注釋民事執行法(6), きんざい, 平成 7年(1995), 786.에서 재인용]

188) 鈴木忠一 外, 위 注解民事執行法(4), 666.

189) 鈴木忠一 外, 위 注解民事執行法(4), 666.

그리고 압류채권자가 추심하여 제3채무자로부터 지급을 받은 때에는 민사집행법 제236조 제1항에 따라 바로 이를 집행법원에 신고해야 하는 것으로 되어 있다. 또 제3채무자가 민사집행법 제248조 제1항 내지 제3항에 기초하여 공탁한 경우에도 그 이후 배당등의 절차는 남아있지만 피담보채권은 소멸하고 압류도 실효하게 되며, 이 경우도 제3채무자는 위 제248조 제4항에 의해 공탁서를 첨부하여 그 취지를 집행법원에 신고해야 하는 것으로 되어 있다.

이와 같은 서면이 변제 또는 공탁이 있었던 사실을 증명하는 문서가 될 수 있고, 또 법원사무관등은 통상 사건기록 자체로 이러한 사실을 알 수 있으므로 이 경우는 다른 문서의 제출이 필요하지 않을 수 있다. 추심신고서나 사유신고서의 제출이 없는 경우에는 신청인이 이것을 증명하는 문서를 제출해야 할 것이다.¹⁹⁰⁾

나. 압류명령신청이 취하된 때

채권집행의 신청은 집행이 종료할 때까지 언제든지 취하할 수 있다.

그리고 적법한 취하가 있으면 그 시점에서 당연히 채권집행절차는 종료하고 압류도 실효되므로 채권압류등기의 말소 촉탁이 가능하게 된다. 또한 통상 신청의 취하는 취하서를 집행법원에 제출하게 되어 있으므로 법원사무관등은 그것에 의해 취하 사실을 알 수 있다.

다. 압류명령의 취소결정이 확정된 때

채권압류명령의 취소결정이 확정된 때도 당연히 채권집행절차는 종료하고 압류도 실효하게 된다.

그런데 압류명령의 취소결정에 대하여는 ① 그 취소결정이 확정되지 않으면 효력이 생기지 않는 것(민집 제17조 참조)과 ② 취소결정이 채무자 및 압류채권자에 대하여 고지된 때에 그 효력이 생기는 것(민집 제49조 제1호, 제3호, 제5호, 제6호에 따른 집행취소서류의 제출에 의한 취소, 민집 제50조 제2항 참조) 등이 있는데, 후자의 경우에는 위 민사집행규칙 제167조 제4항의 「취소결정이 확정된 때」를 적용할 때는 「취소결정의 효력이 생긴 때」로 고쳐서 이해해야 할 것이다. 또 이와 같은 사실도 기록상 명확하므로 따로이 증명을 위한 문서를 제출할 필요가 없음은 물론이다.

190) 鈴木忠一 外, 위 注解民事執行法(4), 666.

2. 촉탁의 절차

가. 신청권자 등

이 규정에 의한 압류등기말소의 촉탁도 신청에 의해서 행해진다(민집규 제167조 제4항). 신청권자는 저당권자(채무자) 또는 압류채권자이다.

촉탁서에 기재할 등기의 목적은 「저당권부채권 압류등기말소」이고, 등기원인은 각각 “변제(지급)”, “공탁”, “취하” 또는 “취소결정”이며, 등기원인의 날짜는 각각 변제 또는 공탁이 된 날, 취하가 된 날 또는 취소결정의 효력이 생긴 날이 될 것이다. 전술한 대로 압류명령의 취소결정에 대하여는 취소결정이 확정되지 않으면 그 효력이 생기지 않는 것으로 되어 있는 것과 취소결정이 채무자 및 압류채권자에게 고지된 때에 그 효력이 생기는 것으로 되어 있는 것이 있지만, 취소결정의 효력이 생긴 날이란 전자에 대하여는 그 취소결정이 확정된 날이고, 후자에 대하여는 그 취소결정이 채무자 및 압류채권자에게 고지된 날이 된다.

이 경우 등기권리자는 채무자(저당권자)이고, 등기의무자는 압류채권자이다.

등기원인증서와 관련하여서는, “취하” 또는 “취소결정”에 의하여 채권압류등기의 말소를 촉탁하는 경우에 채권압류의 신청의 취하서 또는 취소결정의 정본을 등기원인을 증명하는 서면으로 하는 것이 가능한지가 문제될 수 있는데, 이에 대하여는 부동산에 대한 강제경매신청이 취하된 경우 또는 강제경매절차가 취소결정된 경우와 동일하게 생각하면 될 것이다. 그리하여 채권압류신청의 취하서에 목적물건의 표시가 있는 등 등기원인을 증명하기에 족한 기재가 있는 경우에는 이것을 등기원인을 증명하는 서면으로 취급할 수 있고, 확정된 때에 그 효력이 생기는 것으로 되어 있는 취소결정의 정본에 확정된 취지 및 확정된 날이 부기되어 있는 경우 또는 채무자 및 압류채권자에게 고지된 때에 그 효력이 생기는 것으로 되어있는 취소결정의 정본에 그 고지가 된 취지 및 고지의 날이 부기되어 있는 경우 등에는 이러한 정본을 등기원인을 증명하는 서면으로 취급할 수 있을 것이다.

나. 비용의 부담 등

비용의 부담에 대하여는 민사집행규칙 제167조 제5항이 이를 규정하고 있다. 즉 변제 또는 공탁에 의한 압류채권의 소멸에 있어서는 채무자가 부담하고, 신청의 취하, 압류명령의 취소의 확정 등에 있어서는 압류채권자가 부담하는 것으로 하고 있

다.

그리고 채권압류등기의 말소는 을구란에 독립등기로 기입된다.

IV. 근저당권과 이전등기의 촉탁

1. 서

근저당권의 원본이 확정된 후에 개별 피담보채권이 압류된 경우 그 압류의 효력은 근저당권에까지 미치고, 또 압류에 관계된 피담보채권에 대하여 전부명령 등이 있었던 때에는 일반원칙에 의해 근저당권은 피담보채권의 이전에 수반하여 그 전부 또는 일부가 피압류채권자 등에 이전한다. 그래서 이 경우에는 근저당권의 전부 또는 일부 이전의 등기와 채권압류등기의 말소를 촉탁하게 된다.

그런데 여기서 살펴볼 문제는 근저당권의 원본이 확정되기 전에 개별 피담보채권이 압류된 경우 그 압류의 효력이 근저당권에까지 미치는가, 또 미친다고 할 경우 그 압류에 관계된 피담보채권에 대해 그 후 전부명령 등이 있었던 때에 그 근저당권의 전부 또는 일부가 위 피담보채권의 이전에 수반하여 압류채권자등에게 이전하는가 어떠한가이다.

2. 원본 확정 전의 근저당권부채권에 대한 압류의 효력

근저당권이 담보하는 채권의 범위에 속하는 채권이 원본확정 전에 압류된 경우에, 과연 그 압류의 효력이 근저당권에 미치게 되는가에 대하여는 이미 제3장 압류명령 제4절 II. 2. 다. 이하에서 자세히 살펴보았듯이 소극설과 적극설이 대립하고 있다.

그러나 그 부분에서 언급한 바대로 ㉠ 근저당권이 담보할 채권의 범위에 속하는 채권은 예를 들어 원본 확정 전이라고 해도 그대로 근저당권이 확정되면 근저당권에 의해 우선변제를 받을 수 있는 관계에 있어서, 무담보채권(일반채권)보다도 높은 가치를 가지고 있다고 말할 수 있는 점, ㉡ 위 소극설에 서게 되면 근저당권이 가지는 담보가치에 대한 강제집행 방법이 폐쇄되고 마는 점, ㉢ 또 위에서 본 것처럼 저당권부채권이 압류된 경우에 그 채권에 대한 압류의 효력이 그 종된 권리인 저당권에도 미치는 근거는 이른바 저당권의 수반성에서 이를 찾는 것이 일반적인데, 민법 제357조에 의해 원본 확정 전에 근저당권의 수반성이 부정되는 것은 채권양도 등의 경우에 한정되는 것이고, 원본확정 전의 채권에 대하여 압류가 되어도 그것에 의해 바로 채권

주체에 변경이 생기는 것은 아니므로 이 경우는 수반성의 문제도 해결될 수 있는 점, ㉔ 그리고 소극설이 그 이유로 하는 압류의 효력이 근저당권에 미친다고 해석하면 압류채권자가 근저당권을 실행하여 근저당거래를 종료시키게 되어 타당하지 않다든가, 근저당권자의 권리행사에 대해 압류채권자들의 동의를 요하는 것으로 되어 근저당권의 성질에 반한다는 것 등도 위와 같은 근저당권이 파악하는 담보가치에 대하여 강제집행을 허용해야 한다는 집행법상의 요청 앞에서는 어쩔 수 없는 것으로서 시인되어야 하는 점 등 여러 가지 이유를 고려할 때, 위 학설 중 적극설이 보다 합리적인 견해라고 보이므로 이에 찬동하기로 한다. 현재 실무도 이에 따르고 있는 것으로 생각된다.

3. 이전등기촉탁의 가능 여부

가. 그러면, 다시 나아가 원본확정 전의 근저당권부채권이 압류되어 압류등기가 된 후 다시 그 압류채권에 대하여 전부명령, 양도명령 또는 매각명령이 있었던 경우에 그 근저당권의 전부 또는 일부가 위 피담보채권의 이전에 수반하여 압류채권자들에게 이전하는가 여부에 대하여도 역시 다음과 같이 학설이 나뉘어지고 있다(이 문제는 근저당권부채권이 원본확정 전에 양도되거나 혹은 대위변제된 경우에 근저당권이 이에 수반되어 이전하는가의 문제와 상통하여 있고, 아래 학설은 이에 관한 견해의 대립이다).¹⁹¹⁾

1) 이전긍정설¹⁹²⁾

이 견해는 근저당거래 계속 중 발생한 개개의 채권이 양도 또는 대위변제된 경우 근저당권의 일부가 이전하여 양도인과 양수인 사이에 준공유관계가 발생한다는 것이다. 그 근거로는 피담보채권의 원본액이 근저당거래의 종료까지에는 확정되어 있지 않으나 개개의 채권은 역시 근저당권에 의하여 담보되어 있는 것이므로 그것이 근저당거래의 종료시에 현존한 경우 당해 근저당권에 의하여 담보된다는 이익을 보유하고 있는 한 양도되어도 이러한 이익을 보유한 채로 양수인에게 이전한다고 해석해야 한다거나 근저당권의 특질은 피담보채권의 수액이 근저당거래의 종료까지는 확정하지 않는다는 것일 뿐이고 근저당거래 중의 각개의 채권은 근저당권으로 담보되는 것이며

191) 일본은 원본의 확정 전에 근저당권자로부터 채권을 취득한 자는 그 채권에 대한 근저당권을 행사할 수 없고, 원본의 확정 전에 채무자를 위하여 또는 채무자에 갈음하여 변제한 자도 또한 같다고 규정함으로써(日民法 제398조의 7), 입법적으로 그 이전을 부정하는 입장을 취하였다.

192) 이영준, 물권법, 박영사(1991), 852.; 김석우, “근저당권의 처분에 관한 소고”, 김중환기념논문집, 406.; 장경학, 물권법, 법문사(1987), 827.; 香川保一, 新版擔保, 791.[곽윤직 편집대표, 민법주해(VII), 박영사(1996), 29.에서 재인용] 등

그 채권이 근저당거래 종료시에 현존한다면 그 근저당권에 의하여 담보된다는 이익을 가지고 있는 것이기 때문에 양도되더라도 그러한 이익을 가진 채 양수인에게 이전한다는 것 등을 들고 있다.¹⁹³⁾

2) 이전부정설¹⁹⁴⁾

이 설은 근저당거래 계속 중 발생한 개개의 채권이 양도 또는 대위변제된 경우 근저당권은 이전되지 아니한다는 견해인데, 근저당권에 있어서는 피담보채권의 유동 교체는 문제가 되지 않는다거나 근저당권에 의하여 담보되는 것은 계속적 거래로부터 발생하는 개개의 채권이라기 보다는 오히려 전체로서 부동(浮動)하는 채권이며, 계속적 거래관계 없는 확정채권을 가진 자와 준공유관계를 인정하는 것은 복잡한 문제를 발생시킨다는 점 등을 그 근거로 들고 있다.

이와 같이 학설이 대립하고는 있으나, 생각건대 우리 민법 제357조 제1항 후문 이, “이 경우에는 그 확정될 때까지의 채무의 소멸 또는 이전은 저당권에 영향을 미치지 아니한다.”라고 규정하고 있는 것은 일반 저당권과 달리 장래의 증감변동하는 불특정의 채권을 담보하는 근저당권의 성질상 그 원본확정 전에는 수반성이 부정됨을 명시한 것이라고 보아야 할 것이다.

이에 대하여 우리 대법원 또한 “근저당권은 계속적인 거래관계로부터 발생·소멸하는 불특정다수의 채권 중 그 결산기에 잔존하는 채권을 일정한 한도액의 범위 내에서 담보하는 것으로서 그 거래가 종료하기까지 그 피담보채권은 계속적으로 증감·변동하는 것이므로 근저당 거래관계가 계속되는 관계로 근저당권의 피담보채권이 확정되지 아니하는 동안에는 그 채권의 일부가 대위변제되었다 하더라도 그 근저당권이 대위변제자에게 이전될 수 없다.”라고 하거나¹⁹⁵⁾ 혹은 “변제할 정당한 이익이 있는 자가 채무자를 위하여 채권의 일부를 대위변제할 경우에 대위변제자는 변제한 가액의

193) 그런데 이 경우에 양수인이 취득하는 담보가치에 대하여, 근저당권확정 후에 확정채권액의 비율에 의하여 채권자와 양수인이 채권최고액을 분배하여 함께 우선변제를 받을 지위를 갖는다는 견해(香川保—(주192), 800.]와, 양수인의 지분은 보통 저당권의 성질을 가지고 있으며, 또한 양도 시점에 있어서 양도인과 양수인의 채권의 비율을 확정한다는 것은 실제로 있어 대단히 곤란하기 때문에 양수인은 전 양도채권에 대하여 우선권을 가지고, 근저당권자는 그 한도액을 그만큼 인하시킨 것으로 감수하여야 한다는 견해(장경학(주192), 827.; 김석우(주192), 406.; 이영준(주192), 852.)로 나뉘어져 있다. 다만 후설의 입장에서서도, 채권양도액이 최고액을 넘는 경우에도 근저당권의 일부이전의 등기를 할 것이고 전부이전의 등기를 할 것은 아니라고 한다[이영준(주192), 852.].

194) 박윤직, 물권법, 박영사(1990), 616.; 中川善之助 等 編, 주釋民法(9, 債權), 有斐閣(1964), 273.

195) 대법원 2000. 12. 26. 선고 2000다54451 판결; 대법원 1996. 6. 14. 선고 95다53812 판결

범위 내에서 종래 채권자가 가지고 있던 채권 및 담보에 관한 권리를 법률상 당연히 취득하게 되는 것이므로 채권자가 부동산에 대하여 근저당권을 가지고 있는 경우에는 채권자는 대위변제자에게 일부 대위변제에 따른 저당권의 일부 이전의 부기등기를 경료해 주어야 할 의무가 있다 할 것이나, 이 경우에도 채권자는 일부 변제자에 대하여 우선변제권을 가지고 있다 할 것이고, 근저당권이라고 함은 계속적인 거래관계로부터 발생하고 소멸하는 불특정다수의 장래 채권을 결산기에 계산하여 잔존하는 채무를 일정한 한도액의 범위 내에서 담보하는 저당권이어서 거래가 종료하기까지 채권은 계속적으로 증감변동하는 것이므로 근저당거래관계가 계속 중인 경우 즉 근저당권이 피담보채권이 확정되기 전에 그 채권의 일부를 양도하거나 대위변제한 경우 근저당권이 양수인이나 대위변제자에게 이전할 여지는 없다 할 것이나, 그 근저당권에 의하여 담보되는 피담보채권이 확정되게 되면, 그 피담보채권액이 그 근저당권의 채권최고액을 초과하지 않는 한 그 근저당권 내지 그 실행으로 인한 경락대금에 대한 권리 중 그 피담보채권액을 담보하고 남은 부분은 저당권의 일부이전의 부기등기의 경료 여부와 관계없이 대위변제자에게 법률상 당연히 이전된다.”라고 판시¹⁹⁶⁾함으로써 이전부정설의 입장을 취하고 있다고 보이는데,¹⁹⁷⁾ 이는 타당하다고 본다.

나. 이와 같이 원본 확정 전의 근저당권에 대하여 수반성이 부정되면 압류에 관계된 채권은 근저당권의 피담보채권으로부터 이탈해버리는 것으로 된다.

따라서 앞서 본대로 원본확정 전 근저당권부채권에 대한 압류의 효력이 근저당권에 미침을 긍정한다고 해도 다시 원본확정 전에 전부명령 등이 있었던 때에는 위와 같이 수반성이 부정되는 결과 압류에 관계된 채권은 무담보채권으로 되기 때문에 전부명령에 의해 채권을 취득한 자도 근저당권을 취득하는 것이 가능하지 않고 결국 그 이전등기를 받을 수 없게 되는 것이다.

그러므로 이 경우에는 근저당권부채권에 대하여(압류 및) 전부명령을 얻은 채권자가 이전등기촉탁 신청을 하더라도 법원사무관등은 이에 응하여 촉탁을 해서는 안된

196) 대법원 2002. 7. 26. 선고 2001다53929 판결

197) 물론 위 판례들은 근저당권에 대하여 원본확정 전의 채권양도 또는 대위변제의 경우에 수반성을 부정하는 취지의 것들이지만, 원본 확정 전에 피담보채권이 압류 및 전부된 경우에도 이는 단지 당사자 사이의 계약에 의한 채권이전이나(채권양도) 혹은 법률의 규정에 의한 채권이전이나(대위변제, 전부명령)의 차이가 있을 뿐 모두 동일한 채권이전의 형태들이고, 그 이전에 대해 근저당권이 수반하는가의 문제는 여전히 근저당권의 성질에 관한 문제이므로 결국 근저당권의 피담보채권이 압류 및 전부된 경우에도 위 판례들의 취지와 똑같이 해석될 수밖에 없다고 보아야 할 것이다.

다 할 것이다. 198) 199) 200)

4. 압류등기말소의 방법

가. 위와 같이 원본확정 전에 근저당권의 피담보채권이 이전한 경우에 있어서는 근저당권의 수반성이 부정되는 결과, 압류에 관계된 채권은 무담보채권으로 되기 때문에 전부명령 등에 의해 채권을 취득하였어도 근저당권을 취득할 수 없고 또 그 이전등기를 받을 수 없게 된다.

그래서 이러한 전부명령 등이 있었던 때는 먼저 경료된 근저당권부채권에 대한 압류등기는 의미가 없는 것으로 되어버리므로 이를 말소해야 되지만, 그 말소방법에 관하여는 견해의 대립이 있다.

즉 이에 대하여, ① 민사집행규칙 제167조 제4항에 의해서 그 말소촉탁을 해야 한다는 설,²⁰¹⁾ ② 집행법원이 원본확정 전에 압류채권에 대하여 전부명령등을 발한 때는 압류명령의 취소결정을 한 다음 민사집행규칙 제167조 제4항의 규정에 의해 “취소결정”을 등기원인으로 하여 압류등기의 말소촉탁을 해야 한다는 설,²⁰²⁾ ③ 민사집행규칙 제167조 제4항에 기재하는 사유를, 담보권이 이전하는 것이 아니라 압류명령이 존재의의를 상실한 경우의 예시로 해석하여 이 경우에는 압류명령을 취소할 것

198) 그런데 현재의 실무 일부례는 이러한 때에도 이전등기촉탁을 인정해주고 또 나아가 그 이전등기에 따른 경매신청마저 받아주는 경우도 있어 보이는데, 이는 법리에 맞지 않으므로 재고가 필요하다.

199) 근저당권이 담보하는 채권이 확정되기 전에 그 채권을 양도하면서 근저당권을 함께 이전하기 위해서는 채권뿐만 아니라 근저당권도 모두 이전하는 형식, 즉 그 계약상 지위를 양도하는 방법에 의해서 하여야 한다. 또한 근저당권의 존속기간을 정하지 않은 때에 채권자와 채무자가 그 기본계약 또는 근저당권설정계약을 해지하고 원본채권을 확정된 다음 그 확정된 채권을 양도하는 경우에는 이는 확정채권양도이므로 위 근저당권은 통상 저당권과 같은 성질을 갖게 되어 그 채권 이전에 수반하게 된다.

200) 따라서 근저당권부채권을 압류한 채권자는 그에 대해 전부명령을 얻지 말고 추심명령을 얻어 그 추심권의 발동으로서 경매를 신청하여 일단 근저당권을 확정시킨 후 전부명령을 받는 방법을 강구함이 타당하고, 또 만일 전부명령을 받아버려 무담보채권만을 이전받게 되었다면 제3채무자인 근저당권설정자를 상대로 전부금소송을 제기하여 승소한 후 그것으로써 당해 부동산에 대해 강제경매를 신청하면 그 채권 회수의 목적을 달성할 수 있을 것이다[이때 압류채권자가 이미 채권을 전부받아버린 근저당권자의 근저당권은 그 채권이 압류채권자에게 이전되어버렸으므로 채권 부존재상태인지라(결국, 위 근저당권은 소멸한다. 대법원 1997. 11. 25. 선고 97다29790 판결, 대법원 1999. 2. 5. 선고 97다33997 판결), 압류 및 전부권자가 강제경매를 신청하더라도 무익여로 취소되는 일은 거의 없을 것이다].

201) 稻葉威雄, “抵當權付債權の差押の登記”, 不動産登記講座IV·各論(2)(改訂版), 52.

202) 松尾, “根抵當權付債權の差押え, 質入れの登記と諸問題(3)”, 金融法務事情 978号, 8.[吉野 衛外, 위 注釋民事執行法(6), 790.에서 재인용]

까지 없이 위 제4항에 의하여 “전부명령”등을 등기원인으로 하는 압류등기의 말소촉탁이 가능하다는 설²⁰³⁾ 등이 나타나고 있지만, 전부명령이 확정된 경우 그 전제가 되는 압류명령이 그 목적을 달성하고 장래에 소멸하는 것을 감안하면 위 ③설에 따라 처리하는 것이 타당하다고 생각한다.²⁰⁴⁾

나. 다음으로 원본확정 전의 근저당권부채권에 대하여 압류등기가 되고, 원본확정 후에 그 압류채권에 대하여 전부명령 또는 양도명령 또는 매각명령이 있었던 경우에는 일반원칙에 의해 근저당권은 피담보채권의 이전에 수반하여 그 전부 또는 일부가 압류채권자등에게 이전하게 된다(원본 확정 후의 근저당권은 일반 저당권과 동일한 성질을 가진다²⁰⁵⁾).

따라서 이 경우는 민사집행법 제230조와 민사집행규칙 제167조 제4항 등에 따라 법원사무관등은 근저당권의 전부 또는 일부의 이전등기와 채권압류등기의 말소를 촉탁하면 될 것이다.

다. 문제는 근저당권에 대하여 그 원본이 확정되었음에도 이에 관한 등기가 아직 되어 있지 않은 경우에 관해서인데, 만일 당초 근저당권의 존속기간 또는 기본계약에 의한 거래관계의 결산에 관한 약정이 등기되어 있었고²⁰⁶⁾ 그에 따라 그 확정일이 이미 도래하여 있음이 명백한 때에는 원본확정의 등기가 되어있지 않은 경우에도 이전 등기 등의 촉탁이 가능하다고 볼 것이나,²⁰⁷⁾ 그 외의 경우에는 이러한 등기 등을 촉탁할 수 없고 또 원본확정등기의 촉탁도 할 수 없다.

이 경우에 채권자 또는 매수인은 전부명령 등을 대위원인으로 채무자인 근저당권자를 대위하여 근저당권설정자와 공동으로 원본확정의 등기를 신청해야 할 것이다.²⁰⁸⁾

203) 鈴木忠一 外, 위 注解民事執行法(4), 667.

204) 吉野 衛 外, 위 注解民事執行法(6), 790.

205) 대법원 1963. 2. 7. 선고 62다796 판결【판결요지】신민법 시행 전에 있어서도 근저당권설정계약을 무효로 할 이유가 없을 뿐만 아니라 저당권이 일반 저당권 또는 근저당권에 해당되는 여부는 그 명칭에만 구애될 것이 아니고 그 설정계약의 내용에 의하여 결정하여야 하며 근저당권의 경우에 있어서도 담보채권이 확정된 경우에는 일반 저당권으로 전환된다고 해석함이 타당할 것이다.

206) 이러한 사항에 대한 등기 여부는 당사자 사이의 자유이고, 근저당권의 효력을 좌우하는 문제도 아니다.

207) 吉野 衛 外, 위 注解民事執行法(6), 791.

208) 南 敏文, “根抵當權의 確定”, 判例先例金融取引法(新訂版), 291.[吉野 衛 外, 위 注解民事執行法(6), 791.에서 재인용]

[5 - 1] 채권압류 및 전부명령 신청서

채권압류 및 전부명령 신청		
수 입 인 지	채 권 자	이 ○ ○ ○○시 ○○구 ○○동 ○○ 소송대리인 변호사 손 재 주
	채 무 자	오 ○ ○ ○○시 ○○구 ○○동 ○○
	제3채무자	장 ○ ○ ○○시 ○○구 ○○동 ○○
채무명의의 표시`		
채권자와 채무자 사이의 ○○지방법원 2018. 2. 16. 선고 2018가합101 손해배상 사건의 확정판결		
청구채권의 표시		
금 55,000,000원(손해배상금)		
압류할 채권의 표시		
금 40,000,000원(채무자가 2018. 4. 1. 제3채무자에게 공급한 건설기자재 대금)		
신 청 취 지		
채무자가 제3채무자에 대하여 가지고 있는 위 채권을 압류하고, 채권자의 청구채권의 지급에 갈음하여 위 압류된 채권을 채권자에게 전부한다. 는 재판을 구합니다.		
신 청 이 유		
1. 채권자는 채무자에 대하여 위 채무명의 집행력 있는 정본에 기한 위 청구채권표시의 채권을 가지고 있고, 채무자는 제3채무자에 대하여 위 압류할 채권 표시의 채권을 가지고 있습니다.		
2. 이에 채무자의 제3채무자에 대한 위 채권을 압류하고, 나아가 채권자의 위 청구채권의 지급에 갈음하여 위 압류된 채권을 채권자에게 전부한다는 재판을 구하기 위하여 이 사건 신청을 합니다.		

첨 부 서 류

- | | |
|----------------|----|
| 1. 집행력 있는 판결正本 | 1통 |
| 1. 송달증명서 | 1통 |
| 1. 위임장 | 1통 |

20

채권자 소송대리인 변호사 손 재 주 ㉑

○○ 지방법원 귀중

[5 - 2] 채권전부명령

○ ○ 지 방 법 원

결정

사 건 20 타채 전부명령

채 권 자

채 무 자

제 3 채무자

주 문

채무자의 제3채무자에 대한 별지 기재의 압류된 채권을 지급에 갈음하여 채권자에게 전부한다.

이 유

○ ○ 지방법원 20 타채 채권압류사건에 관한 채권자의 신청은 이유 있으므로 주문과 같이 결정한다.

20 . . .

판사(사법보좌관)

인

[5 - 3] 채권압류 및 전부명령

○ ○ 법 원

결 정

사 건 20 타채 채권압류 및 전부명령

채 권 자

채 무 자

제3채무자

주 문

1. 채무자의 제3채무자에 대한 별지 기재의 채권을 압류한다.
2. 제3채무자는 채무자에게 위 채권에 관한 지급을 하여서는 아니 된다.
3. 채무자는 위 채권의 처분과 영수를 하여서는 아니 된다.
4. 위 압류된 채권은 지급에 갈음하여 채권자에게 전부한다.

청구금액

금 원(대여금)

금 원(위 대여금에 대한 이자 및 지연손해금)

합계 금 원

이 유

채권자가 위 청구금액을 변제받기 위하여 ○○지방법원 20 가합 대여금 청구사건의 집행력 있는 판결정본에 기초하여 한 이 사건 압류 및 전부명령 신청은 이유 있으므로 주문과 같이 결정한다.

20 . . .

판사(사법보좌관)

㉠

- 주의 : 1. 전부명령이 제3채무자에게 송달될 때까지 다른 채권자가 압류, 가압류 또는 배당요구를 한 때에는 전부명령은 효력이 없습니다.
2. 전부명령은 확정되어야 효력이 있습니다.
3. 이 결정에 불복하는 사람은 송달받은 날부터 1주 내에 이 법원에 항고장을 제출하여야 합니다.

민사집행법 제15조, 제223조, 제227조, 제229조

[5 - 4] 근저당권부 채권압류 및 전부명령 신청

근저당권부 채권압류 및 전부명령 신청

채 권 자 ○ ○ ○
 주 소
채 무 자 ○ ○ ○
 주 소
제3채무자 ○ ○ ○
 주 소

청구채권의 표시
일금 25,000,000원정

내 역
① 금 45,953,800원정 대여원금,
② 금 8,844,532원정 위 원금에 대한 2007. 8. 29.부터 아래 내역과 같은 지연 손해금,
③ 합계금 54,798,332원 중 일부금
지연손해금 계산내역

원 금	기간(일수)	이율	계 산	금 액
45,953,800	2007.8.29.~ 2009.4.21.(600)	5%	원금×0.05×600/6 35	3,777,024
	2009.4.22.~ 2009.9.30.(161)	25%	원금×0.25×161/3 65	5,067,508
			합 계	8,844,532

압류할 채권의 표시

별지목록 기재와 같습니다.

신 청 취 지

1. 채권자가 가지는 위 청구채권에 기하여, 채무자가 제3채무자에 대하여 가지는 별지목록 기재 근저당권부 채권을 압류한다.
 2. 제3채무자는 채무자에게 위 채권에 관한 지급을 하여서는 안 된다.
 3. 채무자는 위 채권의 처분과 영수를 하여서는 안 된다.
 4. 위 압류된 채권은 지급에 갈음하여 채권자에게 전부 한다.
- 라는 결정을 구합니다.

신 청 이 유

위 청구채권은 채권자와 채무자간의 ○○지방법원의 2013가합000호 손해배상(기) 청구사건의 집행력 있는 정본에 의한 채무자가 채권자에게 변제할 금액인 바, 채무자는 임의로 변제치 않으므로 그 변제를 받고자, 채무자가 제3채무자에 대하여 가지는 위 근저당권부 채권에 대하여 압류명령 및 전부를 받고자 이 건 신청에 이른 것입니다.

첨 부 서 류

- | | |
|----------------|----|
| 1. 집행력 있는 판결정본 | 1통 |
| 1. 송달증명원 | 1통 |
| 1. 부동산등기사항증명서 | 1통 |

20 . . .

위 채권자 ○ ○ ○ 인

○ ○ 지방법원 귀중

[5 - 5] 전부명령신청취하서

전부명령신청취하서

사 건 2018타기○○○호 채권전부명령
채 권 자 ○ ○ ○
채 무 자 ○ ○ ○
제3채무자 ○ ○ ○

위 당사자간 귀 원 2018타기○○○호 채권전부명령신청사건에 관하여 채권자는 위 전부
명령신청을 취하합니다.

첨 부 서 류

1. 취하서 부분 1통

20 . . .

위 채권자 ○ ○ ○ ①

○ ○ 지방법원 귀 중